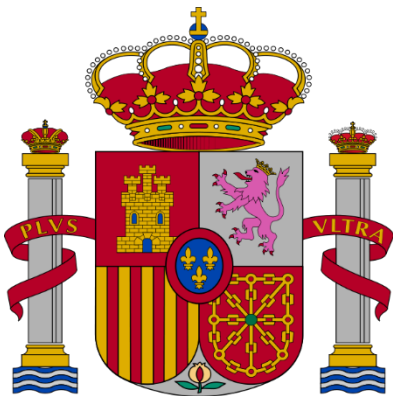




Derecho Penal I

Javier Vázquez Pariente
Magistrado

**Temas del Programa de las Oposiciones de Ingreso en las
Carreras Judicial y Fiscal**

**Edición adaptada al programa publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2025**

Abril 2026

Información sobre el temario y suscripción a actualizaciones en:
www.vazquezpariente.com y Carrera.Judicial.2008@gmail.com

Edición cerrada el 20 de abril de 2026

DERECHO PENAL I

Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2025

TEMA 1. LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL; EN ESPECIAL, LOS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, LEGALIDAD, CULPABILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM». LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO PENAL. LA ANALOGÍA.

TEMA 2. LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. EL SISTEMA CAUSALISTA. EL SISTEMA FINALISTA.. EL CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. CLASES DE DELITOS. SUJETOS, TIEMPO Y LUGAR DEL DELITO.

TEMA 3. TIPICIDAD. ESTRUCTURA, CLASES Y FORMULACIÓN DE LOS TIPOS. LA ACCIÓN. TEORÍAS CAUSALES. CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL CRITERIO DE LA JURISPRUDENCIA PENAL.

TEMA 4. EL DOLO. CLASES DE DOLO. LA DELIMITACIÓN DEL DOLO EVENTUAL DE LA CULPA CONSCIENTE. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO.

TEMA 5. EL DELITO IMPRUDENTE. ELEMENTOS. LA INCRIMINACIÓN DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

TEMA 6. EL DELITO DE OMISIÓN. CLASES. LA CLÁUSULA DEL ARTÍCULO 11.

TEMA 7. ANTIJURIDICIDAD. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN: LEGÍTIMA DEFENSA; ESTADO DE NECESIDAD; OBRAR EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO.

TEMA 8. IMPUTABILIDAD, CULPABILIDAD Y CAUSAS QUE LAS EXCLUYEN. ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA. INTOXICACIÓN PLENA. ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN. LA MENOR EDAD. EL MIEDO INSUPERABLE.

TEMA 9. TEORÍA DEL ERROR EN EL DERECHO PENAL. CLASES DE ERROR. CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

TEMA 10. LA PUNIBILIDAD. LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS. LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. LAS CONDICIONES DE PERSEGUIBILIDAD.

TEMA 11. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. ANÁLISIS DE LAS EXIMENTES INCOMPLETAS.

TEMA 12. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA AGRAVANTE DE GÉNERO. EL PROBLEMA DE LA COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

TEMA 13. LAS FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO. EL «ITER CRIMINIS». LOS ACTOS PREPARATORIOS. LA CONSPIRACIÓN, LA PROPOSICIÓN Y LA PROVOCACIÓN PARA DELINQUIR. LA TENTATIVA. EL DESISTIMIENTO. EL DELITO IMPOSIBLE.

TEMA 14. LA AUTORÍA. AUTORÍA DIRECTA Y MEDIATA. LA COAUTORÍA. LA PARTICIPACIÓN: FUNDAMENTO; LA ACCESORIEDAD. INDUCCIÓN, COOPERACIÓN NECESARIA Y COMPLICIDAD.

TEMA 15. LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFERENCIAS DOCTRINALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. RÉGIMEN DE INCRIMINACIÓN: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. PENAS Y CRITERIOS DE DETERMINACIÓN. RESPONSABILIDAD CIVIL.

TEMA 16. TEORÍA DEL CONCURSO. CONCURSO DE LEYES. CONCURSO DE DELITOS. EL DELITO CONTINUADO Y EL DELITO MASA.

TEMA 17. LA PENA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES. CLASES DE PENAS. LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

TEMA 18. LA PENA DE MULTA. LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS, CON REFERENCIA A LAS PROHIBICIONES DE APROXIMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA Y DE RESIDENCIA EN DETERMINADOS LUGARES EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. LAS PENAS ACCESORIAS.

TEMA 19. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS: EL DECOMISO. MEDIDAS APLICABLES A LAS AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA.

TEMA 20. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. ESPECIALIDADES EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA. REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

TEMA 21. SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. LA LIBERTAD CONDICIONAL.

TEMA 22. LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. REGLAS GENERALES Y ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA.

TEMA 23. LA MEDIDA DE SEGURIDAD: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES. CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNAMIENTO. CONCURRENCIA DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

TEMA 24. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. LAS COSTAS PROCESALES.

TEMA 25. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL. LA CANCELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PENALES. BREVE REFERENCIA AL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES Y TRATA DE SERES HUMANOS.

TEMA 26. EL DERECHO PENITENCIARIO. LA RELACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA. EL JUEZ DE VIGILANCIA. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

EXTENSIÓN DE LOS TEMAS

Número de palabras

1	3433
2	2998
3	3072
4	3176
5	3124
6	3057
7	3208
8	3120
9	3104
10	3097
11	3183
12	3591
13	2997
14	3095
15	2966
16	3054
17	3651
18	3362
19	3074
20	3245
21	2975
22	3135
23	3108
24	3498
25	3651
26	3121

DERECHO PENAL

TEMA 1

LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL; EN ESPECIAL, LOS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, LEGALIDAD, CULPABILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM». LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO PENAL. LA ANALOGÍA.

LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL

- Al estudiar los principios informadores del Derecho Penal, hay que comenzar señalando que el Derecho Penal puede contemplarse desde un punto de vista objetivo o subjetivo.
 - En efecto, desde un punto de vista objetivo, el Derecho Penal se define como *aquel sector del ordenamiento jurídico a través del cual el Estado sanciona con reacciones de particular gravedad las conductas desviadas más peligrosas para la convivencia con el fin de asegurar la disciplina social.*
 - Por el contrario, desde un punto de vista subjetivo, el Derecho Penal se define como *el derecho del Estado a definir los delitos y a establecer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad.*
- En cuanto a sus **principios informadores**, nos referiremos a los principios de intervención mínima, legalidad, culpabilidad y no discriminación.

EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA

- En cuanto al principio de intervención mínima, podemos definirlo como *aquel principio en virtud del cual el Derecho Penal sólo debe intervenir ante los conflictos sociales cuando ello resulte estrictamente necesario.*
- Por otro lado, este principio de intervención mínima se manifiesta en el carácter subsidiario y el carácter fragmentario del Derecho Penal.
- En cuanto a su **carácter subsidiario**, éste implica que el Derecho Penal sólo debe intervenir ante los conflictos sociales como *ultima ratio* o, lo que es igual, cuando se han agotado otros medios menos lesivos y más eficaces con los que cuenta el Estado de Derecho y entre los que cabe destacar la imposición de sanciones civiles como la nulidad de los negocios jurídicos y la reparación de daños y perjuicios.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que el principio de intervención mínima no es un principio de interpretación de las normas penales sino un principio de política criminal dirigido esencialmente al legislador.
 - De este modo, el principio de intervención mínima no permite excluir por razones de oportunidad el castigo de hechos tipificados penalmente y que los Jueces o Tribunales consideren de menor significación¹.
- En cuanto a su **carácter fragmentario**, éste implica que el Derecho Penal sólo debe intervenir castigando los ataques más intolerables contra los bienes jurídicos más fundamentales.
- En este sentido, el principio de intervención mínima exige despenalizar los llamados “delitos bagatela” o conductas que han dejado de recibir un reproche social significativo pero también castigar las nuevas formas de delincuencia y los atentados contra aquellos bienes jurídicos que la sociedad considera especialmente valiosos.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

- Pasando a ocuparnos del principio de legalidad, éste fue primeramente formulado en el s. XVIII por Beccaria y Feuerbach con la máxima *nullum crimen, nulla poena sine lege*
- Por otro lado, el principio de legalidad fue acogido en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y aparece actualmente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

- En cuanto al **principio de legalidad en nuestro ordenamiento**, el mismo está previsto en el art. 25.1 de la Constitución que dispone que *nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento*.
 - En este sentido, el principio de legalidad constituye uno de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I por lo que podrá ser invocado en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
 - Por su parte, el art. 1 del Código Penal dispone que *no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración*.

GARANTÍAS

- En cuanto a las garantías del principio de legalidad penal, éste se traduce en cuatro garantías como son la garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía en la ejecución.
- En cuanto a la **garantía criminal**, ésta implica que la tipificación de conductas delictivas y el establecimiento de causas de agravación sólo pueden realizarse mediante ley.
 - En este sentido, el art. 10 del Código Penal dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*.
 - Por su parte, el art. 4.2 dispone que *en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal*.
- En cuanto a la **garantía penal**, ésta implica que la definición de las penas asociadas a una infracción penal sólo puede realizarse mediante ley.
- En este sentido, el art. 2 que *no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad*.
- En cuanto a la **garantía jurisdiccional**, ésta implica que la apreciación de una infracción penal y la imposición de una pena sólo pueden realizarse por sentencia judicial y conforme al procedimiento legalmente previsto.
 - En este sentido, el art. 3.1 dispone que *no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales*.
 - Por su parte, el art. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que *no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por el Juez competente*.
- En cuanto a la **garantía en la ejecución**, ésta implica que la ejecución de la pena se ajustará a la norma que la regule.
 - En efecto, el art. 3.2 del Código Penal dispone que *tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes*.
 - Por su parte, el art. 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que *la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales*.

CONSECUENCIAS

- En cuanto a las consecuencias del principio de legalidad, éste se traduce en cuatro exigencias como son las de *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa* y *lex previa*.
- En cuanto a la **exigencia de *lex scripta***, ésta implica que la definición de los delitos y penas sólo podrá realizarse por normas con rango formal de ley.
- En este sentido, el art. 149.1.6ª de la Constitución dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación penal por lo que la regulación de los delitos y las penas se realizará siempre mediante leyes estatales.
- Por otro lado, se han planteado dos cuestiones:
 - En primer lugar, se plantea la cuestión de determinar si las leyes penales deben ser ordinarias u orgánicas. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que la reserva de ley orgánica sólo afectará a las leyes penales que restrinjan los derechos fundamentales y libertades públicas como son las que establecen penas privativas de libertad o de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo pero no las que prevean penas como la multa o la privación del derecho a la conducción de vehículos a motor²
 - En segundo lugar, se plantea la cuestión de determinar los límites constitucionales de las leyes penales en blanco, entendidas como aquéllas en que la conducta típica o su consecuencia jurídica no están plenamente definidas por lo que es necesario acudir a normas integradoras de rango inferior. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que las leyes penales en blanco deben reunir tres requisitos como son que el reenvío sea expreso, que esté justificado en razón del bien jurídico protegido y que la ley penal establezca la pena y el núcleo esencial de la prohibición³.
- En cuanto a la **exigencia de *lex stricta***, ésta implica que las leyes penales sólo se aplicarán a los casos expresamente previstos en ellas con la consiguiente exclusión de la interpretación extensiva y la analogía en los términos que señalaremos más adelante.
- En cuanto a la **exigencia de *lex certa***, ésta implica que la definición de los delitos y las penas y medidas de seguridad debe realizarse mediante tipos cerrados y elementos descriptivos.
 - En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró que el uso de conceptos jurídicos indeterminados en los tipos penales es contrario al principio de legalidad cuando el tipo queda formulado de forma tan abierta que su aplicación depende de una decisión libre y arbitraria de los Jueces y Tribunales⁴.
 - Finalmente, esta exigencia de taxatividad no impide que la ley fije los márgenes dentro de los que corresponde al Juez individualizar la pena concreta que procede imponer.
- En cuanto a la **exigencia de *lex previa***, ésta implica que la ley penal deberá ser anterior al hecho sancionado con la consiguiente prohibición de retroactividad de la ley penal.
- En este sentido, el art. 9.3 de la Constitución dispone que *la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos*.
- Por su parte, el art. 2 del Código Penal establece las siguientes reglas:
 - 1º. *No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.*
 - 2º. *No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley penal más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.*

- En relación con este precepto, cabe señalar que el mismo acoge el principio de retroactividad en su extensión más plena porque la ley nueva se aplicará no sólo a los hechos pendientes de enjuiciamiento sino también a los resueltos mediante sentencia firme aunque el reo estuviere cumpliendo condena.
- Por su parte, la doctrina sostiene que el principio también se aplicará aunque el reo hubiere cumplido íntegramente la condena a efectos de cancelación de los antecedentes penales y apreciación de la agravante de reincidencia.
- En cuanto a la **determinación de la ley penal más favorable**, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que ésta se efectuará por referencia al caso concreto y teniendo en cuenta no sólo las penas previstas para el delito sino también las reglas de determinación derivadas del grado de participación y desarrollo y de las circunstancias modificativas.
- Por otro lado, la comparación entre ambas leyes deberá realizarse en bloque y sin que sea admisible la combinación de los preceptos de una y otra para formar una tercera norma⁵.

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

- Pasando a ocuparnos del principio de culpabilidad, podemos definirlo como *aquel principio en virtud del cual no procede la imposición de una pena cuando el hecho no resulta reprochable personalmente a su autor*.
- En este sentido, el principio de culpabilidad se basa en el presupuesto de la imputabilidad entendida como la capacidad del sujeto para comprender la significación antijurídica de sus propios actos y actuar conforme a esta comprensión.
- Por otro lado, el principio de culpabilidad se traduce en los siguientes principios:
 - Primero, el principio de personalidad de las penas conforme al cual la responsabilidad penal sólo será exigible a personas concretas y por sus actos propios sin que pueda admitirse una responsabilidad colectiva extensible al grupo familiar o social.
 - Segundo, el principio de responsabilidad subjetiva conforme al cual la responsabilidad penal sólo será exigible por los hechos causados por dolo o imprudencia pero no por los producidos fortuitamente.
 - Tercero, el principio de graduación de la pena conforme a la culpabilidad del autor.
 - Por último, el principio de responsabilidad por el hecho que implica que el Derecho Penal no castiga la personalidad o la pertenencia del sujeto a determinados grupos ya que ello daría lugar a un Derecho Penal de autor.

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

- En cuanto al principio de no discriminación, conviene recordar el art. 14 de la Constitución que dispone que *los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*.
- En este sentido, el principio de no discriminación puede contemplarse como un límite a la ley penal pero también como un mandato de protección penal.
- En cuanto a su **aplicación como límite de la ley penal**, el principio de no discriminación se opone a las leyes penales formalmente discriminatorias que establecen diferencias de trato sin una justificación objetiva y razonable.
- Por otro lado, este principio no impide que legislador establezca diferencias de trato fundadas en razones objetivas como la mayor vulnerabilidad de la víctima o en la mayor gravedad del ataque al bien jurídico protegido como en los delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos.

- En este sentido, conviene recordar la Ley Orgánica 1/2004 que introdujo el reforzamiento de la respuesta penal a determinadas infracciones en el caso de que la víctima sea esposa o mujer que haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
- Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional declaró que la discriminación penal positiva por razones de género no es contraria a los principios de igualdad y culpabilidad⁶.
- En cuanto a su **aplicación como mandato de protección**, el principio de no discriminación puede operar como exigencia de sanción penal de determinadas conductas discriminatorias y como exigencia para la labor interpretativa del Juez.
 - De este modo, el Convenio de Estambul de 2011 obliga a los Estados parte a tipificar como delito ciertas conductas de violencia contra la mujer como el acoso, la violencia física o sexual, el aborto, los matrimonios forzados y las mutilaciones genitales.
 - De igual modo, la Decisión Marco de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2008 obliga a los Estados miembros a tipificar como delito determinadas conductas de tipo racista o xenófobo.
- Finalmente, hay que señalar que la sanción penal de las conductas discriminatorias puede realizarse por dos vías como son la tipificación específica de conductas concretas o la fijación de una agravante genérica para los delitos cometidos por móviles discriminatorios.
 - En este sentido, el Código Penal contempla delitos antidiscriminatorios como los de discriminación en el empleo del art. 314 o incitación al odio contra ciertos grupos por motivos discriminatorios del art. 510.
 - De igual modo, también se establece la agravante genérica del art. 22.4 y ciertos tipos agravados como las amenazas para atemorizar a un grupo étnico, cultural o religioso del art. 170 y las torturas por motivos de discriminación del art. 174.

OTROS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL

- En cuanto a los otros principios informadores del Derecho Penal, cabe señalar los principios de proporcionalidad, resocialización y prohibición de las penas inhumanas o degradantes.
- En cuanto al **principio de proporcionalidad**, éste implica que las penas previstas para cada delito deberán ser necesarias, adecuadas y proporcionadas en sentido estricto para preservar los bienes jurídicos que se trata de proteger.
- En cuanto al **principio de resocialización**, éste aparece consagrado en el art. 25.2 de la Constitución que establece las siguientes reglas:
 - 1º. *Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.*
 - 2º. *El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.*
- En cuanto al **principio de humanidad de las penas**, éste aparece consagrado en el art. 15 de la Constitución que dispone que *todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.*
- En este sentido, hay que señalar que el Código Penal Militar de 1985 contemplaba la pena de muerte inicialmente para determinados supuestos y en tiempo de guerra. Por su parte, la Ley Orgánica 11/1995 abolió la pena de muerte incluso en tiempo de guerra.

EL PRINCIPIO *NON BIS IN IDEM*

- Pasando a ocuparnos del principio *non bis in idem*, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que este principio no está expresamente reconocido en la Constitución pero se desprende de una consideración conjunta del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24 y del principio de legalidad penal y administrativa del art. 25⁷.
- En cuanto a su **significado material**, el principio *non bis in idem* impide que una persona sea sometida a una doble sanción penal y administrativa por el mismo hecho.
 - No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido esta dualidad de sanciones cuando su fundamento sea diferente.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia sostiene que existe diversidad de fundamento cuando la segunda sanción castigue el hecho desde la perspectiva de un bien jurídico distinto de la primera como sucede cuando la conducta se produce en el ámbito de una relación de supremacía especial ya sea laboral, penitenciaria o de otro tipo⁸.
- En cuanto a su **significado formal**, el principio *non bis in idem* impide que una persona sea sometida a dos procesos penales o sancionadores por unos mismos hechos.
- En este sentido, la potestad sancionadora de la Administración está subordinada a la de los Tribunales como muestran los siguientes principios:
 - Primero, el principio de preferencia del orden penal sobre la potestad sancionadora de la Administración que implica que, tratándose de conductas delictivas, la Administración no podrá actuar mientras no lo hagan los Tribunales.
 - Segundo, el principio de vinculación de la Administración a los hechos declarados probados por los Tribunales que implica que la Administración no podrá sancionar cuando los Tribunales hayan dictado sentencia absolutoria basada en la inexistencia del hecho o falta de participación del acusado pero sí cuando los Tribunales hayan dictado sentencia absolutoria por entender que los hechos no constituyen delito.

LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO PENAL

- Pasando a ocuparnos de la interpretación en Derecho Penal, conviene recordar el art. 3.1 del Código Civil que establece cinco criterios interpretativos como son el gramatical, el sistemático, el histórico, el sociológico y el teleológico.
- En este sentido, el criterio teleológico exige atender al bien jurídico protegido por la norma en la medida en que el Derecho Penal se dirige a la protección de bienes jurídicos.
 - Por otro lado, se ha planteado la cuestión de determinar si la interpretación en Derecho Penal debe ser necesariamente restrictiva debido al carácter gravoso de las normas penales y conforme al principio *odiosa stant restringenda, favorabilia sunt amplianda*.
 - En relación con ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se inclina por la tesis positiva por entender que el derecho fundamental a la legalidad sancionadora del art. 25 de la Constitución incluye un mandato de taxatividad o certeza que prohíbe realizar una interpretación extensiva de las normas penales⁹.

LA ANALOGÍA

- En cuanto a la analogía, el art. 4.1 del Código Penal dispone que *las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas*.

- En relación con este precepto, la doctrina mayoritaria sostiene que sólo queda prohibida la analogía contraria al reo o *in malam partem* pero no la analogía favorable al reo o *in bonam partem*.
- Finalmente, la analogía *in bonam partem* puede aparecer expresamente prevista por la ley como sucede en el art. 21 del Código Penal que prevé como circunstancia atenuante *cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores*.

¹ SSTS 28 de febrero de 2005 y 8 de enero de 2020.

² STC 140/1996, de 16 de septiembre.

³ STC 127/1990, de 5 de julio.

⁴ STC 89/1993, de 12 de marzo.

⁵ STC 131/1986, de 29 de octubre

⁶ SSTC 59/2008, de 14 de mayo; 76/2008, de 24 de julio; 80/2008, de 17 de julio, entre otras.

⁷ SSTC 2/1981, de 30 de enero; 204/1996, de 16 de diciembre y 249/2005, de 10 de octubre.

⁸ STC 279/1994, de 17 de octubre.

⁹ SSTC 133/2021, de 24 de junio; 25/2022, de 23 de febrero y 8/2024, de 16 de enero.

DERECHO PENAL

TEMA 2

LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. EL SISTEMA CAUSALISTA. EL SISTEMA FINALISTA.
EL CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. CLASES DE
DELITOS. SUJETOS, TIEMPO Y LUGAR DEL DELITO.

LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

- Al estudiar la teoría jurídica del delito, hay que comenzar señalando que la misma tiene por objeto el estudio de los elementos comunes a toda clase de hechos punibles como son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad.
 - En este sentido, su origen histórico se remonta a las aportaciones realizadas durante el Humanismo y la Ilustración por autores como Wolff y Puffendorf. Sin embargo, el concepto moderno de delito surge de las aportaciones de distintos autores que han ido formulando sucesivamente los citados conceptos.
 - Por otro lado, este concepto de delito ha dado lugar a dos principales sistemas como son el sistema causalista y el sistema finalista. En este sentido, la controversia entre ambos sistemas gira en torno al concepto de acción pero encierra consecuencias sistemáticas de primer orden para la configuración de todos los elementos del delito.

EL SISTEMA CAUSALISTA

ETAPA CLÁSICA

- Pasando a ocuparnos del sistema causalista, el mismo engloba dos principales etapas como son la etapa clásica y la etapa neoclásica.
- En este sentido, la etapa clásica, representada por autores como Beling y Von Liszt, se caracteriza por la formulación de un concepto de delito en que sus componentes permanecen estancos de forma que todos los elementos objetivos se sitúan en el campo de la tipicidad y la antijuridicidad y todos los elementos subjetivos se sitúan en el campo de la culpabilidad.
- En cuanto a la **acción**, ésta se concibe en términos exclusivamente naturalísticos como un movimiento corporal que provoca una modificación en el mundo exterior de modo que acción y resultado deben aparecer unidas por un nexo de causalidad que se determina según la teoría de la equivalencia de las condiciones.
 - En este sentido, el concepto de acción es puramente objetivo al distinguir entre el impulso de la voluntad que origina el movimiento corporal y el contenido de la voluntad, que no pertenece al ámbito de la acción sino de la culpabilidad.
 - No obstante, el concepto es criticado ya que no explica los comportamientos omisivos en los que falta la realización de un movimiento corporal ni los comportamientos de los que no se deriva la producción de un resultado.
- En cuanto a la **tipicidad**, el tipo se concibe como una descripción valorativamente neutra de la parte externa de la acción sin comprender elementos normativos como la ajenidad de la cosa en el hurto ni elementos subjetivos como el ánimo de lucro. De este modo, la tipicidad se configura como la simple constatación de que una acción queda subsumida en la descripción de una figura delictiva.
- En cuanto a la **antijuridicidad**, ésta se concibe en términos formales como la oposición entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico entendido en su conjunto.
- En cuanto a la **culpabilidad**, ésta se concibe como una conexión psicológica entre el sujeto y la acción que puede tomar la forma del dolo o la culpa.
 - De este modo, el dolo y la culpa no sólo integran la culpabilidad sino que se confunden con la culpabilidad ya que ésta no engloba otros elementos como la imputabilidad, la exigibilidad de una conducta distinta y la conciencia de la antijuridicidad.
 - No obstante, esta teoría es criticada ya que no explica aquellos comportamientos en que no existe una conexión psicológica entre el sujeto y la acción como los casos de culpa inconsciente, en los que el sujeto no llega a prever la producción del resultado, ni aquéllos en que la conexión psicológica existe pero falta la culpabilidad como cuando se aprecia una causa de exculpación por inexigibilidad de una conducta distinta.

ETAPA NEOCLÁSICA

- En cuanto a la etapa neoclásica, representada por autores como Mezger, ésta se caracteriza por la elaboración de un concepto de delito en el que sus componentes vienen estrechamente ligados entre sí, lo que se manifiesta en la relación entre acción, tipicidad y antijuridicidad.
- En cuanto a la **acción**, ésta deja de definirse en términos puramente naturalísticos y pasa a entenderse como un comportamiento necesariamente voluntario que produce una alteración del mundo exterior.
- De este modo, se intentan superar las críticas formuladas contra la concepción anterior mediante la introducción de un elemento valorativo consistente en el origen de la acción en la voluntad humana de modo que cualquier comportamiento activo u omisivo con o sin resultado, en tanto dependa de la voluntad humana, se considera acción.
- En cuanto a la **tipicidad**, hay que señalar que el tipo deja de concebirse como una descripción valorativamente neutra de la parte externa de la acción y pasa a incluir elementos normativos y elementos subjetivos. De este modo, el tipo se convierte en tipo de injusto al incluir todos los elementos integrantes de la antijuridicidad en relación con cada clase de delito.
- En cuanto a la **antijuridicidad**, ésta deja de concebirse en términos exclusivamente formales y pasa a basarse en criterios materiales como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico con el efecto de que no exista antijuridicidad en los casos en que no hay lesión de intereses.
 - Por otro lado, la etapa neoclásica establece una relación estrecha entre tipicidad y antijuridicidad.
 - De este modo, algunos autores como Mayer conciben al tipo como indicio o *ratio cognoscendi* de la antijuridicidad en tanto no se acredite la existencia de una causa de justificación. Por su parte, otros autores como Mezger identifican ambos elementos convirtiendo al tipo en *ratio essendi* de la antijuridicidad.
- En cuanto a la **culpabilidad**, ésta pasa a concebirse como un juicio de reproche dirigido al autor de una acción típica y antijurídica porque, pudiendo y debido actuar conforme a la norma, opta por realizar la conducta antijurídica.
- De este modo, la culpabilidad adopta una naturaleza normativo-psicológica y se estructura en tres elementos como son la imputabilidad, concebida como capacidad de culpabilidad y que presupone que el sujeto reúne ciertas condiciones biopsíquicas; las formas de la culpabilidad, integradas por el dolo o la culpa y la exigibilidad de una conducta distinta que supone la concurrencia de unas condiciones fácticas que permitían al sujeto actuar conforme a la norma.

SISTEMA FINALISTA

- En cuanto al sistema finalista, representado por Welzel, éste introduce un nuevo concepto de acción que repercute sobre los demás elementos del concepto de delito.
 - De este modo, la acción deja de concebirse de forma puramente objetiva y pasa a estar formada por un elemento objetivo consistente en el curso causal, integrado por el movimiento corporal o su ausencia y el resultado, y un elemento subjetivo integrado por el contenido de la voluntad, sea dolo o culpa.
 - Por otro lado, en la medida en que tipicidad y antijuridicidad constituyen predicados de la acción, también aquéllas pasan a concebirse de modo subjetivo.
 - Finalmente, la culpabilidad culmina el proceso de normativización iniciado en la etapa neoclásica. En efecto, al desplazarse el dolo y la culpa al ámbito de la acción, la culpabilidad queda sólo integrada por elementos normativos como son la imputabilidad, la exigibilidad de una conducta distinta y la conciencia de la antijuridicidad que, en el caso del sistema finalista, no se integra en el dolo ya que éste se concibe como un *dolus naturalis* integrado por el simple conocimiento y voluntad de realizar la conducta descrita por el tipo penal.

EL CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL

- Pasando a ocuparnos del concepto jurídico de delito en el Derecho Penal español, hay que señalar que todos los Códigos Penales españoles han establecido un concepto legal de delito.
 - En este sentido, el art. 1 del Código Penal de 1822 disponía que *comete delito el que libre y voluntariamente y con malicia hace u omite lo que la ley prohíbe o manda bajo alguna pena*. Por su parte, el art. 2 disponía que *comete culpa el que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por alguna causa que puede y debe evitar*.
 - Por su parte, el Código Penal de 1848 dispone que *son delitos o faltas las acciones u omisiones voluntarias penadas por la Ley*. Por otro lado, esta definición se mantiene hasta la reforma del Código Penal de 1983.
- En cuanto al **concepto actual de delito**, el art. 10 del Código Penal de 1995 dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*.
- En relación con este precepto, la doctrina ha puesto de manifiesto que el mismo no engloba todos los elementos del concepto doctrinal del delito sino que debe ser integrado con los arts. 19 y 20 que regulan las causas de justificación y las causas de exclusión de la culpabilidad.
 - De este modo, la acción vendría englobada en la referencia a las *acciones u omisiones* mientras que la tipicidad y la punibilidad se reflejan en la expresión *penadas por la ley*.
 - Por el contrario, el precepto no refleja la antijuridicidad como oposición de la conducta del sujeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, ni la culpabilidad, de la que se alude al dolo y la culpa pero no a la imputabilidad ni la exigibilidad de una conducta distinta.

CLASES DE DELITOS

- Pasando a ocuparnos de las clases de delitos, distinguimos diversos criterios de clasificación.
- En cuanto a su **gravedad**, el art. 13 del Código Penal dispone lo siguiente:
 - 1º. *Son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave.*
 - 2º. *Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave.*
 - 3º. *Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.*
 - 4º. *Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.*
- Por su parte, la jurisprudencia sostiene que los delitos castigados con penas alternativas leves y menos graves se considerarán menos graves aunque la pena impuesta sea leve¹.
- En cuanto al **sujeto activo**, distinguimos entre delitos comunes o especiales según puedan ser cometidos por cualquier persona o exijan una determinada condición.
 - Por su parte, los delitos especiales pueden ser propios o impropios. En este sentido, son delitos especiales propios aquellos que carecen de un delito común correlativo que pueda ser cometido por cualquier persona como es el delito de prevaricación. Por el contrario, son delitos especiales impropios aquéllos que cuentan con un delito común correlativo como el delito contra la inviolabilidad del domicilio cometido por funcionarios en relación con el delito de allanamiento de morada.
 - Por otro lado, son delitos de propia mano aquéllos que exigen una intervención física del autor como son los delitos sexuales o los delitos de falso testimonio.
 - Finalmente, conviene señalar que tanto los delitos especiales propios como los delitos de propia mano excluyen la autoría directa y la autoría mediata de las personas que no reúnan la condición exigida en el tipo o que no hayan desplegado la intervención física exigida pero no impiden la participación en concepto de inducción o complicidad.

- En cuanto a la **conducta típica**, distinguimos entre delitos de acción y delitos de omisión.
 - En cuanto a los **delitos de acción**, éstos se clasifican en delitos de mera actividad y delitos de resultado según el tipo se consume con la mera realización del movimiento corporal o exija la producción de un resultado.
 - Por otro lado, una categoría especial de delitos de resultado viene constituida por los delitos cualificados por el resultado que son aquellos para los que se establece una penalidad agravada en caso de producirse un cierto resultado como son el delito de incendio cuando concurren las circunstancias del art. 353 como que el incendio afecte a una superficie de considerable importancia.
 - En cuanto a los **delitos de omisión**, éstos se clasifican en delitos de omisión propia o impropia según impliquen la simple falta de realización de una conducta o contemplen también la falta de evitación de un resultado.
 - En relación con estos últimos, el art. 11 fija una cláusula específica de incriminación de estos delitos al disponer que *los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto, se equipará la omisión a la acción:*
 - 1º. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
 - 2º. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.
- En cuanto al **grado de afectación del bien jurídico protegido**, distinguimos entre delitos de lesión o de peligro según exijan la producción de un daño efectivo al bien jurídico protegido o la mera probabilidad de un daño.
 - Por su parte, los delitos de peligro pueden ser de peligro concreto o abstracto.
 - En este sentido, son delitos de peligro concreto aquéllos que requieren la creación efectiva de un peligro de lesión inmediata como es el delito de conducción temeraria del art. 380. Por el contrario, son delitos de peligro abstracto aquéllos en que la conducta se presume por sí misma peligrosa sin requerirse aquel peligro de lesión como es el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del art. 379.
- En cuanto al **propósito perseguido por el autor**, distinguimos tres modalidades.
 - En cuanto a los **delitos de intención**, se trata de aquéllos en que el sujeto realiza una conducta para alcanzar un fin posterior y se clasifican en dos modalidades.
 - En efecto, son delitos de resultado cortado aquellos en que el sujeto realiza una conducta con el fin de que se produzca un resultado que no forma parte del tipo penal como el delito de tortura para obtener una confesión del art. 174.
 - Por otro lado, son delitos mutilados en dos actos aquellos en los que el sujeto realiza una conducta con el fin de que se produzca un resultado que exigirá una nueva intervención del sujeto como el delito de posesión de moneda falsa para su distribución o expendición del art. 386.
 - En cuanto a los **delitos de tendencia**, se trata de aquéllos en que el tipo penal incorpora una cierta motivación como sucede con el ánimo de lucro en los delitos patrimoniales.
 - En cuanto a los **delitos de expresión**, se trata de aquellos delitos en los que existe una contradicción entre los que el sujeto sabe y lo que manifiesta como el falso testimonio.
- En cuanto a la **duración de sus efectos sobre el bien jurídico protegido**, distinguimos entre delitos instantáneos como el homicidio; delitos permanentes que suponen la creación de una situación antijurídica duradera y que siguen consumándose mientras la situación permanece como el delito de detención ilegal, y delitos de estado que suponen también la creación de una situación antijurídica duradera pero que se consuman en el momento de su aparición como el delito de falsedad documental.

- En cuanto al **modo de perseguibilidad**, la doctrina distingue entre delitos públicos, privados o semiprivados según sean perseguibles de oficio, mediante querrela o mediante denuncia del ofendido.

SUJETOS DEL DELITO

- Pasando a ocuparnos de los sujetos del delito, nos referiremos a los sujetos activo y pasivo.
- En cuanto al **sujeto activo**, se ha planteado la cuestión de determinar si pueden ser sujeto activo del delito las personas jurídicas.
 - En este sentido, la doctrina moderna ha venido inclinándose por la tesis negativa sobre la base del aforismo *societas delinquere non potest*.
 - No obstante, el art. 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, estableció una regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuyo estudio es materia de otro tema del programa.
- En cuanto al **sujeto pasivo de la acción**, éste viene constituido por el titular del bien jurídico protegido que puede ser una persona física, una persona jurídica o el Estado.
 - En relación con él, hay que señalar que la conducta del sujeto pasivo puede incidir en la responsabilidad penal dando lugar a su exención como sucede con la legítima defensa o a su atenuación como sucede en la atenuante de estímulos poderosos.
 - Del mismo modo, la actividad del sujeto pasivo puede ser necesaria para la realización de delitos como sucede con el auxilio al suicidio y la estafa.

TIEMPO Y LUGAR DEL DELITO

- En cuanto al tiempo y lugar del delito, hay que señalar que existen casos en que la acción y el resultado no se producen en el mismo tiempo y lugar de modo que la determinación del tiempo y el lugar del delito es relevante a efectos de prescripción, retroactividad de la ley penal y competencia de los Tribunales.
- En relación con esta cuestión se han manejado tres posturas doctrinales como son la teoría de la acción que atiende al tiempo y lugar en que se produce la actividad; la teoría del resultado que mantiene la posición opuesta y la teoría de la ubicuidad que considera cometido el delito tanto en el tiempo y lugar en que se desarrolla la actividad aunque sea parcialmente como en el tiempo y lugar en que se produce el resultado.
 - Por su parte, el art. 7 del Código Penal dispone que *a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar*.
 - Finalmente, la jurisprudencia ha optado modernamente por el criterio de la ubicuidad. En efecto, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 declaró que el delito se entenderá cometido en todas las jurisdicciones en que se hubiere producido algún elemento del tipo penal por lo que la competencia corresponderá al Juez de cualquiera de dichas jurisdicciones que primero hubiere iniciado las actuaciones procesales.

¹ STS 31 de mayo de 2017.

DERECHO PENAL

TEMA 3

TIPICIDAD. ESTRUCTURA, CLASES Y FORMULACIÓN DE LOS TIPOS. LA ACCIÓN. LAS TEORÍAS CAUSALES. CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA. EL CRITERIO DE LA JURISPRUDENCIA PENAL.

TIPICIDAD. ESTRUCTURA DE LOS TIPOS

- Al estudiar la tipicidad, hay que comenzar señalando que la teoría jurídica del delito concibe modernamente a éste como una acción típica, antijurídica, culpable y punible.
- En este sentido, la tipicidad constituye uno de los elementos del concepto moderno de delito y se define como *la descripción legal de todos los elementos integrantes del hecho delictivo*.
- En cuanto a la **estructura del tipo**, distinguiremos los sujetos, el objeto y la conducta típica.
 - En cuanto al **sujeto activo**, se trata de la persona que realiza la acción típica.
 - En este sentido, la doctrina tradicional sostuvo que el sujeto activo sólo podía venir constituido por personas físicas conforme al aforismo *societas delinquere non potest*. Sin embargo, la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010 introdujo una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuyo estudio es materia de otro tema del programa.
 - En cuanto al **sujeto pasivo**, se trata del titular del bien jurídico protegido que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica.
 - En este sentido, la doctrina distingue entre el sujeto pasivo y el perjudicado que es la persona que sufre los efectos económicos negativos del delito y que puede resultar relevante a efectos de determinación de la responsabilidad civil derivada del delito.
 - En cuanto al **objeto del tipo**, la doctrina distingue entre objeto material y objeto jurídico.
 - En este sentido, se entiende por objeto material la persona o la cosa en la que recae la acción delictiva y que puede coincidir o no con el sujeto pasivo. Por el contrario, se entiende por objeto jurídico el bien jurídico protegido por el tipo.
 - En cuanto a la **conducta típica**, se trata del núcleo del tipo penal y puede describirse por referencia a los medios comisivos utilizados, al resultado producido o al tiempo o lugar de la acción.

CLASES DE TIPOS

- En cuanto a las clases de tipos, podemos manejar varios criterios de clasificación.
- En cuanto al **sujeto activo**, distinguimos entre delitos comunes o especiales según puedan ser cometidos por cualquier persona o exijan una determinada condición.
 - Por otro lado, son delitos especiales propios aquellos que carecen de un delito común correlativo como es el delito de prevaricación.
 - Por el contrario, son delitos especiales impropios aquéllos que cuentan con un delito común correlativo como el delito contra la inviolabilidad del domicilio cometido por funcionarios en relación con allanamiento de morada.
- En cuanto a la **conducta típica**, distinguimos entre delitos de acción y de omisión.
 - En cuanto a los **delitos de acción**, éstos se clasifican en delitos de mera actividad y delitos de resultado según el tipo se consume con la mera realización del movimiento corporal o exija la producción de un resultado.
 - Por otro lado, una categoría especial de delitos de resultado viene constituida por los delitos cualificados por el resultado que son aquellos para los que se establece una penalidad agravada en caso de producirse un cierto resultado como son el delito de incendio cuando concurren las circunstancias del art. 353 como que el incendio afecte a una superficie de considerable importancia.
 - En cuanto a los **delitos de omisión**, éstos se clasifican en delitos de omisión propia o impropia según impliquen la simple falta de realización de una conducta o contemplen también la falta de evitación de un resultado.

- En relación con estos últimos, el art. 11 fija una cláusula específica de incriminación de estos delitos al disponer que *los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción: 1º Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar; 2º Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.*
- En cuanto al **grado de afectación del bien jurídico protegido**, distinguimos entre delitos de lesión o de peligro según exijan la producción de un daño efectivo al bien jurídico protegido o la mera probabilidad de un daño.
 - Por su parte, los delitos de peligro pueden ser de peligro concreto o abstracto.
 - En este sentido, son delitos de peligro concreto aquéllos que requieren la creación efectiva de un peligro de lesión inmediata como el delito de conducción temeraria del art. 380. Por el contrario, son delitos de peligro abstracto aquéllos en que la conducta se presume por sí misma peligrosa sin requerirse aquel peligro de lesión como el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del art. 379.
- En cuanto a la **duración de sus efectos sobre el bien jurídico protegido**, distinguimos tres modalidades:
 - Primero, delitos instantáneos como el homicidio.
 - Segundo, delitos permanentes que suponen la creación de una situación antijurídica duradera y que siguen consumándose mientras la situación permanece como el delito de detención ilegal.
 - Tercero, delitos de estado que suponen la creación de una situación antijurídica duradera pero que se consuman en el momento de su aparición como el delito de falsedad documental.
- En cuanto a la **conexión entre tipos**, distinguimos entre tipos básicos cuando contienen los elementos esenciales de una figura delictiva, tipos cualificados o agravados cuando dan lugar a una elevación de la pena y tipos atenuados o privilegiados cuando dan lugar a su reducción.

FORMULACIÓN DE LOS TIPOS

- En cuanto a la formulación de los tipos, éstos pueden constar de tres clases de elementos.
 - En cuanto a los **elementos descriptivos**, se trata de aquéllos que señalan una conducta o situación perceptible a través de los sentidos de modo que el intérprete se limita a constatar su existencia como sucede con la muerte de una persona en el homicidio.
 - En cuanto a los **elementos normativos**, se trata de aquéllos que exigen al intérprete un juicio de valor para determinar si concurren en la conducta del sujeto como sucede la ajenidad de la cosa en el delito de hurto.
 - En cuanto a los **elementos subjetivos** se trata de aquéllos que señalan una intención del sujeto como el ánimo de lucro en los delitos patrimoniales que lo exigen.
- En cuanto a las **leyes penales incompletas o leyes penales en blanco**, se trata de aquéllas en que la descripción de la conducta típica o su consecuencia jurídica no se halla plenamente definida por lo que resulta necesario acudir a normas integradoras de rango inferior.
- En relación con ellas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/1990 declaró que las leyes penales en blanco deben reunir tres requisitos como son que el reenvío sea expreso, que esté justificado en razón del bien jurídico protegido y que la ley penal establezca la pena y el núcleo esencial de la prohibición.

LA ACCIÓN

- Pasando a ocuparnos de la acción, hay que señalar que ésta constituye el elemento básico sobre el cual se construye la teoría jurídica del delito.
- En este sentido, la acción surge cuando la resolución criminal se exterioriza, una vez superada la fase interna de ideación, deliberación y resolución previas a la comisión del delito que resultan irrelevantes para el Derecho Penal.
- En cuanto al **concepto de acción**, hay que señalar que la controversia entre los sistemas causalista y finalista gira principalmente en torno al concepto de acción.
 - Sin embargo, en la medida en que la tipicidad y la antijuridicidad son dos predicados de la acción, también la naturaleza de éstas resulta afectada por el contenido que se atribuya a la primera. Del mismo modo, también el contenido de culpabilidad depende de la inclusión o no de elementos subjetivos en el concepto de acción.
 - Por tanto, hay que concluir que el debate entre los sistemas causalista y finalista encierra consecuencias sistemáticas de primer orden para la configuración de todos los elementos del delito.
- En cuanto al **concepto causal de acción**, conviene advertir que la evolución histórica del sistema causalista atraviesa dos etapas como son la etapa clásica y la etapa neoclásica.
 - En cuanto a la **etapa clásica**, representada por autores como Beling y Von Liszt, ésta concibe la acción en términos puramente naturalísticos como un movimiento corporal que provoca una modificación en el mundo exterior de modo que acción y resultado deben aparecer unidas por un nexo de causalidad que se determina según la teoría de la equivalencia de las condiciones.
 - En este sentido, el concepto de acción es puramente objetivo al distinguir entre el impulso de la voluntad que origina el movimiento corporal y el contenido de dicha voluntad, que no pertenece al ámbito de la acción sino de la culpabilidad.
 - No obstante, este concepto es criticado ya que no explica los comportamientos omisivos en los que falta la realización de un movimiento corporal ni tampoco los comportamientos de los que no se deriva la producción de un resultado.
 - En cuanto a la **etapa neoclásica**, representada por autores como Mezger, ésta no concibe la acción en términos puramente naturalísticos sino como un comportamiento necesariamente voluntario que produce una alteración del mundo exterior.
 - De este modo, se intentan superar las críticas formuladas contra la concepción anterior mediante la introducción de un elemento valorativo consistente en el origen de la acción en la voluntad humana de modo que cualquier comportamiento activo u omisivo con o sin resultado, en tanto dependa de la voluntad humana, se considera acción.
- En cuanto al **concepto final de acción**, representado por Welzel, éste deja de concebir a la acción de forma puramente objetiva y pasa a estar formada por un elemento objetivo consistente en el curso causal integrado por el movimiento corporal o su ausencia y el resultado y un elemento subjetivo integrado por el contenido de la voluntad, sea dolo o culpa
- No obstante, también el concepto final de acción ha sido criticado ya que sólo se construye sobre la base de los comportamientos dolosos y, por tanto, no explica suficientemente los comportamientos imprudentes, en los que el objetivo perseguido no coincide con el resultado, ni los comportamientos omisivos, en los que no existe un dominio del curso causal.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ACCIÓN

- En cuanto a las causas de exclusión de la acción, cabe señalar que el Código Penal vigente no contempla estas circunstancias de forma expresa si bien todas se entienden englobadas en la definición de delito del art. 10.

- En cuanto a la **fuerza irresistible**, ésta tiene lugar cuando se aplica en el sujeto una *vis física* absoluta que le obliga o le impide la realización de un movimiento corporal. En este sentido, la jurisprudencia exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
 - Primero, que la fuerza provenga de una causa exógena por lo que no bastarán los estados pasionales o los estados de intoxicación por consumo de alcohol o drogas sin perjuicio de que puedan ser valorados a efectos de excluir o disminuir la culpabilidad.
 - Segundo, que la fuerza sea causada por una persona si bien algunos autores sostienen que también deben incluirse los casos en que la fuerza provenga de hechos naturales.
 - Tercero, que la fuerza sea irresistible en el sentido de producir una anulación completa de la voluntad del sujeto por lo que no bastará la fuerza compulsiva que produzca una mera limitación de esta voluntad sin perjuicio de que puedan ser valorados a efectos de excluir o disminuir la culpabilidad.
- En cuanto a los **movimientos reflejos**, éstos tienen lugar cuando se produce un movimiento corporal no controlado por la voluntad como las convulsiones, los movimientos rotulianos o el cierre reflejo de los ojos causado por un deslumbramiento y que provoca un accidente¹.
- En cuanto a los **estados de plena inconsciencia**, éstos comprenden situaciones con causas patológicas como los trastornos del sueño; situaciones de inconsciencia provocadas por el consumo de sustancias como la embriaguez letárgica y situaciones de hipnosis.
- No obstante, conviene distinguir entre tales estados y las *acciones liberae in causa* que se producen cuando el sujeto se sitúa dolosa o culposamente en un estado de falta de acción o imputabilidad en el cual lleva a cabo la conducta típica.

LAS TEORÍAS CAUSALES

- Pasando a ocuparnos de las teorías causales, hay que señalar que, tratándose de delitos de resultado, la acción y el resultado deben estar unidos por una relación de causalidad. En este sentido, nos referiremos a las principales teorías formuladas sobre la relación de causalidad.
- En cuanto a la **teoría de la equivalencia de las condiciones** o teoría de la *condictio sine qua non*, formulada por Glaser y Von Buri, ésta sostiene que si al suprimir mentalmente la acción desaparece el resultado, entonces debe entenderse que la acción es causa del resultado.
- Por otro lado, esta teoría ha sido criticada sobre la base de los siguientes argumentos:
 - Primero, que incurre en el defecto de identificar causa con condición con el efecto de atribuir a todos los antecedentes de un hecho la misma relevancia penal.
 - Segundo, que no analiza la relación de causalidad de forma directa sino hipotética ya que sólo es posible afirmar que sin acción no se hubiera producido el resultado cuando se conoce la existencia del nexo causal. Sin embargo, si no se conoce el modo de operar de la causa, la mera eliminación mental de la acción no permite determinar si ha tenido influencia en el resultado.
 - Por último, que no ofrece resultados aceptables en los casos de causalidad hipotética en los que el resultado se habría producido por otra causa aunque no hubiera mediado la acción ni tampoco en los casos de causalidad acumulativa en los que el resultado se produce por varias causas simultáneas y con efectividad independiente como sucede en el asesinato de Julio César por veintitrés puñaladas de diversos autores.
- En cuanto a la **teoría de la causalidad adecuada**, ésta sostiene que para los efectos penales, sólo es causa del resultado el antecedente que, conforme a la experiencia, es más probable o razonable que lo produjese.
- En cuanto a la **teoría de la causalidad eficiente**, ésta sostiene que para los efectos penales, sólo es causa del resultado el antecedente más decisivo de éste o, lo que es lo mismo, aquél que tenga fuerza suficiente para producir el resultado sin la concurrencia de otros factores.

CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA

- Pasando a ocuparnos de la causalidad e imputación objetiva, hay que señalar que la relación causal es un problema de índole puramente naturalística y exento de valoraciones normativas.
- Sin embargo, una vez comprobada la existencia de la relación de causalidad, se plantea la cuestión de determinar si el resultado es objetivamente imputable al autor de la acción, ante lo cual surgen las modernas teorías de la imputación objetiva, formuladas por Jescheck y Roxin e introducidas en España por Gimbernat.
 - En este sentido, las modernas teorías de la imputación objetiva parten de la relación de causalidad examinada conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones y tratan de determinar si el resultado causado es objetivamente imputable a su autor, lo que sucederá cuando la acción haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha materializado en el resultado típico.
 - No obstante, la relación de causalidad no siempre es una condición indispensable para la imputación objetiva. En efecto, tratándose de delitos de comisión por omisión, solo es posible afirmar una causalidad hipotética basada en juicios de probabilidad.
- En cuanto a los **requisitos de la imputación objetiva**, distinguimos los siguientes:
 - En primer lugar, será necesario que la acción haya creado o incrementado un riesgo. Por tanto, no habrá imputación objetiva cuando el sujeto haya realizado la acción con el fin de evitar un resultado más grave como sucede con el guardaespaldas que lanza al suelo a la víctima para evitar que sea alcanzada por un proyectil.
 - En segundo lugar, será necesario que el riesgo esté jurídicamente desaprobado. Por tanto, no habrá imputación objetiva cuando la acción no haya creado un riesgo jurídicamente relevante como sucede cuando el sujeto envía al bosque a otra persona en noche de tormenta con la esperanza de que le alcance un rayo para heredarlo.
 - En tercer lugar, será necesario que el riesgo se haya materializado en un resultado que suponga la realización del peligro inherente a la acción. Por tanto, no habrá imputación objetiva cuando el resultado no suponga la realización de dicho peligro como cuando la víctima muere al resbalar en suelo mojado tras ser levemente empujada por el sujeto.
 - Por último, será necesario que el resultado se encuentre en el ámbito de protección de la norma que desaprueba el riesgo creado. Por tanto, no habrá imputación objetiva en casos como un accidente de tráfico acaecido en un adelantamiento antirreglamentario y como consecuencia de un defecto material del vehículo.

EL CRITERIO DE LA JURISPRUDENCIA PENAL

- Pasando a ocuparnos del criterio de la jurisprudencia penal, hay que señalar que el Tribunal Supremo ha seguido tradicionalmente la teoría de la equivalencia de las condiciones aplicando el aforismo *causa causae causa causati est* o, lo que es lo mismo, lo que es causa de la causa es causa del mal causado.
- Sin embargo, la misma jurisprudencia ha elaborado una teoría correctiva de la anterior llamada teoría de la consecuencia natural y del accidente extraño que trata de resolver si la presencia de determinadas circunstancias sobrevenidas o concomitantes en un curso causal puede conducir a la negación de la atribución del resultado al sujeto activo de la acción.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha considerado accidentes extraños el abandono o descuido del herido, la inobservancia del tratamiento curativo prescrito por el facultativo o el propósito de empeorar su propia situación con el fin de perjudicar al procesado.
 - Por el contrario, no se han considerado como tales las concausas preexistentes como el estado de debilidad previo de la víctima; las concausas concomitantes como el terror producido por la agresión ni las concausas posteriores como el no haberse procedido a una intervención quirúrgica.

- Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha empleado en ocasiones las teorías de la causalidad adecuada o de la causalidad eficiente.
- Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene acogiendo desde una Sentencia de 5 de abril de 1983 el concepto de imputación objetiva como criterio de relevancia penal pero partiendo de la relación de causalidad determinada conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones.

¹ STS 11 de mayo de 1977

DERECHO PENAL

TEMA 4

EL DOLO. CLASES DE DOLO. LA DELIMITACIÓN DEL DOLO EVENTUAL DE LA CULPA
CONSCIENTE. LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO.

EL DOLO

- Al estudiar el concepto de dolo, siguiendo a Cuello Calón, podemos comenzar definiéndolo como *la voluntad consciente dirigida a la comisión de un hecho que la ley castiga como delito*.
- En cuanto a su **ubicación sistemática** hay que señalar que su ubicación en la teoría jurídica del delito es distinta según se acoja el sistema causalista o el sistema finalista.
 - En cuanto al **sistema causalista clásico**, representado por autores como Beling y Von Liszt, éste concibe la acción en términos puramente naturalísticos como un movimiento corporal que provoca una modificación en el mundo exterior de modo que la acción y el resultado aparecen unidas por un nexo de causalidad que se determina según la teoría de la equivalencia de las condiciones.
 - Por su parte, la culpabilidad se concibe como una conexión psicológica entre el sujeto y la acción que puede tomar la forma del dolo o la culpa.
 - De este modo, el dolo y la culpa no solo integran la culpabilidad sino que son la culpabilidad misma, que no engloba la conciencia de la antijuridicidad.
 - En cuanto al **sistema causalista neoclásico**, representado por autores como Mezger, éste deja de definir la acción en términos puramente naturalísticos y pasa a concebirla como un comportamiento necesariamente voluntario que produce una alteración del mundo exterior.
 - De este modo, se intentan superar las críticas formuladas contra la concepción anterior mediante la introducción de un elemento valorativo consistente en el origen de la acción en la voluntad humana de modo que cualquier comportamiento activo u omisivo con o sin resultado, en tanto dependa de la voluntad humana, se considera acción.
 - Por su parte, la culpabilidad pasa a concebirse como un juicio de reproche dirigido al autor de una acción típica y antijurídica porque, pudiendo y debido actuar conforme a la norma, opta por realizar la conducta antijurídica.
 - De este modo, la culpabilidad adopta una naturaleza normativo-psicológica y se estructura en tres elementos como son la imputabilidad, concebida como capacidad de culpabilidad y que supone que el sujeto reúne ciertas condiciones biopsíquicas; las formas de la culpabilidad, integradas por el dolo o la culpa y la exigibilidad de una conducta distinta que supone la concurrencia de unas condiciones fácticas que permitan al sujeto actuar conforme a la norma.
 - En cuanto al **sistema finalista**, éste deja de concebir la acción de forma puramente objetiva por lo que pasa a estar formada por un elemento objetivo consistente en el curso causal integrado por el movimiento corporal o su ausencia y el resultado y un elemento subjetivo integrado por el contenido de la voluntad, sea dolo o culpa.
 - De este modo, al desplazarse el dolo y la culpa al ámbito de la acción, la culpabilidad queda solamente integrada por elementos normativos como son la imputabilidad, la exigibilidad de una conducta distinta y la conciencia de la antijuridicidad que, en el caso del sistema finalista, no queda integrada en el dolo.
- En cuanto a los **elementos del dolo**, la doctrina moderna lo concibe como la reunión de un elemento intelectual y un elemento volitivo.

ELEMENTO INTELECTIVO

- En cuanto al elemento intelectual, éste supone una representación mental del hecho por parte de su autor que debe referirse a dos aspectos como son los elementos objetivos del tipo y la significación antijurídica de la acción.

- En cuanto a los **elementos objetivos del tipo**, será necesario que el autor conozca tanto los elementos descriptivos como los elementos normativos y aquellos que puedan determinar una agravación de la pena.
 - No obstante, tratándose de los elementos normativos del tipo, Mezger sostiene que no será exigible el conocimiento propio del especialista sino que bastará que el sujeto realice *una valoración paralela en la esfera del profano*.
 - Por otro lado, tratándose de delitos de resultado, será necesario que el autor conozca los rasgos esenciales del curso causal que su acción puede provocar de modo que no responderá por aquellos resultados que no hubiere previsto a menos que haya actuado con imprudencia.
- Por otro lado, conviene señalar que el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo da lugar al error de tipo. En relación con él, el art. 14 del Código Penal dispone lo siguiente:
 - 1º. *El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.*
 - 2º. *El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación.*
- En cuanto a la **significación antijurídica de la acción**, será necesario que el autor conozca que la acción que realiza se encuentra prohibida por la ley aunque no conozca su calificación jurídica ni la pena prevista. No obstante, conviene recordar que el sistema finalista no incluye este requisito dentro del dolo ya que éste se concibe como un *dolus naturalis* integrado por el simple conocimiento y voluntad de realizar la conducta descrita por el tipo penal.
 - Por otro lado, el desconocimiento de la significación antijurídica de la acción da lugar al error de prohibición.
 - En este sentido, el art. 14.3 dispone que *el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados*.

ELEMENTO VOLITIVO

- En cuanto al elemento volitivo del dolo, éste consiste en la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal aunque no se persigan directamente todas sus consecuencias sino que bastará que éstas se acepten como consecuencia inevitable de la conducta realizada, como sucede en los casos de dolo eventual a los que nos referiremos más adelante.

EL DOLO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL

- En cuanto al concepto del dolo en el Derecho Penal español, hay que señalar que todos los Códigos Penales españoles han establecido un concepto legal del delito pero no han definido el concepto del dolo.
 - En este sentido, el Código Penal de 1822 distinguía entre delitos y culpas. De este modo, el art. 1 disponía que *comete delito el que libre y voluntariamente y con malicia hace u omite lo que la ley prohíbe o manda bajo alguna pena*. Por su parte, el art. 2 disponía que *comete culpa el que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por alguna causa que puede y debe evitar*.
 - Por otro lado, el art. 5 del Código Penal de 1995 dispone *no hay pena sin dolo o imprudencia*. Del mismo modo, el art. 10 dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*.

- Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha concebido tradicionalmente al dolo como la conjunción de los elementos intelectual y volitivo de modo que el primero integraría no sólo el conocimiento de los elementos objetivos del tipo sino también el de la significación antijurídica de la acción¹.
 - Por otro lado, la jurisprudencia ha distinguido el dolo de los móviles del autor ya que el dolo es único e inmediato mientras que los móviles pueden ser múltiples y mediatos como la amistad, la afinidad ideológica o cualquier otro. De este modo, los móviles del autor carecen de relevancia en tanto no se incorporen al tipo de injusto como sucede con el ánimo de lucro en aquellos delitos patrimoniales que lo exigen, sin perjuicio de su valoración a través de las circunstancias atenuantes o agravantes que los recojan².
 - Finalmente, la jurisprudencia ha declarado que el dolo debe quedar probado en todos los casos y sin presunciones derivadas de la mera concurrencia del tipo objetivo.

CLASES DE DOLO

- Pasando a ocuparnos de las clases de dolo, podemos manejar varios criterios de clasificación.
- En cuanto al **objeto**, distinguimos entre dolo determinado y dolo alternativo en función de que el sujeto persiga la realización de un fin concreto o ignore cuál de los posibles tipos legales se realizarán como consecuencia de su acción.
- En cuanto al **momento en que surge**, distinguimos entre dolo inicial y dolo subsiguiente en función de que exista en el momento inicial de la acción o surja posteriormente como sucede en el caso del enfermero que coloca un veneno sobre la mesa del enfermo y, advertido del error, desiste de remediarlo y provoca la muerte del mismo.
- No obstante, conviene advertir que el dolo deberá siempre acompañar a la realización de la conducta típica por lo que el *dolo subsequens* será insuficiente cuando sobrevenga después de la consumación del delito.
- En cuanto al **propósito del autor**, distinguimos entre dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual.
 - En cuanto al **dolo directo de primer grado**, éste tiene lugar cuando el autor persigue directamente la realización del tipo penal con independencia de que la contemple como segura o meramente posible.
 - Por otro lado, tratándose de delitos de resultado, será necesario que el autor persiga también directamente la consecución del resultado previsto en el tipo.
 - En cuanto al **dolo directo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias**, éste tiene lugar cuando el autor no persigue directamente la realización del tipo pero ésta se le representa como consecuencia segura o inevitable de su actuación.
 - De este modo, incurre en dolo directo de segundo grado el que para lesionar a quien se halla tras una ventana, arroja una piedra que producirá daños al romper el cristal.
 - En cuanto al **dolo eventual**, éste tiene lugar cuando el autor no persigue directamente la realización del tipo delictivo ni ésta se le representa como consecuencia segura o inevitable de su actuación pero sí considera seriamente posible la realización del tipo y se conforma con ella o asume sus consecuencias.
 - De este modo, incurre en dolo eventual quien para dejar inconsciente a una persona, inicia su estrangulamiento con una correa sin intención de matarla pero continúa su actuación a sabiendas de que puede causarle la muerte hasta conseguirlo.

LA DELIMITACIÓN ENTRE EL DOLO EVENTUAL Y LA CULPA CONSCIENTE

- Pasando a ocuparnos de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente, hay que señalar que tanto uno como otro exigen que el autor del hecho no persiga la realización del tipo delictivo pero se la representa como posible.
 - En este sentido, la distinción es de la máxima relevancia ya que el dolo eventual lleva aparejada la penalidad característica del delito doloso mientras que la culpa consciente es una modalidad de imprudencia por lo que llevará consigo la imposición de una pena más leve o la impunidad del hecho.
 - En relación con esta cuestión, se han manejado distintas posturas doctrinales como la teoría del consentimiento, la teoría de la probabilidad y la teoría de la conformidad.
- En cuanto a la **teoría del consentimiento**, formulada por Frank, ésta atiende al elemento volitivo del dolo y sostiene que hay dolo eventual cuando el sujeto se representa mentalmente la producción del resultado y aprueba que éste se produzca y culpa consciente, cuando el sujeto se representa la producción del resultado pero confía en que no se produzca.
 - Sin embargo, esta teoría es criticada en la medida que supone calificar una conducta como dolosa siempre que el sujeto apruebe el resultado con independencia del grado de peligrosidad de la conducta.
 - Por tanto, podría existir dolo eventual aunque la conducta sea escasamente peligrosa y existiría culpa consciente aunque la conducta sea extremadamente peligrosa si el sujeto actúa de forma temeraria al confiar en que el resultado no llegue a producirse.
- En cuanto a la **teoría de la probabilidad** formulada por Sauer, ésta atiende al elemento intelectual del dolo y sostiene que hay dolo eventual si el autor reconoce una alta probabilidad de que el resultado se produzca y culpa consciente, cuando el sujeto contempla una escasa probabilidad.
 - Sin embargo, esta teoría es criticada en la medida que supone calificar una conducta como dolosa siempre que exista una alta probabilidad de producción del resultado aunque el sujeto no tuviese intención de provocarlo ni asuma sus consecuencias.
 - Por otro lado, esta teoría impide trazar un límite claro entre dolo eventual y culpa consciente ya ambos dependerían siempre de una representación mental del autor.
- En cuanto a la **teoría de la indiferencia**, formulada por Engisch, ésta sostiene que hay dolo eventual si el sujeto se comporta con indiferencia hacia el bien jurídico cuya lesión se presenta como probable y culpa consciente, cuando considera esta lesión como indeseable.
- En cuanto a la **teoría de la manifestación objetiva**, formulada por Kauffman, ésta sostiene que existirá dolo eventual si el sujeto no emplea medios para prevenir el resultado y culpa consciente en el caso contrario.
- En cuanto a la **posición de la jurisprudencia**, ésta se inclinó tradicionalmente por la teoría del consentimiento por considerar que se trataba de la postura más arraigada en la doctrina y la que conllevaba el menor riesgo de sancionar conductas imprudentes como dolosas³.
 - No obstante, la misma jurisprudencia se ha inclinado por teoría de la probabilidad a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992, relativa al caso de la Colza, en la que se prescinde del elemento volitivo del dolo y se considera suficiente para la apreciación del dolo eventual el conocimiento del peligro concreto de la acción aunque se albergue la esperanza de que el resultado lesivo no llegue a producirse.
 - De este modo, la jurisprudencia ha sancionado como dolo eventual el caso de la mujer que prende fuego a su dormitorio y abandona el domicilio desentendiéndose de su hija menor de edad, que muere asfixiada, ya que existió una representación mental del resultado y era previsible su producción⁴.
 - Finalmente, la misma jurisprudencia ha admitido la existencia de culpa consciente en los casos en que el autor alberga la confianza racional de que el resultado no llegue a producirse siempre que se acredite que tenía controlada la situación de riesgo⁵.

LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO

- Pasando a ocuparnos de los elementos subjetivos del tipo, conviene recordar que la teoría del delito en la época clásica parte de una concepción en la que sus componentes permanecen estancos de modo que todos los elementos objetivos se sitúan en el ámbito de la tipicidad y la antijuridicidad y todos los elementos subjetivos se sitúan en el ámbito de la culpabilidad.
 - En este sentido, el tipo se considera como una descripción valorativamente neutra de la parte externa de la acción sin incluir elementos normativos como la ajeneidad de la cosa en el hurto ni elementos subjetivos como el ánimo de lucro. De este modo, la tipicidad se configura como la mera constatación de que una acción queda subsumida en la descripción de una figura delictiva.
 - Por su parte, la época neoclásica parte de una concepción del delito en la que el tipo deja de concebirse como una descripción valorativamente neutra de la acción y pasa a incluir elementos normativos y elementos subjetivos con lo cual se anticipan al tipo de injusto elementos que venían valorándose en el campo de la culpabilidad.
- En cuanto a la **teoría de los elementos subjetivos del tipo**, ésta es primeramente formulada por Fischer en el ámbito del Derecho Civil y en relación con la teoría del abuso del derecho. De este modo, se afirma que existen supuestos en que una acción lícita deviene ilícita como consecuencia de los fines reprobables que orientan a su autor.
 - Por otro lado, esta teoría es trasladada al ámbito del Derecho Penal por autores como Mezger y Mayer que sostienen que dos conductas externamente idénticas pueden ser lícitas o antijurídicas en función del sentido que el sujeto atribuya al acto.
 - De este modo, Mezger distingue tres clases de delitos con elementos subjetivos como son los delitos de intención, los delitos de tendencia y los delitos de expresión.
- En cuanto a los **delitos de intención**, se trata de aquéllos en que el sujeto realiza una conducta con el fin de alcanzar un fin posterior. Por otro lado, estos delitos se clasifican en delitos de resultado cortado y delitos mutilados en dos actos.
 - En cuanto a los **delitos de resultado cortado**, se trata de aquellos en que el sujeto realiza una conducta con el fin de que se produzca un resultado que no forma parte del tipo penal como el delito de tortura para obtener una confesión del art. 174 o el delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.
 - En efecto, el art. 197 castiga a *el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.*
 - En cuanto a los **delitos mutilados en dos actos**, se trata de aquellos en los que el sujeto realiza una conducta con el fin de que se produzca un resultado que exigirá una nueva intervención del sujeto como el delito de posesión de moneda falsa para su distribución o expendición posterior.
 - En efecto, el art. 386.2 castiga *la tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación.*
- En cuanto a los **delitos de tendencia**, se trata de aquéllos en que el tipo penal incorpora la realización del hecho con una determinada motivación como sucede con el ánimo de lucro en los delitos patrimoniales o con el delito de asesinato por precio, recompensa o promesa o con los delitos en que concurre la circunstancia agravante de móviles discriminatorios.
- En este sentido, el art. 22.4 dispone que es *circunstancia agravante cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurren efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.*

- En cuanto a los **delitos de expresión**, se trata de aquéllos los que existe una contradicción entre los que el sujeto sabe y lo que manifiesta.
- En este sentido, el art. 458 castiga a *el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial*.

CRÍTICA

- En cuanto a la crítica de la teoría de los elementos subjetivos del injusto, la doctrina sostiene que su empleo debe ajustarse a los casos estrictamente necesarios ya que supone conceder una elasticidad excesiva al tipo penal al tiempo que se concede al Juez una discrecionalidad que compromete las exigencias de claridad y taxatividad derivadas del principio de legalidad.

¹ STS 10 de diciembre de 2007

² STS 2 de febrero de 1987

³ STS 27 de marzo de 1990

⁴ STS 30 de octubre de 2008

⁵ STS 8 de octubre de 2010

DERECHO PENAL

TEMA 5

EL DELITO IMPRUDENTE. ELEMENTOS. LA INCRIMINACIÓN DE LA IMPRUDENCIA EN
EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

EL DELITO IMPRUDENTE

- Al estudiar el delito imprudente, podemos comenzar definiéndolo como *la realización de una conducta típica y antijurídica no dolosa pero sí previsible y evitable a causa de la infracción del deber de cuidado personalmente exigible al sujeto*.
 - En relación con la imprudencia, el art. 5 del Código Penal dispone que *no hay pena sin dolo o imprudencia*.
 - Por su parte, el art. 10 que dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*.
- En cuanto al **concepto de la imprudencia**, se han manejado históricamente diversas posturas doctrinales.
 - En cuanto a las teorías tradicionales, representadas por autores como Carrara, éstas definen la imprudencia como *la omisión voluntaria de la diligencia exigible para prever las consecuencias dañosas y previsibles de la actuación de un sujeto*.
 - En este sentido, la imprudencia exigiría la concurrencia de tres requisitos como son la ejecución de un acto voluntario, la previsibilidad del resultado y la falta de previsión del mismo como consecuencia de un vicio de la voluntad del autor.
 - Por su parte, otros autores como Almendingen sostienen que la falta de previsión del resultado no se debe a un vicio de la voluntad sino a un vicio de la inteligencia. De este modo, el castigo de la imprudencia se fundamentaría por la necesidad de amonestar al sujeto para que se abstenga de realizar nuevas conductas culposas, aprendiendo a prever las consecuencias dañosas de su actuación.
 - En cuanto a la teoría integral de Von Liszt, éste exige para el castigo de la imprudencia la concurrencia de tres requisitos:
 - En primer lugar, una falta de precaución para apercibirse de las consecuencias dañosas y previsibles de los propios actos que se determina según la naturaleza del propio acto.
 - En segundo lugar, una falta de previsión del resultado que se determina según la capacidad personal del sujeto.
 - En tercer lugar, una falta de sentido que implica que el sujeto no ha reconocido el significado antisocial del acto a pesar de que pudo hacerlo.
 - En cuanto a la teoría del acto de voluntad, representada por Binding, ésta exige para el castigo de la imprudencia la concurrencia de tres elementos como son la voluntad de realizar el acto peligroso, la previsibilidad y la evitabilidad del resultado.
 - Por su parte, la escuela finalista, representada por Welzel, añade a estos requisitos la infracción del deber de cuidado personalmente exigible al sujeto.

ELEMENTOS

- En cuanto a los elementos de la imprudencia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene que todo delito imprudente deberá reunir cuatro requisitos¹:
 - Primero, la ejecución de un acto consciente y libre.
 - Segundo, la producción de un resultado típico no querido ni consentido por el sujeto por lo que no se sancionará la imprudencia en grado de tentativa.
 - Tercero, la existencia de una relación causal entre la acción y el resultado que permita la imputación objetiva de éste a la conducta del sujeto.
 - Cuarto, la infracción de la norma de cuidado que impone al sujeto el deber de advertir la inminencia y gravedad del peligro y el deber de actuar con la diligencia y prudencia que la situación exige.

- Por otro lado, la misma jurisprudencia sostiene la existencia de dos elementos estructurales de la imprudencia como son el elemento normativo y el elemento psicológico.
- En cuanto al **elemento normativo**, éste consiste en la infracción del deber de cuidado exigible al autor de una conducta peligrosa. En este sentido, distinguimos un deber objetivo y un deber subjetivo de cuidado.
 - En cuanto al **deber objetivo de cuidado**, éste establece la forma en que la conducta peligrosa debería realizarse para evitar la lesión del bien jurídico protegido, teniendo en cuenta el peligro inherente a la acción. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia distinguen un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo².
 - De este modo, se entiende por deber de cuidado interno aquél que impone al sujeto la obligación de examinar las condiciones en que realiza la acción para advertir la inminencia y gravedad del peligro inherente a la misma. Por su parte, el grado de atención exigible dependerá de la proximidad del peligro y del valor del bien jurídico amenazado.
 - Por otro lado, se entiende por deber de cuidado externo aquél que impone al sujeto la obligación de actuar con diligencia y prudencia, evitando las conductas que puedan provocar el resultado lesivo o realizándolas adoptando las medidas de precaución y control necesarias para conjurar o limitar el peligro. Por otra parte, este deber puede derivarse de las máximas de experiencia o de normas jurídicas como las normas reguladoras del tráfico, los reglamentos de policía o las normas de la *lex artis* de determinadas profesiones.
 - En cuanto al **deber subjetivo de cuidado**, éste establece la medida en que el sujeto pudo advertir el peligro inherente a su acción y la medida en que pudo advertir y cumplir el deber objetivo de cuidado. De este modo, el deber subjetivo de cuidado deberá establecerse en función de los conocimientos y circunstancias personales del sujeto.
- En cuanto al **elemento psicológico de la imprudencia**, éste consiste en la previsibilidad y la evitabilidad del resultado.
- En este sentido, la previsibilidad supone la posibilidad de representarse la producción de dicho resultado. Por su parte, la evitabilidad supone la posibilidad de evitar su producción empleando la diligencia adecuada.

LA INCRIMINACIÓN DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

- Pasando a ocuparnos de la incriminación de la imprudencia en el Código Penal español, hay que señalar que el tratamiento de la misma ha atravesado diferentes etapas.
- En cuanto al **Código Penal de 1822**, éste distinguía entre delitos y culpas.
 - En efecto, el art. 1 disponía que *comete delito el que libre y voluntariamente y con malicia hace u omite lo que la ley prohíbe o manda bajo alguna pena*.
 - Por su parte, el art. 2 disponía que *comete culpa el que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por alguna causa que puede y debe evitar*.
- En cuanto al **Código Penal de 1848**, el art. 1 disponía que *es delito o falta toda acción u omisión voluntaria penada por la ley*. Por otro lado, la incriminación de la imprudencia se caracterizaba por tres rasgos:
 - En primer lugar, el castigo de la imprudencia como modalidad de comisión de cualquier delito salvo algunos casos expresamente previstos.
 - En segundo lugar, la regulación específica de la imprudencia como forma de comisión de determinados delitos.
 - En tercer lugar, el establecimiento de una distinción entre imprudencia temeraria e imprudencia simple con o sin infracción de reglamentos.

- En cuanto al **Texto Refundido del Código Penal de 1973**, éste mantiene la definición del Código Penal de 1848 hasta la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/1983 que dispone que *son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley*.
- Por otro lado, la incriminación de la imprudencia experimenta las siguientes modificaciones:
 - Primero, se mantiene el carácter delictivo de la imprudencia temeraria con resultado de daños personales constitutivos de delito o daños materiales que excedieran del seguro obligatorio.
 - Segundo, se despenalizan la imprudencia temeraria con resultado de daños materiales que no excedieran del seguro obligatorio así como la imprudencia simple con resultado de daños materiales.
 - Tercero, se degrada a falta la imprudencia simple con resultado de daños personales.
- Por otro lado, conviene señalar el art. 565 del Código Penal de 1973 que castigaba con pena de prisión menor al que, por imprudencia temeraria, ejecutare un hecho que, si mediare dolo, constituiría delito. Por su parte, el apartado 4 exceptuaba esta regla cuando la pena prevista fuere igual o superior a la prevista para el delito doloso, en cuyo caso los Jueces y Tribunales aplicarían la pena inmediata inferior a esta en el grado que estimaren conveniente.
- En relación con este precepto, se planteó la cuestión de determinar si el Código Penal optaba por un sistema de *crimen culpae*, conforme al cual la imprudencia se configuraba como un tipo autónomo de delito, o un sistema de *crimina culposa*, conforme al cual no existía un delito autónomo de imprudencia sino una pluralidad de delitos realizables imprudentemente.
 - En este sentido, la respuesta a la cuestión era relevante ya que el sistema de *crimen culpae* implicaba que una conducta imprudente con varios resultados daría lugar a la imposición de una sola pena, correspondiente al resultado más grave. Por el contrario, el sistema de *crimina culposa* implicaba la existencia de tantos delitos como resultados se produjeran aplicando las reglas del concurso ideal de delitos.
 - Finalmente, la jurisprudencia se inclinó por la primera de estas tesis mientras que la doctrina mayoritaria se inclinó por la segunda.
- En cuanto al **Código Penal de 1995**, el art. 10 dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley*.
 - Por su parte, el art. 12 que *las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley*.
 - De este modo, el Código Penal de 1995 ha configurado un sistema de *crimina culposa* con arreglo al cual la imprudencia no se considera como un delito autónomo sino como una modalidad de comisión de aquellos delitos expresamente previstos por la ley.

CLASES

- Pasando a ocuparnos de las clases de imprudencia, hay que señalar que el Código Penal de 1995 abandonó la distinción entre imprudencia temeraria e imprudencia simple y la sustituyó por otra nueva distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve, de modo que esta última sólo podía ser constitutiva de falta.
 - Por su parte, la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 ha suprimido definitivamente la regulación de las faltas anteriormente contempladas en el Libro III en aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal y por entender que se trata de asuntos menores que pueden recibir respuesta a través del sistema de sanciones civiles y administrativas.
 - De este modo, la imprudencia leve deja de ser constitutiva de infracción penal mientras que la imprudencia delictiva pasa a clasificarse en imprudencia grave o menos grave.

- En cuanto a la **imprudencia grave o menos grave**, hay que señalar que el Código Penal sólo contempla la imprudencia menos grave en relación con los delitos de homicidio y lesiones.
- Por el contrario, la imprudencia grave se contempla en relación con múltiples delitos como son los de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, daños, receptación, estragos, incendios, delitos contra la salud pública y prevaricación judicial, entre otros.
 - Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que la gravedad de la imprudencia se determinará en función de la intensidad con que aparezcan sus elementos estructurales o, lo que es igual, el elemento normativo constituido por la infracción del deber de cuidado exigible al autor y el elemento psicológico constituido por la previsibilidad y la evitabilidad del resultado³.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia ha declarado que la imprudencia grave supone la omisión de la diligencia mínima exigible a cualquier persona en supuestos en que la conducta es gravemente peligrosa⁴. Por el contrario, la imprudencia leve supone la omisión de la diligencia exigible a una persona cuidadosa si bien cabe recordar que el Código Penal no sanciona actualmente infracciones cometidas por imprudencia leve.
- En cuanto a la **imprudencia en supuestos especiales**, el Código Penal prevé los siguientes:
 - En primer lugar, la imprudencia cometida con vehículos a motor o ciclomotores que lleva consigo la imposición de la pena de privación del derecho a la conducción de este tipo de vehículos.
 - En segundo lugar, la imprudencia cometida con armas de fuego que llevará consigo la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
 - En tercer lugar, la imprudencia profesional que viene configurada como una modalidad de imprudencia grave en relación con determinados delitos como el homicidio, aborto, lesiones y lesiones al feto.
- En relación con la imprudencia profesional, se ha planteado la cuestión de determinar cuál sea el criterio diferenciador que permita distinguir entre ésta y la imprudencia del profesional en el ejercicio de sus funciones.
 - En relación con esta cuestión, la jurisprudencia ha declarado que la imprudencia del profesional consiste en la simple ejecución defectuosa del acto del que se trate.
 - Por el contrario, la imprudencia profesional supone la omisión de los deberes técnicos más elementales del profesional como consecuencia de la ignorancia, el olvido o la falta de actualización de los conocimientos adquiridos o como consecuencia de una dejación inexcusable de la *lex artis*⁵.
- En cuanto a la **culpa consciente e inconsciente**, se entiende por culpa consciente aquella que tiene lugar cuando el sujeto se representa la posibilidad de producción del resultado y por imprudencia inconsciente, la que tiene lugar cuando el sujeto no advierte el peligro inherente a su acción.
- En relación con esta última, se ha planteado la cuestión de determinar cuál sea el criterio diferenciador que permita distinguir entre dolo eventual y culpa consciente si bien su estudio es materia de otro tema del programa.

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA IMPRUDENCIA

- Pasando a ocuparnos de ciertos casos de aplicación de la imprudencia en el Código Penal, nos referiremos al error de tipo vencible, la preterintencionalidad, la concurrencia de conductas culposas y la imprudencia con varios resultados.
- En cuanto al **error de tipo vencible**, el art. 14.1 dispone que *el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente*.

- En relación con este precepto, se han manejado diversas posturas doctrinales:
 - Por un lado, la doctrina mayoritaria sostiene que la expresión *en su caso* del art. 14.1 implica que el error de tipo vencible sólo dará lugar a la incriminación a título de imprudencia en los casos en que el Código Penal sancione la comisión imprudente del delito del que se trate. Por el contrario, en los demás casos, el error de tipo vencible eximiría de responsabilidad criminal.
 - Por su parte, algunos autores sostienen que el art. 14.1 es una norma complementaria del art. 12 de modo que el error de tipo vencible daría lugar a la incriminación a título de imprudencia incluso en los casos en que el Código Penal no prevé expresamente la comisión imprudente del delito.
- En cuanto a la **preterintencionalidad**, ésta tiene lugar en los casos en que el curso causal va más allá de lo deseado por el sujeto como cuando éste golpea a otra persona con el ánimo de herirle y le causa la muerte. En relación con ella, el Texto Refundido del Código Penal de 1973 distinguía dos modalidades de preterintencionalidad:
 - En cuanto a la **preterintencionalidad homogénea**, ésta tenía lugar cuando el resultado producido era de la misma naturaleza que el pretendido en cuyo caso se imponía la pena relativa al resultado más grave con la atenuante de preterintencionalidad.
 - En cuanto a la **preterintencionalidad heterogénea**, ésta tenía lugar cuando el resultado producido era de distinta naturaleza del pretendido en cuyo caso la jurisprudencia apreciaba un concurso entre el delito doloso intentado y delito imprudente consumado.
- Por su parte, el Código Penal de 1995 ha suprimido la atenuante de preterintencionalidad por lo que la doctrina mantiene la posibilidad de aplicar dos soluciones:
 - En primer lugar, la apreciación de un concurso de delitos en los términos señalados siempre que el resultado más grave fuera previsible y evitable y que el delito del que se trate aparezca expresamente tipificado en su modalidad imprudente.
 - En segundo lugar, la apreciación de un error de tipo en relación con el resultado más grave que se resolvería a través del art. 14.1. De este modo, si el error fue invencible, el sujeto quedaría exento de responsabilidad criminal mientras que, si el error fue vencible, se sancionaría el resultado más grave a título de imprudencia siempre que el Código Penal sancione expresamente la comisión imprudente.
- En cuanto a la **concurrency de conductas culposas**, se plantea la cuestión de determinar si la concurrencia de la culpa de la víctima puede compensar la responsabilidad penal del autor.
 - En relación con esta cuestión, la jurisprudencia ha rechazado la compensación de culpas si bien admite la valoración de la eficacia preponderante de la conducta de los diversos sujetos en casos de concurrencia de conductas culposas a fin de degradar e, incluso, excluir la responsabilidad penal del sujeto⁶.
 - Por su parte, el art. 114 del Código Penal dispone que *si la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización*.
- En cuanto a la **imprudencia con varios resultados**, ya hemos señalado que el Código Penal establece un sistema de *crimina culposa* conforme al cual no existe un delito autónomo de imprudencia sino una pluralidad de delitos que pueden cometerse imprudentemente.
 - En este sentido, las acciones imprudentes que produzcan varios resultados darán lugar a tantos delitos como resultados previsibles, evitables y expresamente tipificados se hayan producido.
 - Finalmente, la individualización de la pena se realizará según las normas del concurso ideal de delitos del art. 77.2, que dispone que en estos casos, *se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado*⁷.

PARTICIPACIÓN EN EL DELITO IMPRUDENTE

- En cuanto a la participación en el delito imprudente, algunos autores como Jescheck sostienen que, tratándose de supuestos de culpa inconsciente, no es posible distinguir entre autoría y participación ya que ninguno de los intervinientes tiene el dominio del hecho característico de la autoría.
- Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la existencia de participación en los casos en que se haya producido un acuerdo de voluntades para la realización del acto peligroso pero no para la realización del resultado⁸.

¹ SSTS 26 de marzo de 1994 y 1 de febrero de 2002.

² STS 27 de octubre de 2009.

³ SSTS 27 de marzo de 1989 y 17 de julio de 1995.

⁴ SSTS 29 de noviembre de 2001 y 25 de abril de 2005.

⁵ SSTS 8 de junio de 1994 y 16 de diciembre de 1997.

⁶ SSTS 8 de marzo de 1990 y 22 de febrero de 1992.

⁷ SSTS 10 de octubre de 2000 y 11 de junio de 2001.

⁸ SSTS 17 de febrero de 1976 y 5 de diciembre de 1979

DERECHO PENAL

TEMA 6

EL DELITO DE OMISIÓN. CLASES. LA CLÁUSULA DEL ARTÍCULO 11.

EL DELITO DE OMISIÓN

- Al estudiar el delito de omisión, hay que comenzar señalando el art. 10 del Código Penal que dispone que *son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*.
 - En este sentido, son delitos de acción aquéllos que consisten en la realización de una conducta prohibida y delitos de omisión aquellos que suponen la falta de realización de la conducta esperada o exigida por la ley.
 - Por su parte, los delitos de acción pueden ser de mera actividad o de resultado según el tipo se consume con la mera realización de un movimiento corporal o exijan también la producción de un resultado.

CLASES

- En cuanto a las clases de delitos de omisión, éstos pueden ser de omisión propia o impropia.
- En cuanto a la **diferencia entre ellos**, se han manejado diversas posturas doctrinales entre las cuales destacamos las siguientes:
 - En cuanto a la teoría sustancial de Jescheck, éste sostiene que los delitos de omisión propia se agotan en la simple falta de realización de la conducta esperada por la ley con el fin de evitar la producción de un resultado si bien el resultado no constituye un elemento del tipo penal. De este modo, los delitos de omisión propia vendrían a configurarse como contrapunto de los llamados delitos formales o de simple actividad en los que el tipo se consuma por la mera realización de un movimiento corporal.
 - Por el contrario, los delitos de omisión impropia o comisión por omisión no se agotan en la simple falta de realización de la conducta esperada sino que imponen también a determinadas personas el deber de evitar la producción de un resultado de modo que el resultado constituye un elemento del tipo penal. De este modo, los delitos de omisión impropia vendrían a configurarse como el contrapunto de los llamados delitos materiales o delitos de resultado, en que la consumación del tipo exige la producción de un determinado resultado.
 - En cuanto a la teoría formal de Kaufmann, éste sostiene que el factor diferencial básico entre ambas modalidades de delito radica en que los delitos de omisión propia son expresamente tipificados por la ley mientras que los de omisión impropia son creados por la doctrina y la jurisprudencia partiendo de aquellos delitos de comisión cuyo resultado típico puede también alcanzarse de forma omisiva.
 - No obstante, conviene señalar que también las leyes penales pueden llegar a tipificar delitos de comisión por omisión como sucedería con el delito de omisión de asistencia sanitaria con resultado de riesgo grave para la salud del art. 196 del Código Penal, que castiga a *el profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas*.
 - Del mismo modo, cabe señalar el delito de omisión de restablecimiento de la seguridad de la vía con resultado de riesgo grave para la circulación del art. 385 que castiga a *el que originare un grave riesgo para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo*.
 - En cuanto a la teoría formal de Baumann, ésta sostiene que el factor diferencial básico entre ambas modalidades de delito radica en que los delitos de omisión propia infringen una norma preceptiva que impone la obligación de actuar mientras que los de omisión impropia infringen una norma prohibitiva que prohíbe la causación del resultado.

DELITOS DE OMISIÓN PROPIA

- Pasando a ocuparnos de los delitos de omisión propia, el Código Penal contempla diversos supuestos como son siguientes:
 - Primero, el art. 189.6 castiga a *el que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.*
 - Segundo, el art. 195.1 castiga a *el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.*
 - Tercero, el art. 408 castiga a *la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.*
 - Cuarto, el art. 450 castiga a *el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual.*
- En cuanto a la **estructura de estos delitos**, la doctrina exige los siguientes elementos:
 - En primer lugar, será necesaria la concurrencia de una situación típica como sería la existencia de una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave en el delito de omisión del deber de socorro.
 - En segundo lugar, será necesaria la falta de realización de la conducta esperada.
 - No obstante, conviene señalar que el deber de realización de esta conducta no llega a nacer cuando la misma puede crear o aumentar una situación de riesgo para el omitente o para un tercero.
 - De este modo, algunos autores como Sáinz Cantero consideran el riesgo propio o de tercero como una causa de exculpación por inexigibilidad de una conducta distinta mientras que otros autores como Rodríguez Mourullo sostienen que se trata de una causa de justificación.
 - En tercer lugar, será necesaria una capacidad real de actuación del sujeto que se determinará en función de las circunstancias objetivas de la situación de que se trate y de las posibilidades subjetivas de actuación del individuo y que puede traducirse en una ayuda personal o en la petición de ayuda a terceros.
 - En relación con este requisito, hay que señalar que la creencia del sujeto de su falta de capacidad para realizar la conducta esperada podrá dar lugar a la aplicación de un error de tipo del art. 14.
 - En efecto, el mismo dispone que *el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación.*
 - Por último, será necesaria la conciencia de la situación típica y la decisión de no actuar.
 - En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene la posibilidad de apreciar estos delitos tanto con dolo directo como con dolo eventual¹.
 - No obstante, será irrelevante la actitud subjetiva del omitente en cuanto a la producción del resultado lesivo ya que éste no forma parte del tipo penal.

DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIA

- Pasando a ocuparnos de los delitos de omisión impropia, ya hemos señalado que éstos no se agotan en la simple falta de realización de la conducta esperada por la ley sino que implican también la falta de evitación de un resultado.
- En este sentido, nos referiremos al problema de la causalidad y la delimitación del sujeto activo.

EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD

- En cuanto al problema de la causalidad, hay que señalar que todo delito de resultado exige la concurrencia de una relación de causalidad entre acción y resultado.
 - Sin embargo, cuando el comportamiento del sujeto no consiste en una acción sino en una omisión, la relación de causalidad no puede establecerse desde un punto de vista naturalístico o material ya que una omisión no origina ningún curso causal sino que se limita a no modificar un curso causal ya iniciado.
 - En este sentido, la doctrina recurre al establecimiento de una relación de causalidad hipotética basada en la aplicación de la teoría de la *condictio sine qua non* de modo que si introducida mentalmente en el curso causal la conducta esperada del omitente, el resultado no se hubiera producido con una probabilidad rayana en la seguridad, entonces la omisión es causa del resultado.
- Por otro lado, una vez establecida la relación de causalidad, se plantea la cuestión de determinar si el resultado producido es objetivamente imputable a la omisión del sujeto ante lo cual surgen las modernas teorías de la imputación objetiva.
 - De este modo, siguiendo a Jescheck, cabe señalar que el resultado será objetivamente imputable al sujeto cuando la acción haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se haya materializado en el resultado típico.
 - Sin embargo, tratándose de delitos de omisión, será necesario que la conducta del sujeto no haya reducido el riesgo existente para el bien jurídico y que este riesgo se haya materializado en un resultado que suponga la realización del peligro que el omitente estaba obligado a contrarrestar.

DELIMITACIÓN DEL SUJETO ACTIVO

- En cuanto a la delimitación del sujeto activo del delito, hay que señalar que no todo sujeto que no evita la producción del resultado puede ser castigado como autor de un delito de comisión por omisión sino sólo aquéllos que se encuentran en una posición de garantía respecto al bien jurídico puesto en peligro.
- En este sentido, se plantea la cuestión de determinar cuáles sean las fuentes de las que nace esta posición de garantía, para lo cual se han manejado dos posturas doctrinales como son la teoría formal del deber jurídico y la teoría material de las funciones.
- En cuanto a la **teoría formal del deber jurídico**, representada por autores como Welzel, ésta sostiene que la posición de garante puede originarse en las siguientes fuentes:
 - Primero, una disposición legal.
 - Segundo, una asunción voluntaria como la que se produce a través de un contrato.
 - Tercero, un actuar precedente de modo que quien origina una situación de peligro para un bien jurídico estaría obligado a evitar que el peligro origine una lesión.

- En cuanto a la **teoría material de las funciones**, representada por autores como Jescheck, ésta sostiene que la posición de garante corresponde a aquellos sujetos que tienen a su cargo una función de protección de ciertos bienes jurídicos o una función de control de una fuente de peligro.
 - En cuanto a las **funciones de protección de bienes jurídicos**, éstas pueden originarse por situaciones como las siguientes:
 - En primer lugar, situaciones de dependencia de unas personas respecto de otras basadas en vinculaciones familiares como sucede con los hijos respecto de sus padres o con los cónyuges entre sí. En este sentido, los arts. 67 y 68 del Código Civil establecen el deber de socorro mutuo entre los cónyuges y el art. 154 establece el deber de los padres de velar por los hijos sometidos a la patria potestad.
 - En segundo lugar, comunidades de riesgo libremente asumidas como sucede entre los integrantes de un grupo de alpinistas en el que cada uno de ellos es garante de los demás. Sin embargo, no existirá posición de garante si la comunidad de riesgo no fue asumida libremente como sucede con las víctimas de un naufragio o terremoto.
 - En tercer lugar, situaciones de asunción voluntaria de la posición de garante como sucede en el caso del socorrista en la piscina, el guía alpino o el médico. En este sentido, la jurisprudencia ha declarado la existencia de esta posición de garante en supuestos como el del personal de colegios u otros establecimientos que asumen la custodia de menores en ausencia de sus padres².
 - Por último, situaciones derivadas de deberes jurídicos estatales como sucede en el caso de la Administración penitenciaria en relación con las personas recluidas en centros penitenciarios o en centros de detención.
 - En cuanto a las **funciones de control de una fuente de peligro**, éstas pueden originarse por las siguientes situaciones:
 - En primer lugar, situaciones de control de animales, instalaciones o maquinarias peligrosas como sucede en el caso de los dueños de animales o el guardaguasas encargado de evitar la colisión entre los trenes.
 - En segundo lugar, situaciones de control de la actuación de un tercero como sucede en el caso de los sujetos que tienen a su cargo a personas inimputables como son los titulares o encargados de establecimientos psiquiátricos.
 - En tercer lugar, situaciones de previa realización de una conducta peligrosa.
 - En relación con este último supuesto, se ha planteado la cuestión de determinar bajo qué condiciones pueda sancionarse la no evitación del resultado por parte del autor de una previa conducta peligrosa:
 - En este sentido, algunos autores sostienen que la omisión impropia se castigará tanto si la conducta peligrosa se realizó culposamente como si lo fue fortuitamente. De este modo, el conductor que atropella a un peatón y omite socorrerlo causándole la muerte responderá tanto si el atropello fue culposo como si fue fortuito.
 - Por el contrario, otros autores sostienen que la omisión impropia se castigará sólo si la previa conducta del sujeto hubiera sido antijurídica. De este modo, el conductor que respeta las normas de circulación no se convierte en garante respecto a la víctima de un accidente ni tampoco el que actúa en legítima defensa se situaría en posición de garante respecto al agredido.

PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIA

- En cuanto a la participación en los delitos de omisión impropia, se ha planteado la cuestión de determinar si el omitente que se halla en posición de garante responderá siempre en concepto de autor o puede hacerlo también en concepto de partícipe.
 - En este sentido, algunos autores sostienen que no es posible distinguir entre autoría y participación en los delitos de omisión impropia por lo que el garante responderá en concepto de autor aunque el resultado típico sea causado activamente por otro.
 - Por el contrario, otros autores sostienen que el garante responderá en este caso en concepto de partícipe ya que no tiene el dominio del hecho necesario para la autoría si bien sólo podrá responder como cooperador pero no como inductor.

DELITOS DE OMISIÓN POR HACER

- En cuanto a los delitos de omisión por hacer, se trata de una categoría formulada por la doctrina para englobar ciertos supuestos en los que el omitente responde por la causación del resultado como si lo hubiera producido activamente como en el caso del guardaguasas que se embriaga voluntariamente para imposibilitarse para realizar el cambio de agujas y provocar el choque de trenes o en el caso del inductor que, sin estar en posición de garante, convence a quien sí lo está para que no actúe en cuyo caso respondería como inductor del delito de comisión por omisión.

LA CLÁUSULA DEL ARTÍCULO 11

- Pasando a ocuparnos de la cláusula del art. 11 del Código Penal, hay que señalar que la jurisprudencia admitió tradicionalmente la punición de los delitos de comisión por omisión pese a la falta de un precepto legal que lo autorizara expresamente.
- Por su parte, el art. 11 del Código Penal de 1995 introdujo una cláusula de incriminación de los delitos de comisión por omisión al disponer que *los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto, se equipará la omisión a la acción:*
 - 1º. *Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.*
 - 2º. *Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.*
- En cuanto a los **requisitos del precepto**, éste exige dos elementos como son la equivalencia entre acción y omisión según el sentido de la ley y la infracción de un especial deber jurídico del autor o, lo que es lo mismo, que éste se halle constituido en posición de garante.
 - En cuanto a la equivalencia entre acción y omisión, la doctrina sostiene que ésta no concurrirá en el caso de aquellos delitos en que el verbo empleado en la descripción de la conducta típica exprese una conducta necesariamente activa como sucede con el delito de violación del art. 179.
 - En cuanto a la posición de garantía, hay que señalar que el legislador se ha inclinado por la teoría formal del deber jurídico al configurar la posición de garante sobre la base de una obligación legal o contractual de actuar o de una conducta precedente.
 - Por otro lado, el legislador ha acogido también la llamada teoría de la injerencia al admitir la previa conducta precedente del sujeto como fuente de la posición de garante. Sin embargo, el art. 11 no aclara si la previa conducta del sujeto deberá ser antijurídica o bastará que sea culpable o fortuita en los términos señalados anteriormente.

- En cuanto a las **fuentes de la posición de garantía**, distinguiremos entre cada una de las dos fuentes establecidas por el art. 11.
 - En cuanto al *deber legal o contractual de actuar*, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la existencia de posición de garantía en supuestos como el de la muerte por inanición de un menor dejado por su madre en situación de abandono³ o en el del matrimonio conocedor de las agresiones sexuales de un tercero sobre su hijo y que no impide su continuación⁴.
 - Del mismo modo, se ha apreciado la existencia de posición de garante en el caso del matrimonio de testigos de Jehová que no convencieron a su hijo de trece años para aceptar una transfusión de sangre como único tratamiento para mantenerlo con vida⁵.
 - En cuanto a la *creación previa de una situación de riesgo*, la misma jurisprudencia ha declarado la posición de garantía en el caso del autor de una violación cuya víctima se arrojó al vacío por una ventana para tratar de escapar⁶ o en el caso del autor de una agresión física a su esposa que la abandona sin prestarle asistencia hasta su fallecimiento⁷.

¹ STS 5 de junio de 2012

² STS 1 de diciembre de 2000.

³ STS 30 de junio de 1988.

⁴ STS 10 de octubre de 2006.

⁵ STS 27 de junio de 1997, anulada por la STC 154/2002, de 18 de julio.

⁶ STS 9 de mayo de 2011.

⁷ STS 19 de julio de 1999.

DERECHO PENAL

TEMA 7

ANTI JURIDICIDAD. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. LEGÍTIMA DEFENSA. ESTADO DE NECESIDAD. OBRAR EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO.

ANTI JURIDICIDAD

- Al estudiar el concepto de antijuridicidad, hay que comenzar señalando que la teoría jurídica del delito concibe modernamente a éste como una acción típica, antijurídica, culpable y punible.
- De este modo, la antijuridicidad constituye uno de los elementos del concepto moderno de delito y se define como *la contraposición entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico concebido en su conjunto*.
 - En este sentido, la doctrina moderna sostiene que una conducta es antijurídica cuando lesiona o pone en peligro cualquiera de los bienes jurídicos amparados por el Estado salvo que se encuentre amparada por una causa de justificación.
 - Por otro lado, la doctrina distingue entre antijuridicidad en sentido formal y en sentido material. De este modo, la antijuridicidad formal supone la mera contraposición entre la conducta del sujeto y los mandatos y prohibiciones establecidos por la norma. Por su parte, la antijuridicidad material supone la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y constituye un parámetro para la definición e interpretación de los tipos penales y para la graduación de las penas por parte del Juez.

LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

- Pasando a ocuparnos de las causas de justificación, se trata de todas aquéllas circunstancias que excluyen la antijuridicidad de una conducta que reúne los elementos de un tipo penal.
- En cuanto a su **fundamento**, la doctrina sostiene que todas ellas presuponen la existencia de un conflicto de intereses y tienen por fin proteger aquel interés que el ordenamiento jurídico considera preponderante.
- En cuanto a sus **clases**, distinguimos entre causas de justificación generales y especiales.
 - En este sentido, son causas de justificación generales las recogidas en el art. 20 del Código Penal como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
 - Por el contrario, son causas de justificación especiales aquéllas que afectan a delitos concretos como son el riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada en el delito de aborto y el riesgo propio o ajeno en el delito de omisión del deber de socorro.
- Por otro lado, la doctrina distingue entre causas de justificación penales que son las recogidas en el Código Penal y causas de justificación extrapenales que son las recogidas en otras normas y se incorporan al catálogo del art. 20 a través de la eximente de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo como sucede con las diligencias de entrada y registro domiciliario o la intervención de las comunicaciones.
- En cuanto a sus **efectos**, distinguimos los siguientes:
 - En primer lugar, no podrá oponerse legítima defensa a quien actúa amparado por una causa de justificación al no existir una verdadera agresión ilegítima.
 - En segundo lugar, tampoco podrá exigirse responsabilidad penal a quien participa como inductor, cómplice o cooperador necesario en un hecho amparado por una causa de justificación. Sin embargo, podrá apreciarse la autoría mediata como sucede en el caso del superior jerárquico que ordena a un subordinado ejecutar una conducta típica para que éste último se beneficie de la eximente de cumplimiento de un deber.
 - En tercer lugar, tampoco cabe imponer medidas de seguridad a quien actúa amparado por una causa de justificación ya que el presupuesto de las mismas es la comisión de un hecho legalmente previsto como delito.
 - Por último, las causas de justificación excluyen la responsabilidad civil salvo en el caso del estado de necesidad en los términos del art. 118.

LEGÍTIMA DEFENSA

- Pasando a ocuparnos de la legítima defensa, el art. 20.4 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurren los requisitos siguientes:*
 - *Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o éstas.*
 - *Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.*
 - *Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.*
- En cuanto a su **fundamento**, algunos autores como Rodríguez Devesa sostuvieron que la legítima defensa se fundamenta en la falta de protección estatal al agredido que provocaría una especie de delegación tácita del Estado en el defensor.
- Por el contrario, la doctrina moderna y la jurisprudencia sostienen que la legítima defensa se basa en dos tipos de razones como son la necesidad de proteger el bien jurídico atacado por una agresión ilegítima y la necesidad de garantizar la primacía del Derecho frente al injusto¹.
- En cuanto a los **bienes protegidos por la legítima defensa**, el art. 20.4 se refiere al que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos por lo que distinguiremos entre bienes personales y bienes materiales.
 - En cuanto a los **bienes personales**, hay que señalar que la legítima defensa ampara toda clase de bienes como la vida, la integridad, la libertad, el honor, el patrimonio y los derechos familiares.
 - No obstante, la jurisprudencia ha admitido la legítima defensa frente a ataques contra el honor siempre que los insultos hagan prever una situación de riesgo inminente para la integridad física².
 - En cuanto a los **bienes materiales**, la jurisprudencia ha venido aplicando una restricción ética para los casos de grave desproporción entre el mal causado y el que se trata de evitar³. De este modo, no cabría legítima defensa en el caso de la persona que da muerte a un ladrón para evitar la comisión de un hurto de escasa cuantía.

AGRESIÓN ILEGÍTIMA

- En cuanto a la agresión ilegítima, se trata del elemento básico de la legítima defensa ya que su ausencia impide la apreciación de una eximente completa o incompleta a diferencia de los otros dos requisitos, cuya ausencia no impide la apreciación de una eximente incompleta.
- En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que la agresión ilegítima deberá ser real; actual o inminente y antijurídica.
- En cuanto al **carácter real de la agresión**, será necesario que ésta implique la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico sin que basten actitudes meramente intimidatorias que no vayan acompañadas de un peligro de lesión inmediato⁴.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha negado la existencia de agresión ilegítima en hechos como de exigir explicaciones o imprecar verbalmente a otra persona⁵.
 - Por otro lado, puede suceder que el sujeto se crea erróneamente víctima de una agresión ilegítima dando lugar a la legítima defensa putativa que constituye un error de prohibición inverso por falta de conciencia del autor del hecho sobre la significación antijurídica de la acción.

- En cuanto al **carácter actual o inminente de la agresión**, hay que señalar que no cabe la legítima defensa preventiva en tanto no se haya presentado la situación de ataque inminente⁶.
 - Por otro lado, tampoco cabe la legítima defensa contra agresiones acabadas en cuyo caso no procederá la apreciación de la eximente completa ni incompleta.
 - No obstante, el Juez podrá valorar el estado de ofuscación que la agresión haya causado a la víctima a efectos de apreciación de la circunstancia atenuante del art. 21.3⁷.
- En cuanto al **carácter ilegítimo de la agresión**, será necesario que ésta sea antijurídica en el sentido de lesionar o poner en peligro un bien jurídico.
 - En este sentido, no podrá oponerse legítima defensa a quien actúe amparado en una causa de justificación como el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
 - Por otro lado, será necesario que la agresión ilegítima provenga de actos humanos aunque se trate de niños, enfermos mentales o personas que actúen por imprudencia o error. De este modo, no cabe la legítima defensa frente a las agresiones de animales a menos que sean impulsados por el hombre y sin perjuicio de que pueda apreciarse el estado de necesidad.

NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO

- En cuanto a la necesidad racional del medio empleado, la doctrina sostuvo tradicionalmente que este requisito equivalía a una exigencia de proporcionalidad entre la agresión ilegítima y el medio empleado para impedirla o repelerla.
 - Por el contrario, la jurisprudencia sostiene actualmente que la necesidad racional del medio empleado debe valorarse desde el punto de vista objetivo y subjetivo⁸ teniendo en cuenta la relación personal entre los contendientes⁹, la entidad del ataque y del bien jurídico atacado¹⁰ y los medios disponibles para el agredido.
 - De este modo, el agredido deberá optar siempre por el medio menos lesivo entre los que se encuentren a su alcance y siempre que sean suficientes para impedir o repeler la agresión¹¹. No obstante, la misma jurisprudencia sostiene que la legítima defensa no se excluye en los casos en que el defensor tenga la posibilidad de huir o escapar¹².
- En cuanto al **exceso en la defensa**, el mismo se produce cuando el defensor sobrepasa el límite de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión en cuyo caso procederá la apreciación de una eximente incompleta.

FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE

- En cuanto a la falta de provocación suficiente, la jurisprudencia ha declarado que no podrá apreciarse la eximente completa cuando el defensor haya realizado cualquier incitación u hostigamiento que hubiera llevado a la mayoría de las personas a una reacción agresiva¹³.
 - Por otro lado, tratándose de riñas mutuamente aceptadas, la jurisprudencia tradicional sostiene que existe mutua provocación por lo que ninguno de los contendientes podrá alegar agresión ilegítima¹⁴.
 - Sin embargo, la misma jurisprudencia sostiene que podrá apreciarse legítima defensa cuando uno de los contendientes hubiese iniciado la riña y el otro se hubiese limitado a repeler la agresión¹⁵ o cuando uno de los contendientes acepta el desafío por temor a pasar por cobarde¹⁶ o cuando uno sobrepasa los límites tácitamente aceptados al hacer uso de ataques descomedidos o armas peligrosas con que no se contaba¹⁷.

ELEMENTO SUBJETIVO

- En cuanto al elemento subjetivo de la legítima defensa, será necesario que el sujeto actúe a impulsos del *animus defensionis* por lo que no podrá invocar legítima defensa quien actúe con otros móviles distintos.
- No obstante, la jurisprudencia sostiene que el *animus defensionis* es compatible con otros ánimos concurrentes como el *animus necandi* o propósito de dar muerte al agresor¹⁸.

ESTADO DE NECESIDAD

- Pasando a ocuparnos del estado de necesidad, el art. 20.5 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurren los siguientes requisitos:*
 - *Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.*
 - *Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto.*
 - *Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.*
- En cuanto a la **situación de necesidad**, la jurisprudencia exige los siguientes requisitos:
 - En primer lugar, el mal que se pretende evitar deberá ser real ya que, de lo contrario, estaríamos ante un estado de necesidad putativo que se resolvería de acuerdo con la teoría del error en los términos señalados para la legítima defensa.
 - En segundo lugar, el mal deberá ser actual o inminente sin que baste la probabilidad más o menos remota de sufrir el mal.
 - En tercer lugar, el mal deberá ser de igual o mayor gravedad que el mal causado. Sin embargo, si el mal causado fuere del mismo valor que el mal que se pretendía evitar, la doctrina y la jurisprudencia sostienen que estaríamos ante una causa de exculpación por inexigibilidad de otra conducta distinta¹⁹.
 - En cuarto lugar, será necesario que el sujeto haya agotado todos los medios lícitos o menos gravosos disponibles para eludir el mal.
 - Por último, será necesario también que el sujeto actúe a impulsos de un *animus conservationis* por lo que la concurrencia de un ánimo distinto impediría la apreciación de la eximente u obligaría a apreciarla únicamente como incompleta.
- Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido aplicando la eximente en casos como el aborto consentido por una mujer²⁰, la mediación en un secuestro por banda armada²¹ o la aplicación de transfusiones a Testigos de Jehová que se negaban a admitirlas²².
- Por otro lado, la jurisprudencia también ha aplicado el estado de necesidad al llamado hurto famélico siempre que concurren los siguientes requisitos²³:
 - Primero, que el sujeto actúe hallándose en un estado de precariedad o indigencia que exceda de la mera estrechez económica.
 - Segundo, que el sujeto haya agotado las demás soluciones posibles en la esfera personal, familiar o profesional sin que baste la mera situación de paro laboral sin otras connotaciones.
 - Tercero, que los efectos sustraídos sean aplicados a la satisfacción de las necesidades primarias del reo o de su familia y sin que se haya tomado más de lo estrictamente indispensable.

- En cuanto a la **falta de provocación intencionada**, ésta implica que no podrá invocar la eximente quien hubiere provocado intencionalmente la situación de necesidad.
- Sin embargo, la eximente podrá ser invocada cuando la situación de necesidad haya sido provocada culposamente sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la imprudencia.
- En cuanto a la **falta de obligación de sacrificio**, hay que señalar que determinadas personas pueden tener un deber especial de afrontar riesgos que otras personas no deben asumir como sucede con el bombero en relación con los riesgos derivados de un incendio; el médico en relación con el riesgo de contagio o los miembros de la tripulación de una aeronave en caso de siniestro.
 - En este sentido, será indiferente que el oficio o cargo sea público o privado de modo que los términos de la obligación vendrán determinados por las normas reguladoras de la profesión u oficio de que se trate.
 - Por otro lado, no podrá ampararse en esta eximente quien lesiona un bien jurídico o infrinja un deber para evitar un mal al obligado a sacrificarse.

OBRAR EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER

- Pasando a ocuparnos del cumplimiento de un deber, el art. 20.7 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia distingue tres requisitos básicos cuya ausencia impide la apreciación de la eximente completa o incompleta como son los siguientes²⁴:
 - Primero, que el sujeto sea una autoridad o funcionario público legalmente autorizado a hacer uso de medios violentos en el ejercicio de su cargo.
 - Segundo, que el delito se haya cometido en el ejercicio de las funciones del cargo sin que sea necesaria una previa agresión ilegítima.
 - Tercero, que sea necesario el uso de la violencia para el cumplimiento de la función de que se trate.
- Por otro lado, la misma jurisprudencia distingue dos requisitos accesorios cuya ausencia no impedirá la apreciación de la eximente incompleta como son los siguientes:
 - Primero, que el medio empleado sea el menos peligroso según las circunstancias del caso y las posibilidades de actuación del agente.
 - Segundo, que la violencia utilizada sea proporcionada a la situación que ha originado la intervención de la fuerza pública.

EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO

- En cuanto al ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, la jurisprudencia ha admitido su aplicación en casos como los siguientes:
 - En primer lugar, la provocación de lesiones con motivo de la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos siempre que el paciente haya prestado consentimiento informado y a menos que el médico haya actuado con impericia.
 - En segundo lugar, la provocación de lesiones con motivo de la práctica de deportes violentos siempre que se observen las reglas de la actividad deportiva. No obstante, el art. 83 de la Ley del Deporte de 1990 dispone que los órganos disciplinarios deportivos comunicarán al Ministerio Fiscal las infracciones que puedan revestir caracteres de delito.

- En tercer lugar, la realización de imputaciones por parte de Abogados en el ejercicio de su profesión cuando pudieran ser constitutivas de delito en el caso de realizarse al margen de la misma. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que los límites de la libertad de expresión de los Abogados son más amplios cuando se trata de afirmaciones o expresiones utilizadas en el ejercicio del derecho de defensa y que puedan afectar al honor ajeno²⁵.
- Por último, el uso de armas por agentes de la autoridad. En este sentido, el art. 5 de la Ley Orgánica 5/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo autoriza cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de los agentes u otras personas o un riesgo grave para la seguridad ciudadana.
- Por otro lado, se ha planteado la cuestión de determinar si existe un derecho de corrección paterna que legitime el uso de la violencia como en el caso del padre que propina a su hijo un cachete, un azote o un estirón de pelo.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que el derecho de corrección paterna sigue existiendo como facultad inherente a la patria potestad tras la reforma del art. 154 del Código Civil aprobada por la Ley 13/2005, que suprimió la regla de que los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos.
 - No obstante, este derecho debe ejercitarse conforme a principios de proporcionalidad, razonabilidad y moderación por lo que no ampara actos violentos que causen lesiones en el sentido de requerir una primera asistencia facultativa. Por su parte, el resto de conductas deberán analizarse según las circunstancias y las que no superen los límites del derecho de corrección no tendrán consecuencias penales ni civiles²⁶.

-
- ¹ STS 13 de marzo de 2000.
- ² ATS 18 de julio de 2007.
- ³ STS 21 de junio de 2007.
- ⁴ SSTS 7 de abril de 1993 y 6 de octubre de 1993.
- ⁵ SSTS 23 de marzo de 1990 y 26 de mayo de 1989.
- ⁶ STS 18 de julio de 2007.
- ⁷ STS 4 de junio de 2007 y 14 de junio de 2011.
- ⁸ STS 16 de diciembre de 1991.
- ⁹ STS 7 de octubre de 1988.
- ¹⁰ STS 6 de junio de 1989.
- ¹¹ SSTS 29 de mayo de 2009 y 9 de abril de 2010.
- ¹² SSTS 5 de mayo de 2009 y 21 de junio de 2007.
- ¹³ STS 17 de octubre de 1989.
- ¹⁴ SSTS 29 de enero de 2000 y 16 de febrero de 2001.
- ¹⁵ STS 22 de mayo de 1993.
- ¹⁶ STS 18 de noviembre de 1987.
- ¹⁷ STS 26 de octubre de 2005.
- ¹⁸ STS 12 de mayo de 2004 y 22 de abril de 2010.
- ¹⁹ SSTS 28 de septiembre de 1989 y 20 de marzo de 1991.
- ²⁰ STS 11 de diciembre de 1990.
- ²¹ STS 5 de diciembre de 1994.
- ²² ATS 14 de marzo de 1979.
- ²³ STS 21 de enero de 1986.
- ²⁴ SSTS 19 de junio de 1988 y 1 de diciembre de 1999.
- ²⁵ STC 299/2006, de 23 de octubre.
- ²⁶ SSTS 8 de enero de 2020 y 11 de febrero de 2020.

DERECHO PENAL

TEMA 8

IMPUTABILIDAD, CULPABILIDAD Y CAUSAS QUE LAS EXCLUYEN. ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA. INTOXICACIÓN PLENA. ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN. LA MENOR EDAD. MIEDO INSUPERABLE.

LA CULPABILIDAD

- Al estudiar la imputabilidad, la culpabilidad y las causas que las excluyen, podemos comenzar definiendo la culpabilidad como *el juicio de reproche dirigido personalmente al autor de una acción típica y antijurídica porque, pudiendo y debiendo actuar conforme a la norma, opta por comportarse en contra de ella*.
- En relación con ella, hay que señalar que los ordenamientos penales primitivos establecen sistemas de responsabilidad objetiva en los que la imposición de una pena se produce por la mera causación de un resultado lesivo con independencia de la culpabilidad del autor. Por el contrario, los ordenamientos penales modernos se basan en el principio de culpabilidad que se traduce en los siguientes principios:
 - Primero, el principio de personalidad de las penas conforme al cual la responsabilidad penal sólo será exigible a personas concretas y por sus actos propios sin que pueda admitirse una responsabilidad colectiva extensible al grupo familiar o social.
 - Segundo, el principio de responsabilidad subjetiva conforme al cual la responsabilidad penal sólo será exigible por los hechos causados por dolo o imprudencia pero no por los producidos fortuitamente.
 - Tercero, el principio de graduación de la pena conforme a la culpabilidad del autor.
 - Por último, el principio de responsabilidad por el hecho conforme al cual el Derecho Penal no castiga la personalidad o la pertenencia del sujeto a determinados grupos ya que ello daría lugar a un Derecho Penal de autor. No obstante, ello no impide que la personalidad del sujeto se valore en aspectos como la apreciación de su imputabilidad o la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Por otro lado, este principio supone también que el Derecho Penal no castiga las fases de ideación, deliberación y resolución previa a la comisión de un delito sino que será necesario que la resolución criminal se exteriorice para que tenga lugar la acción represora.

NATURALEZA JURÍDICA

- En cuanto a la naturaleza de la culpabilidad, se han mantenido históricamente varias posturas.
- En cuanto a la **concepción psicológica**, correspondiente a la escuela causalista clásica y representada por autores como Beling y Von Liszt, ésta concibe la culpabilidad como una conexión psicológica entre el sujeto y la acción que puede tomar la forma del dolo o la culpa.
 - De este modo, el dolo y la culpa no sólo integran la culpabilidad sino que se confunden con la culpabilidad ya que ésta no engloba otros elementos como la imputabilidad, la exigibilidad de una conducta distinta y la conciencia de la antijuridicidad.
 - No obstante, esta teoría es criticada ya que no explica aquellos comportamientos en que no existe una conexión psicológica entre el sujeto y la acción como los casos de culpa inconsciente, en los que el sujeto no llega a prever la producción del resultado, ni aquéllos en que la conexión psicológica existe pero falta la culpabilidad como cuando se aprecia una causa de exculpación por inexigibilidad de una conducta distinta.
- En cuanto a la **concepción normativo-psicológica**, correspondiente a la escuela causalista neoclásica y representada por autores como Mezger, ésta concibe la culpabilidad como un juicio de reproche dirigido al autor de una acción típica y antijurídica porque, pudiendo y debido actuar conforme a la norma, opta por realizar la conducta contraria a ella.
- De este modo, la culpabilidad pasa a estructurarse sobre la base de tres elementos como son la imputabilidad, concebida como capacidad de culpabilidad y que presupone que el sujeto reúne unas ciertas condiciones biopsíquicas; las formas de la culpabilidad, integradas por el dolo o la culpa y la exigibilidad de una conducta distinta que supone la concurrencia de unas condiciones fácticas que permitan al sujeto actuar conforme a la norma.

- En cuanto a la **concepción estrictamente normativa**, correspondiente a la escuela finalista y representada por autores como Welzel, ésta parte de la afirmación de que la diferencia entre la acción humana y los procesos naturales reside en que el hombre se fija objetivos y prevé las consecuencias de su actuación.
 - Por tanto, la acción deja de concebirse de forma meramente objetiva y pasa a estar formada por un elemento objetivo consistente en el proceso causal integrado por el movimiento corporal o su ausencia y el resultado y un elemento subjetivo consistente en el contenido de la voluntad, es decir, el dolo o la culpa.
 - De este modo, al desplazarse el dolo y la culpa al ámbito de la acción, la culpabilidad queda exclusivamente integrada por elementos normativos como son la imputabilidad, la exigibilidad de una conducta distinta y la conciencia de la antijuridicidad que, en el caso del sistema finalista, no se integra en el dolo ya que éste se concibe como un *dolus naturalis* integrado por el simple conocimiento y voluntad de realizar la conducta descrita por el tipo penal

LA IMPUTABILIDAD

- En cuanto a la imputabilidad, podemos definirla como *la capacidad del sujeto para comprender la significación antijurídica de los propios actos y actuar conforme a esa comprensión*.
- En este sentido, el Derecho Penal no analiza la concurrencia de la imputabilidad de forma positiva sino que la deduce de la falta de cualquiera de las causas que la excluyen.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD

- En cuanto a las causas de exclusión de la culpabilidad, distinguimos dos modalidades como son las causas de inimputabilidad y las causas de exculpación.
- En cuanto a las **causas de inimputabilidad**, éstas tienen lugar cuando el sujeto no reúne las condiciones biopsíquicas precisas para comprender la significación antijurídica de sus propios actos y actuar conforme a esa comprensión.
- En este sentido, son causas de inimputabilidad las anomalías o alteraciones psíquicas, la intoxicación plena y las alteraciones en la percepción. Por su parte, la minoría de dieciséis años deja de concebirse como causa de inimputabilidad en el Código Penal de 1995.
- En cuanto a las **causas de exculpación**, éstas tienen lugar cuando el legislador exime de responsabilidad penal a una persona capaz e imputable por no concurrir aquellas condiciones fácticas que le permitirían actuar conforme a la norma.
- En este sentido, el Código Penal contempla como tales el miedo insuperable y el estado de necesidad exculpante, una vez suprimidas la fuerza irresistible y la obediencia debida.

ANOMALÍA PSÍQUICA

- En cuanto a las anomalías y alteraciones psíquicas, el art. 20.1 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión*.
- En este sentido, las anomalías psíquicas pueden adoptar cuatro modalidades como son las oligofrenias, las psicosis, las psicopatías y las neurosis.

- En cuanto a las **oligofrenias**, se trata de anomalías caracterizadas por el retraso mental o la disminución de la capacidad intelectual del sujeto.
 - En este sentido, la jurisprudencia distingue en función de la intensidad de la anomalía entre la oligofrenia profunda, cuando el coeficiente de inteligencia no excede de 25; la oligofrenia media, cuando este coeficiente no excede de 70; y la oligofrenia leve o simple torpeza mental, cuando este coeficiente se sitúa entre 70 y 80¹.
 - Por otro lado, la jurisprudencia sostiene que el oligofrénico es generalmente inimputable en los dos primeros casos y generalmente imputable en el tercero sin perjuicio de apreciar una imputabilidad disminuida en función de las circunstancias del caso y del grado de facilidad para comprender la ilicitud del hecho².
- En cuanto a las **psicosis**, se trata de las anomalías psíquicas más graves y que comprenden la esquizofrenia, la paranoia, el trastorno maniaco-depresivo y la epilepsia.
 - En este sentido, la jurisprudencia contempla la apreciación de una eximente completa, una eximente incompleta o una atenuante analógica en función de la intensidad de los síntomas y del grado de alteración de las facultades mentales del sujeto al tiempo de realizar la acción y teniendo en cuenta si el delito se cometió en estados crepusculares o en intervalos lúcidos.
 - En este sentido, la jurisprudencia aprecia la eximente completa en los casos de delitos cometidos durante un brote psicótico, delitos relacionados con las ideas delirantes del sujeto³ o delitos cometidos en un estado de intensa alteración de facultades mentales por el consumo de alcohol o drogas aunque no se acredite el brote psicótico⁴.
- En cuanto a las **psicopatías**, se trata de anomalías sin incidencia en las facultades intelectivas o volitivas del sujeto pero sí sobre su afectividad.
 - En este sentido, la jurisprudencia se mostró tradicionalmente contraria a considerarlas patologías mentales por entender que se trataba de atipias caracterológicas graves o especiales maneras de ser⁵.
 - Por su parte, la jurisprudencia reciente mantiene la excepcionalidad de la exención o la atenuación de la responsabilidad penal y sostiene que sólo se apreciará la eximente completa en casos graves y cuando concurren con otras patologías o con el consumo de sustancias tóxicas.
- En cuanto a las **neurosis**, se trata de anomalías psíquicas más leves que las anteriores.
 - En relación con ellas, la jurisprudencia ha declarado que las neurosis no anulan por si solas la imputabilidad del sujeto si bien podrán dar lugar a una eximente incompleta o una atenuante analógica en los casos más graves⁶.
 - No obstante, la misma jurisprudencia ha contemplado la apreciación de una eximente completa, una eximente incompleta o una atenuante analógica en el caso de ludopatía cuando el sujeto actúa con un deseo irrefrenable de participar en el juego que le lleva a cometer actos dirigidos a proveerse de dinero⁷. Sin embargo, los trastornos del estímulo sexual como la pedofilia no afectan a la imputabilidad salvo que vengán acompañados de otras anomalías o trastornos psíquicos⁸.
- En cuanto al **trastorno mental transitorio**, se trata de un supuesto de perturbación de las facultades mentales caracterizado por su duración limitada.
 - En este sentido, será necesaria su aparición brusca; su duración breve sin dejar secuelas; la anulación de las facultades intelectivas o volitivas del sujeto y que el trastorno no sea provocado por el propio sujeto dando lugar a las llamadas *acciones liberae in causa*, que tienen lugar cuando el sujeto se sitúa dolosa o culposamente en un estado de falta de acción o de imputabilidad en el que realiza la conducta típica.
 - En relación con ellas, ya hemos señalado el art 20.1 que dispone que *el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión*.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

- En cuanto a las consecuencias jurídicas de las anomalías y alteraciones psíquicas, éstas llevarán consigo la exención o atenuación de la responsabilidad penal.
 - No obstante, el art. 101 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un centro adecuado al tipo de anomalía o alteración que se aprecie en cuyo caso no podrán abandonar el establecimiento sin autorización del órgano sentenciador.
 - Por otra parte, el art. 118.1 dispone que *son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.*

INTOXICACIÓN PLENA

- Pasando a ocuparnos de la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia, el art. 20.2 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.*
- En relación con este precepto, cabe señalar que el consumo de drogas y bebidas alcohólicas puede incidir en la imputabilidad del sujeto de cuatro formas:
 - En primer lugar, el art. 20.2 permite apreciar una eximente completa cuando el delito se comete en un estado de inimputabilidad total provocado por el consumo de drogas o bebidas alcohólicas o por el síndrome de abstinencia derivado de la interrupción brusca del consumo o del tratamiento deshabitador.
 - En segundo lugar, el art. 21.1 permite apreciar una eximente incompleta cuando el delito se comete en un estado de semiimputabilidad provocado por las mismas causas o, lo que es igual, cuando se produce una perturbación profunda pero no completa de las facultades del sujeto que no le impide apreciar la antijuridicidad del hecho.
 - En tercer lugar, el art. 21.2 permite apreciar una atenuante genérica cuando el sujeto comete el delito *a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2º del artículo anterior.* De este modo, se contemplan los supuestos en que la disminución de imputabilidad no proviene de la intoxicación o síndrome de abstinencia sino de un estado de adicción.
 - En cuarto lugar, el art. 21.7 permite apreciar una atenuante analógica en los supuestos de escasa incidencia en las facultades del sujeto como en los de mero abuso de la sustancia o adicciones de menor intensidad o antigüedad.
- En cuanto a la **intoxicación plena**, la jurisprudencia ha declarado que la apreciación de una eximente completa exigirá que la perturbación de facultades del sujeto sea plena y fortuita.
- Por otro lado, la jurisprudencia contempla la apreciación de una eximente incompleta en casos en que la perturbación es fortuita pero no plena y si es plena pero no fortuita como sucede con las *acciones liberae in causa*.
- En cuanto al **síndrome de abstinencia**, la jurisprudencia sostiene que éste podrá dar lugar a la aplicación de una eximente completa, una eximente incompleta o una atenuante analógica en función de la intensidad de la alteración de las facultades mentales del sujeto.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

- En cuanto a las consecuencias jurídicas de la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia, éstas llevarán consigo la exención o atenuación de la responsabilidad penal.
 - Por otro lado, el art. 102 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad criminal por intoxicación plena o síndrome de abstinencia se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado u homologado.
 - En relación con la responsabilidad civil, el art. 118 dispone que *son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado*.

ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN

- Pasando a ocuparnos de las alteraciones en la percepción, el art. 20.3 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia sostiene que el rasgo esencial de la eximente consiste en la falta de aptitudes del sujeto para desenvolverse en la convivencia social debido al estado de incomunicación en que ha permanecido desde el nacimiento o la infancia con independencia de que ésta se deba a limitaciones sensoriales o anomalías del carácter.
 - Por otro lado, será necesario que estas alteraciones se produzcan desde el nacimiento o desde la infancia por lo que la ausencia de este requisito impide la apreciación de la eximente completa o incompleta⁹.
 - Finalmente, la jurisprudencia solamente ha aplicado la eximente completa en casos de sordomudez¹⁰. Del mismo modo, la jurisprudencia ha aplicado la atenuante analógica en casos de déficits de socialización por marginación social.¹¹
- En cuanto a sus **consecuencias jurídicas**, éstas se traducen principalmente la exención de responsabilidad penal.
 - Por otro lado, el art. 103 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad criminal por alteraciones en la percepción se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento en centro educativo especial en cuyo caso no podrán abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.
 - Finalmente, el art. 118 regula la responsabilidad civil en los términos señalados para la eximente de anomalía o alteración psíquica.

LA MENOR EDAD

- Pasando a ocuparnos de la menor edad, el art. 19 dispone que *los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula la responsabilidad penal del menor*.
 - En relación con este precepto, hay que señalar que el Código Penal no declara inimputables a los menores de dieciocho años pero eleva hasta dicha edad la exención de responsabilidad penal con arreglo al Código al tiempo que se modifica la situación anterior en la que la minoría de dieciséis y dieciocho años se contemplaban como eximente y atenuante respectivamente.
 - Por su parte, el art. 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000, sobre Responsabilidad Penal de los Menores dispone que *esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales*.

EL MIEDO INSUPERABLE

- En cuanto al miedo insuperable, el art. 20.6 dispone que *está exento de responsabilidad criminal el que obre impulsado por miedo insuperable*.
- En relación con esta circunstancia, la doctrina mayoritaria sostiene que se trata de una causa de exculpación por inexigibilidad de una conducta distinta si bien algunos autores se han mostrado partidarios de considerarla como causa de inimputabilidad o de justificación.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia distingue los siguientes¹²:
 - En primer lugar, la existencia de un terror determinante de la anulación de la voluntad del sujeto.
 - En segundo lugar, la necesidad de que el terror sea insuperable en el sentido de que no pueda ser dominado por la generalidad de las personas y sin considerar a personas especialmente valerosas o temerarias o especialmente pusilánimes o miedosas.
 - En tercer lugar, que el terror esté inspirado en un hecho real y acreditado.
 - En tercer lugar, que el miedo sea el único móvil de la acción.
- En cuanto a sus **consecuencias jurídicas**, éstas se traducen principalmente la exención de responsabilidad penal.
- En relación con la responsabilidad civil, el art. 118 dispone que *responderán principalmente los que hayan causado el miedo y, en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho*.

¹ SSTS 22 de septiembre de 2003 y 21 de octubre de 2009.

² SSTS 4 de diciembre de 1989, 13 de diciembre de 1994 y 3 de junio de 2004.

³ STS 29 de junio de 2000.

⁴ STS 7 de marzo de 2010.

⁵ STS 2 de noviembre de 1983 y 10 de octubre de 1984.

⁶ STS 20 de septiembre de 1993.

⁷ STS 29 de octubre de 2001.

⁸ SSTS 30 de septiembre de 2010 y 18 de enero de 2017.

⁹ STS 6 de febrero de 2001.

¹⁰ STS 23 de diciembre de 1992.

¹¹ STS 2 de marzo de 2005.

¹² STS 19 de julio de 1994.

DERECHO PENAL

TEMA 9

TEORÍA DEL ERROR EN DERECHO PENAL. CLASES DE ERROR. CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

TEORÍA DEL ERROR EN EL DERECHO PENAL

- Al estudiar la teoría del error en el Derecho Penal, podemos comenzar definiéndolo como *una ignorancia o falso conocimiento del autor del hecho delictivo acerca de alguno de los elementos objetivos del tipo de injusto o de la significación antijurídica de la acción*.
 - En relación con él, hay que señalar que el error afecta a la existencia del dolo ya que supone la falta de alguno de los requisitos integrantes de su elemento intelectual, que viene constituido por la representación mental del autor del hecho sobre los elementos objetivos del tipo y la significación antijurídica de su acción.
 - Por otra parte, hay que señalar que la teoría del error es el campo de la teoría jurídica del delito en el que más intensamente se manifiestan las consecuencias sistemáticas de optar por un concepto causal o un concepto final de acción tal como expondremos más adelante.

CLASES DE ERROR

- En cuanto a las clases de error, podemos manejar distintos criterios de clasificación.
- En cuanto al **error propio e impropio**, se entiende por error propio aquél que surge durante las fases de ideación, deliberación y resolución previas a la ejecución del delito y que afecta al proceso de formación de la voluntad. Por el contrario, se entiende por error impropio aquél que surge durante la fase de ejecución del delito y en el cual se distinguen diversas modalidades a las que nos referiremos al término de esta exposición.
- En cuanto al **error directo e inverso**, se entiende por error directo aquél que surge cuando el autor cree erróneamente en la inexistencia de algún elemento del delito que sí concurre en la realidad y por error inverso, aquél que surge cuando el autor cree erróneamente la existencia de algún elemento del delito que no concurre en la realidad.
- En cuanto al **error vencible e invencible**, se entiende por error vencible aquél que hubiera podido evitarse empleando la diligencia adecuada a las circunstancias del caso y del autor y por error invencible, el que no hubiera podido evitarse ni empleando la máxima diligencia.
- En cuanto al **error de hecho y de Derecho**, se entiende por error de hecho o *error facti* aquél que recae en los elementos fácticos de un delito y por error de Derecho o *error iuris* aquél que afecta al conocimiento de la norma jurídica.
 - En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se esforzó tradicionalmente por establecer criterios claros de distinción entre ambas figuras al tiempo que reconoció la eficacia exculpatória del error de hecho pero no del error de Derecho al considerar indispensable el mantenimiento de una presunción de conocimiento de las normas como medio para preservar su imperio.
 - En este sentido, el art. 6.1 del Código Civil dispone que *la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen*.
- En cuanto al **error de tipo y de prohibición**, se trata de un criterio de distinción introducido por la doctrina alemana y que sirve actualmente como base para la solución de los problemas del error.
 - De este modo, se entiende por error de tipo aquél que afecta al conocimiento de los elementos objetivos del tipo de injusto como sucede en el caso del cazador que dispara contra un hombre creyendo que se trata de una pieza cinegética.
 - Por el contrario, se entiende por error de prohibición el que afecta al conocimiento de la significación antijurídica de la acción como sucede en el caso del cazador extranjero que dispara a una pieza cinegética ignorando que su caza está prohibida en España.

- En relación con estas clases de error, hay que señalar que sus consecuencias jurídicas son distintas según se acoja el sistema causalista o el sistema finalista.
 - En efecto, el sistema causalista sitúa el dolo en el ámbito de la culpabilidad y engloba en el mismo tanto el conocimiento de los elementos objetivos del delito como de la significación antijurídica de la acción. De este modo, tanto el error de tipo como el error de prohibición afectan a la culpabilidad.
 - Por su parte, el sistema finalista sitúa el dolo en el ámbito de la acción típica y engloba en el mismo el conocimiento de los elementos objetivos del delito y del resultado mientras que la conciencia de la antijuridicidad se sitúa en el ámbito de la culpabilidad. Por tanto, el error de tipo afecta a la tipicidad mientras que el error de prohibición afecta a la culpabilidad.
- Por otro lado, la doctrina distingue entre el error inverso de tipo que equivale a la tentativa inidónea y el error inverso de prohibición que equivale al delito putativo.
 - En este sentido, la tentativa inidónea o error inverso de tipo supone una ignorancia o falso conocimiento acerca de la existencia de alguno de los elementos del tipo que no concurre en la realidad como cuando una persona oculta al funcionario de aduanas un reloj que considera valioso pero que, en realidad, es una falsificación.
 - Por su parte, el delito putativo o error inverso de prohibición supone una ignorancia o falso conocimiento acerca de la significación antijurídica de la acción como cuando una persona oculta al funcionario de aduanas un reloj valioso en el caso de que los relojes hubieran sido suprimidos de la lista de productos gravados.
- En cuanto al **error sobre los presupuestos de una causa de justificación**, éste tiene lugar cuando el sujeto sabe que la conducta que realiza se encuentra prohibida por la ley pero cree que está amparada por una causa de justificación como sucede en los siguientes casos:
 - En primer lugar, cuando el autor cree erróneamente en la existencia de una causa de justificación que el Derecho Positivo no admite.
 - En segundo lugar, cuando el autor cree erróneamente en la existencia de todos los elementos de una causa de justificación, dando lugar a las causas de justificación putativas, como cuando una persona se cree erróneamente atacada por otra y repele la agresión dando muerte al supuesto agresor en cuyo caso nos encontraríamos ante un caso de legítima defensa putativa por falta de agresión ilegítima.
- Por otro lado, se ha planteado la cuestión de determinar si el error sobre los presupuestos de una causa de justificación constituye error de tipo o error de prohibición.
 - En relación con esta cuestión, la teoría de los elementos negativos del tipo se inclina por la primera tesis al considerar que los presupuestos de las causas de justificación se integran en la tipicidad de modo que el delito de homicidio no consistiría sólo en matar a otro, sino en hacerlo en una situación en la que el sujeto no resulte amparado por una causa de justificación.
 - Por su parte, la jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por considerar el error sobre los presupuestos de las causas de justificación como error de prohibición si bien conviene advertir que existen resoluciones en ambos sentidos¹.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

- Pasando a ocuparnos de las consecuencias jurídicas del error, cabe señalar que el Derecho Penal español carecía de una regulación sobre la materia hasta la reforma del Código Penal de 1973 operada por la Ley Orgánica 8/1983 que introduce la distinción entre error de tipo y error de prohibición.

- En este sentido, la regulación de las consecuencias jurídicas del error supone una plasmación del principio de culpabilidad con arreglo al cual no procede la imposición de una pena cuando el hecho no resulta reprochable personalmente a su autor.
- De este modo, la regulación jurídica del error se opone al principio medieval *versari in re illicita* conforme al cual el autor de una conducta respondía de cualquier resultado derivado de la misma por la mera circunstancia de estar causalmente vinculado con ella aunque el resultado no hubiera sido previsto ni previsible al tiempo de la ejecución de la acción.

ERROR DE TIPO

- En cuanto a las consecuencias del error de tipo, distinguiremos según recaiga en elementos esenciales o elementos accidentales del tipo penal.
- En cuanto al **error sobre elementos esenciales**, se trata de aquél que recae sobre alguno de los elementos objetivos que configuran el tipo básico de cada figura delictiva.
 - En relación con él, el art. 14.1 dispone que *el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.*
 - Por tanto, tratándose de un error invencible, el sujeto quedará exento de pena. Sin embargo, tratándose de un error vencible, habrá que entender que el error es debido a la imprudencia del autor por lo que la infracción será castigada a título de imprudencia siempre que la modalidad imprudente del delito esté castigada por la ley y, en caso contrario, el hecho quedará impune.
- En cuanto al **error sobre elementos accidentales**, se trata de aquél que recae en elementos que pueden ocasionar la agravación o atenuación de la pena.
 - En cuanto al **error sobre circunstancias agravantes**, la agravación puede provenir tanto de la concurrencia de una agravante genérica del art. 22 como de la infracción de un subtipo agravado.
 - En este sentido, el art. 14.2 dispone que *el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá su apreciación.* De este modo, el error impedirá en todo caso la apreciación de la circunstancia agravante aunque se trate de un error vencible.
 - Por otro lado, conviene señalar que esta misma solución se desprende del art. 65.2 que dispone que *las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.*
 - En cuanto al **error sobre circunstancias atenuantes**, la atenuación puede provenir tanto de la concurrencia de una atenuante genérica del art. 21 como de la infracción de un subtipo privilegiado.
 - En relación con este supuesto, hay que señalar que el art. 14 no contempla una norma específica. No obstante, tratándose de atenuantes genéricas, la doctrina sostiene que éstas no necesitan ser conocidas por el culpable sino que podrán ser apreciadas de oficio por el juzgador.
 - Sin embargo, tratándose de subtipos privilegiados, algunos autores sostuvieron que el error sobre los mismos determinaría la aplicación del tipo básico de la figura delictiva en cuestión. Por su parte, otros autores como Mir Puig defienden la aplicación del subtipo privilegiado ya que lo contrario supondría imponer la pena correspondiente a un tipo distinto del que concurre en el caso concreto.

ERROR DE PROHIBICIÓN

- En cuanto a las consecuencias del error de prohibición, ya hemos señalado que éste tiene lugar cuando el sujeto ignora que la conducta que realiza se encuentra prohibida por la ley.
- En este sentido, el art. 14.3 del Código Penal dispone que *el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.*
 - En relación con este precepto, algunos autores sostienen que el mismo acoge una concepción finalista del delito conforme a la cual el dolo exige el conocimiento del autor sobre los elementos objetivos del tipo pero no sobre la significación antijurídica de su acción. De este modo, el error vencible de prohibición no impediría la existencia del dolo, por lo que la infracción se castiga con la pena inferior en uno o dos grados.
 - Por el contrario, otros autores como Mir Puig se han opuesto a esta teoría al entender que el error vencible de prohibición impide la existencia del dolo y debería dar lugar en todo caso a la comisión imprudente de modo que la reducción de pena tendría por finalidad evitar la impunidad de aquellos delitos que no admiten la comisión a título de imprudencia.
- En cuanto al **error de prohibición en la jurisprudencia**, distinguimos los siguientes aspectos:
 - En primer lugar, la jurisprudencia ha rechazado el error de prohibición cuando el actor duda sobre la significación antijurídica de su conducta y, sin embargo, decide actuar y también cuando el sujeto se coloca en una situación de ignorancia deliberada de lo que puede y debe saber o cuando no muestra un conocimiento equivocado sino una mera indiferencia².
 - En segundo lugar, la misma jurisprudencia ha rechazado la apreciación del error de prohibición cuando se trata de infracciones de carácter natural que lesionan normas éticas necesarias para la convivencia y cuya ilicitud es notoria para cualquier persona. De este modo, se ha rechazado la existencia de error de prohibición en casos como el de la persona que acudió al domicilio de otra para amenazarla si no retiraba una denuncia o el del esposo que realizó el acceso carnal venciendo la oposición de su esposa o el de quien transportaba hachís por la aduana.
 - En tercer lugar, tratándose de delitos formales y de creación artificial, la jurisprudencia ha declarado que deberán tenerse en cuenta las condiciones psicológicas y culturales del sujeto además de las posibilidades que hubiese tenido para apercebirse de la significación antijurídica de su conducta.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha apreciado el error de prohibición invencible en casos como la persona que abandonó una mesa electoral antes de tiempo³ o en el de la persona que adquirió armas de guerra creyendo que se trataba de bienes de libre posesión⁴.
 - Por el contrario, la jurisprudencia ha rechazado el error de prohibición en casos como el de personas que contaron con asesoramiento técnico sobre el carácter ilícito de su conducta⁵. De igual modo, la jurisprudencia ha rechazado el error de prohibición en casos de mutilación genital por entender que el respeto a las culturas y tradiciones tiene como límite el respeto a los derechos humanos que operan como denominador común a todas las culturas, tradiciones y religiones⁶.
 - En cuarto lugar, la jurisprudencia ha rechazado la relevancia del error de subsunción que tiene lugar cuando el sujeto sabe que su conducta está prohibida por la ley pero ignora su calificación jurídica o la pena que pueda corresponderle. En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que la responsabilidad penal sólo exige el conocimiento de la ilicitud de la conducta y no de la norma concreta infringida⁷.
 - Por último, la jurisprudencia ha subrayado la dificultad de apreciar la existencia del error por pertenecer al arcano íntimo de la conciencia. En este sentido, no bastará la mera alegación del error sino que será necesaria la prueba no sólo de la existencia del error sino también de su carácter invencible⁸.

ERROR IMPROPIO

- Pasando a ocuparnos del error impropio, ya hemos señalado que éste no incide en la fase de ideación, deliberación y resolución previa sino sobre la fase de ejecución del delito. En este sentido, nos referiremos a sus distintas modalidades.
- En cuanto al **“error in persona” o “error in obiecto”**, éste tiene lugar cuando el sujeto confunde la persona o la cosa sobre la que recae la acción delictiva en cuyo caso distinguimos según que el error afecte o no al bien jurídico protegido:
 - Por un lado, si el error no afecta al bien jurídico protegido por gozar ambos objetos de igual protección como cuando una persona mata a otra creyendo erróneamente que se trata de un enemigo, el error será irrelevante.
 - Por otro lado, si el error afecta al bien jurídico protegido por gozar uno de los objetos de una protección penal reforzada como cuando una persona mata a otra creyendo que se trata de un enemigo tratándose, sin embargo, de un Jefe de Estado extranjero, se apreciará un concurso ideal entre el delito doloso intentado y el delito imprudente consumado siempre que el resultado más grave hubiera sido previsible y evitable y, además, aparezca expresamente castigado en su modalidad imprudente.
- En cuanto al **error en el golpe o “aberratio ictus”**, éste tiene lugar cuando el sujeto dirige su acción contra un objeto determinado pero ésta recae sobre otro objeto distinto debido a una ejecución deficiente del acto. En este sentido, la jurisprudencia distingue tres supuestos:
 - Primero, si el resultado efectivamente producido era previsible, se apreciará también un concurso ideal entre el delito doloso intentado y el delito imprudente consumado⁹.
 - Segundo, si el resultado efectivamente producido era imprevisible, nos encontraríamos ante un único delito doloso intentado.
 - Tercero, si el resultado efectivamente producido es imputable a título de dolo eventual, nos encontraríamos ante un dolo alternativo integrado por un dolo directo de primer grado y un dolo eventual. En relación con este supuesto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que el dolo del resultado producido excluye al otro por lo que el error sería irrelevante¹⁰.
- En cuanto al **error en el curso causal o “aberratio causae”**, éste tiene lugar cuando el desenvolvimiento del curso causal se produce de forma distinta de la prevista por el autor del hecho en cuyo caso pueden darse tres posibilidades:
 - En primer lugar, que el curso causal vaya más allá de lo deseado por el sujeto en cuyo caso estaríamos ante un caso de preterintencionalidad como sucede cuando el sujeto golpea a otra persona con el ánimo de herirle y le causa la muerte. En este sentido, la doctrina sostiene que el hecho será castigado como un concurso ideal entre el delito doloso intentado y el delito imprudente consumado¹¹.
 - En segundo lugar, que el curso causal haya sido insuficiente para producir el resultado como cuando el sujeto suministra veneno a otra persona en dosis insuficientes para causar su muerte, en cuyo caso estaríamos ante un delito imposible.
 - Por último, que el resultado pretendido tenga lugar por un cauce distinto del planeado como sucede en el caso del sujeto que intenta matar a otro arrojándolo por un puente y éste muere al chocar con uno de sus pilares o en el caso del marido que creyendo haber matado a su esposa abriendo la llave del gas mientras dormía, la abre de nuevo para simular un suicidio, provocando así el fallecimiento.
 - En relación con estos casos, la doctrina sostiene que nos encontramos ante un hecho unitario con un *dolus generalis* que no merece un tratamiento jurídico privilegiado.
 - De este modo, el sujeto responderá a pesar de la desviación del curso causal al haber creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha materializado en el resultado típico conforme a las teorías de la imputación objetiva.

¹ SSTS 17 de mayo de 1999, 13 de noviembre de 2003 y 18 de abril de 2006.

² SSTS 11 de marzo de 1996, 3 de diciembre de 2002, 5 de febrero de 2007 y 19 de junio de 2008.

³ STS 19 de abril de 2013.

⁴ STS 16 de mayo de 2013.

⁵ STS 20 de febrero de 1992.

⁶ STS 31 de octubre de 2012.

⁷ SSTS 3 de diciembre de 2002 y 16 de febrero de 2006.

⁸ SSTS 3 de enero de 1985, 13 de noviembre de 1989 y 13 de junio de 1990,

⁹ SSTS 7 de febrero de 2002 y 12 de junio de 2009.

¹⁰ STS 12 de junio de 2009.

¹¹ SSTS 26 de octubre de 2005 y 22 de octubre de 2010.

DERECHO PENAL

TEMA 10

LA PUNIBILIDAD. LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS. LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. LAS CONDICIONES DE PERSEGUIBILIDAD.

LA PUNIBILIDAD

- Al estudiar la punibilidad, hay que comenzar señalando que la teoría jurídica del delito concibe modernamente a éste como una acción típica, antijurídica, culpable y punible. De este modo, la punibilidad constituye uno de los elementos integrantes del concepto moderno de delito.
- En cuanto al **contenido de la punibilidad**, ésta comprende todas aquellas circunstancias que condicionan la imposición de una pena y que no guardan relación con la antijuridicidad ni con la culpabilidad.
 - En este sentido, algunos autores sostienen un concepto estricto de la punibilidad conforme al cual ésta sólo comprendería las excusas absolutorias y las condiciones objetivas de punibilidad.
 - Por el contrario, otros autores sostienen un concepto amplio de la punibilidad conforme al cual ésta comprendería también las causas personales de exclusión de la pena, las condiciones de perseguibilidad como la exigencia de denuncia o querella y la ausencia de causas de extinción de la responsabilidad penal como la prescripción o el indulto.
- Por otro lado, algunos autores sostienen que la punibilidad no deber formar parte del concepto jurídico de delito ya que resulta inadecuado incluir en su definición lo que no constituye uno de sus elementos esenciales sino una consecuencia del mismo.
 - Por su parte, Quintano Ripollés sostiene la necesidad de distinguir la amenaza de la pena y la imposición real y efectiva de la misma de modo que sólo el primero de estos conceptos sería un elemento esencial del delito.
 - Por otro lado, Cobo del Rosal distingue el momento normativo y el momento aplicativo de la punibilidad de modo que el primero se referiría al delito como concepto abstracto descrito en la ley y el segundo se referiría a un hecho delictivo concreto y ya verificado. De este modo, la pena podría faltar en el momento aplicativo sin afectar a la existencia del delito pero no en el momento normativo.
- En cuanto al **fundamento de las causas de exclusión de la punibilidad**, éstas pueden responder a distintos tipos de motivaciones como son las siguientes:
 - En primer lugar, la existencia de medios menos lesivos y más eficaces para la solución del conflicto como sucede con la excusa absolutoria del art. 268.
 - En segundo lugar, la necesidad de incentivar comportamientos postdelictivos favorables como sucede con la evitación de la propagación del incendio del art. 354.
 - En tercer lugar, la existencia de intereses ajenos al hecho delictivo que aconsejan mantenerlo impune como sucede con las inviolabilidades e inmunidades.
 - Por último, la necesidad de condicionar la persecución del delito a la voluntad de la víctima como sucede con la exigencia de denuncia o querella.
- En cuanto a sus **clases**, podemos manejar diversos criterios de clasificación.
 - En cuanto al **momento en el que surgen**, distinguimos entre circunstancias coetáneas como la excusa absolutoria del art. 268 y circunstancias posteriores como los comportamientos postdelictivos favorables.
 - En cuanto al **relación con el autor**, distinguimos entre circunstancias personales que se extienden sólo a aquéllos en quienes concurren como son las inviolabilidades e inmunidades y circunstancias no personales que se extienden a cualquier persona como la condición de reciprocidad en los delitos contra el Derecho de Gentes del art. 606.2.
 - En cuanto al **efecto sobre la pena**, distinguimos entre circunstancias de exclusión de la pena como la excusa absolutoria del art. 268 y circunstancias de atenuación de la pena como la liberación de la víctima en el delito de detención ilegal del art. 163.2

- En cuanto a los **efectos de la punibilidad**, la doctrina se refiere a los siguientes:
 - En primer lugar, el error sobre la punibilidad resulta irrelevante al no afectar a ninguno de los elementos objetivos del tipo ni al conocimiento de la significación antijurídica de la acción. De este modo, la persona que hurta dinero a su tío creyéndose amparada por la excusa absolutoria del art. 268 del Código Penal no incurre en error de tipo ni en error de prohibición.
 - En segundo lugar, podrá oponerse legítima defensa a quien actúe amparado por una causa de exclusión de la punibilidad y no sólo cuando ésta sea posterior al delito sino también cuando sea coetánea o anterior. Por tanto, la víctima de un hurto amparado por la excusa absolutoria del art. 268 podrá oponer legítima defensa en los términos previstos en el art. 20.4 para la defensa de los bienes.
 - Por último, las causas de exclusión de la punibilidad no excluyen la responsabilidad civil.

LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS

- Pasando a ocuparnos de las excusas absolutorias, se trata de supuestos en que el legislador opta por mantener impune una conducta típica, antijurídica y culpable por razones de utilidad y política criminal.
- En relación con ellas, distinguimos entre excusas absolutorias coetáneas y posteriores a la ejecución del hecho delictivo.

COETÁNEAS

- En cuanto a las excusas absolutorias coetáneas, nos referiremos a las previstas en relación con los delitos patrimoniales y el delito de encubrimiento.
- En cuanto a los **delitos patrimoniales**, el art. 268 dispone que *están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de persona con discapacidad. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.*
 - En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que su fundamento radica en razones de política criminal relativas al menor reproche social de los delitos patrimoniales en el seno familiar y la conveniencia de evitar una intervención penal que podría perjudicar la reconciliación¹.
 - Por otro lado, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2000 declaró que la aplicación de la excusa absolutoria entre hermanos no exige la convivencia entre ellos.
 - Por su parte, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2005 declaró que a efectos de aplicación de la excusa absolutoria, las relaciones estables de pareja se equiparan a la relación matrimonial.
- En cuanto a los **delitos de encubrimiento**, el art. 454 dispone que *están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el número 1º del art. 451.*

POSTERIORES

- En cuanto a las excusas absolutorias posteriores, el Código Penal contempla varios supuestos de desistimiento voluntario del autor del hecho en relación con los delitos que exponemos a continuación.
- No obstante, algunos autores sostienen que no se trata propiamente de excusas absolutorias sino de elementos negativos del tipo que impiden la existencia de delito y no sólo la imposición de una pena.
- En cuanto al **delito de matrimonio ilegal**, el art. 218 contempla como excusa absolutoria la convalidación posterior del matrimonio inválido.
 - En este sentido, el apartado 1 castiga a *el que para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido*.
 - Por su parte, el apartado 2 dispone que *el responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado*.
- En cuanto al **delito de incendio forestal**, el art. 354 contempla como excusa absolutoria la acción voluntaria y positiva del sujeto activo que evita la propagación del incendio.
- En cuanto al **delito de cohecho**, el art. 426 contempla como excusa absolutoria la denuncia del particular afectado por la solicitud de dádivas de una autoridad o funcionario público.
- En efecto, se establece que *quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos*.
- En cuanto al **delito de falso testimonio**, el art. 462 contempla como excusa absolutoria la retractación en tiempo y forma del testigo falso.
- En efecto, se establece que *quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate. Si, a consecuencia del falso testimonio, se hubiese producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado*.
- En cuanto al **delito de rebelión**, el art. 480 contempla como excusa absolutoria la revelación del delito.
- En efecto, se establece que *quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias*.
- En cuanto a los **delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social**, hay que señalar que la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012 configuró la regularización de la situación tributaria o la situación ante la Seguridad Social como elemento negativo del tipo a diferencia de la legislación anterior que la contemplaba como excusa absolutoria.
 - En efecto, el art. 305 castiga a *el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo*.
 - En relación con este precepto, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2012 señala que la regularización tributaria extingue el injusto derivado del incumplimiento inicial de la obligación tributaria por lo que hay que entender que no se trata de una causa de exclusión de la punibilidad sino de una causa de exclusión de la tipicidad.

CAUSAS PERSONALES DE EXCLUSIÓN DE LA PENA

- Pasando a ocuparnos de las causas personales de exclusión de la pena, se trata de supuestos en que el legislador opta por mantener impune una conducta típica, antijurídica y culpable por razón del cargo especialmente relevante de su autor.
- En este sentido, distinguiremos entre inviolabilidades e inmunidades de Derecho interno y de Derecho internacional.

INVIOLABILIDAD

- En cuanto a las inviolabilidades, éstas comprenden la inviolabilidad parlamentaria, la del Jefe del Estado y la de los titulares de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo y los Magistrados del Tribunal Constitucional.
- En cuanto a la **inviolabilidad parlamentaria**, el art. 71 de la Constitución dispone que *los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones*.
 - En relación con este precepto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/1985 declaró que la inviolabilidad parlamentaria no se extingue por la expiración del mandato y se extiende únicamente a las opiniones expresadas en los actos parlamentarios.
 - Por el contrario, la inviolabilidad no se extiende a las opiniones expresadas por los parlamentarios al margen del ejercicio de sus funciones.
- En cuanto a la **inviolabilidad del Jefe del Estado**, el art. 56.3 de la Constitución dispone que *la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo salvo lo dispuesto en el art. 65.2*.
- En cuanto a la **inviolabilidad de Derecho Internacional**, el art. 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sustrae al conocimiento de los tribunales españoles los casos de inmunidad de jurisdicción y ejecución establecidos en las normas de Derecho Internacional Público.

INMUNIDADES DE DERECHO INTERNO

- En cuanto a las inmunidades de Derecho interno, se trata de instituciones de carácter procesal que incluyen la inmunidad parlamentaria y la inmunidad del Presidente y los demás miembros del Gobierno.
- En cuanto a la **inmunidad parlamentaria**, el art. 71.2 de la Constitución dispone que *durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán, asimismo, de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo*.
 - En relación con este precepto, conviene señalar que la inmunidad se extiende a los delitos cometidos antes o durante el mandato parlamentario y que sean enjuiciados en el mismo periodo. Sin embargo, no se extiende a hechos enjuiciados con posterioridad a menos que se trate de actos amparados por la inviolabilidad parlamentaria.
 - Finalmente, cabe señalar que algunos Estatutos de Autonomía regulan la inmunidad de los miembros de sus Asambleas Legislativas de forma similar a la prevista en la Constitución. No obstante, la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1981 declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento Vasco que disponía que sus miembros no podrían ser inculcados ni procesados sin la previa autorización del propio Parlamento.

- En cuanto a la **inmunidad de los miembros del Gobierno**, el art. 102 de la Constitución dispone que *la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.*

INMUNIDADES DE DERECHO INTERNACIONAL

- En cuanto a las inmunidades de Derecho Internacional, el art. 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sustrae al conocimiento de los Jueces y Tribunales españoles los supuestos de inmunidad de jurisdicción y ejecución establecidos en las normas de Derecho Internacional Público.
- En este sentido, cabe señalar la inmunidad diplomática regulada en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares de 1961 y 1963, la Convención de Nueva York sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 y el Protocolo nº 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea.

LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD

- Pasando a ocuparnos de las condiciones objetivas de punibilidad, se trata de circunstancias de naturaleza heterogénea, ajenas al hecho punible y que condicionan la imposición de una pena.
- En este sentido, nos referiremos a las condiciones objetivas de punibilidad en sentido estricto y los requisitos de perseguibilidad o condiciones objetivas de procedibilidad.
- En cuanto a las **condiciones objetivas de punibilidad en sentido estricto**, cabe señalar dos supuestos como son la condición de penalidad recíproca en los delitos contra el Derecho de Gentes y la punibilidad de los delitos cometidos en el extranjero en su lugar de ejecución.
 - En cuanto a la **penalidad recíproca en los delitos contra el Derecho de Gentes**, el art. 606.2 dispone que *cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior no tengan señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito, con arreglo a las disposiciones de este Código si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial mencionado en el apartado anterior.*
 - En cuanto a la **punibilidad de los cometidos en el extranjero en su lugar de ejecución**, el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la jurisdicción española conocerá de los delitos previstos en las leyes españolas y cometidos fuera del territorio nacional siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y que concurren los siguientes requisitos:
 - En primer lugar, que el hecho sea punible en su lugar de ejecución a menos que este requisito no sea necesario conforme a un Tratado Internacional o un acto normativo de una Organización Internacional en la que España sea parte.
 - En segundo lugar, que el Ministerio Fiscal o el agraviado interponen querrela ante los tribunales españoles.
 - Por último, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o condenado en el extranjero y que, en este caso, no haya cumplido la condena. Sin embargo, si la hubiere cumplido solo en parte, ésta se computará para rebajar la pena.

LAS CONDICIONES DE PERSEGUIBILIDAD

- En cuanto a las condiciones de perseguibilidad, se trata de óbices procesales cuya falta es normalmente subsanable y entre los que destacan los que exponemos a continuación.
- En cuanto a la **exigencia de denuncia**, ésta será exigible para la persecución de los delitos de agresión sexual; acoso sexual; descubrimiento y revelación de secretos; reproducción asistida sin consentimiento materno y abandono de familia e impago de pensiones, entre otros.
- Por otro lado, también será preceptiva la denuncia o querella del agraviado o del Ministerio Fiscal para la persecución de los delitos cometidos por españoles en el extranjero.
- En cuanto a la **exigencia de querella**, ésta será exigible para la persecución de los delitos de calumnia e injuria contra particulares.
- En efecto, el art. 215 dispone que *nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.*
- En cuanto la **exigencia de licencia del Juez o Tribunal**, el mismo precepto dispone que *nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.*
- En cuanto a la **exigencia de sentencia firme o auto firme de archivo**, el art. 456 dispone que *no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.*

¹ SSTS 5 de marzo de 2003 y 30 de enero de 2007.

DERECHO PENAL

TEMA 11

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. ANÁLISIS DE LAS EXIMENTES INCOMPLETAS.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

- Al estudiar las circunstancias atenuantes, hay que comenzar señalando que la gravedad de la pena impuesta como consecuencia de la comisión de un delito depende de la gravedad objetiva del mismo, del grado de ejecución y participación, de la personalidad del delincuente y de la concurrencia de determinadas circunstancias atenuantes o agravantes que revelan una mayor o menor antijuridicidad o culpabilidad.
- En cuanto a las **circunstancias atenuantes**, hay que señalar que el art. 21 del Código Penal ha modificado el catálogo existente bajo la vigencia del Código Penal anterior al suprimir las de embriaguez, preterintencionalidad y minoría de dieciocho años.
- Del mismo modo, se ha incorporado la atenuante de adicción a sustancias tóxicas y se ha desdoblado la atenuante de arrepentimiento espontáneo en dos circunstancias distintas como son la de confesión y la de reparación del daño causado.

GRAVE ADICCIÓN A DETERMINADAS SUSTANCIAS

- En cuanto a la atenuante de grave adicción a determinadas sustancias, el art. 21.2 dispone que *es circunstancia atenuante la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2º del artículo anterior*.
- En este sentido, el Código Penal contempla los casos en que el delito se comete en un estado de disminución de imputabilidad provocado por la adicción al consumo de drogas o bebidas alcohólicas y no en un estado de falta de imputabilidad provocada por la intoxicación plena o por un síndrome de abstinencia en cuyo caso nos encontraríamos ante la eximente completa del art. 20.2.
- En cuanto a sus **requisitos**, será necesario que la adicción sea grave y que guarde relación funcional con el delito cometido.
 - En cuanto a la **gravedad de la adicción**, la jurisprudencia ha declarado que no bastará la mera condición de drogodependiente o alcohólico sino que será necesario que la adicción sea intensa y prolongada y que afecte siquiera de forma ligera a la capacidad del sujeto para comprender la significación antijurídica de sus actos y actuar conforme a esa comprensión¹.
 - En cuanto a la **relación funcional con el delito cometido**, la jurisprudencia sostiene que será necesario que la causa del delito sea la adicción, dando lugar a los supuestos de “delincuencia funcional” en los que el sujeto comete el delito para procurarse el dinero con que obtener la droga o trafica con droga para tener oportunidades de consumirla y conseguir beneficios económicos con que mantener sus inclinaciones².
 - En este sentido, la jurisprudencia aprecia habitualmente la atenuante en delitos contra el patrimonio o delitos contra la salud pública. Por el contrario, la misma jurisprudencia la ha rechazado en casos de tráfico de grandes cantidades de droga por entender que la finalidad principal del delito era el ánimo de lucro³.
- En cuanto a su **aplicación como atenuante analógica**, la jurisprudencia la ha apreciado en supuestos de escasa incidencia en las facultades del sujeto como en los de mero abuso de la sustancia o adicciones de menor intensidad o antigüedad⁴.

ARREBATO, OBCECACIÓN U OTRO ESTADO PASIONAL DE ENTIDAD SEMEJANTE

- Pasando a ocuparnos de la atenuante de arrebató, el art. 21.3 dispone que *es circunstancia atenuante la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante*.

- En cuanto a sus **elementos**, cabe distinguir dos como son las causas o estímulos poderosos y el arrebató, obcecación o estado pasional de entidad semejante.
 - En cuanto a las causas o estímulos poderosos, distinguimos los siguientes requisitos:
 - Primero, será necesario que las causas o estímulos procedan de la víctima por lo que no se apreciará la atenuante en casos de riña mutuamente aceptada⁵ ni en situaciones que deban ser necesariamente aceptadas como el desafecto o el deseo de poner fin a una relación conyugal⁶.
 - Segundo, será necesario que las causas o estímulos sean graves por lo que no se apreciará la atenuante en casos de reacciones coléricas por motivos ante los que cualquier persona reaccionaría con normalidad⁷.
 - Tercero, será necesario que las causas o estímulos sean próximos en el sentido de que exista una relación causal entre el estímulo y la reacción del sujeto por lo que no se apreciará la atenuante cuando el tiempo transcurrido haya permitido recuperar la serenidad.
 - Cuarto, será necesario que exista una cierta proporcionalidad entre el estímulo y la reacción del sujeto y que ésta no sea repudiable desde el punto de vista social y cultural. En este sentido, la jurisprudencia rechaza la apreciación de la atenuante en casos de violencia de género por estimar que una conducta que perpetúa una desigualdad de género no expresa una menor culpabilidad⁸.
 - En cuanto al arrebató, obcecación o estado pasional, la jurisprudencia ha declarado que el arrebató se caracteriza por su aparición súbita y su fugacidad mientras que la obcecación se caracteriza por su aparición lenta y su mayor duración⁹.
 - Por otro lado, la jurisprudencia sostiene que el arrebató u obcecación es distinto del simple acaloramiento que acompaña a la comisión de algunas conductas delictivas pero también del trastorno mental transitorio, del que se diferencian por la menor intensidad de la perturbación de facultades del sujeto¹⁰.
 - Finalmente, la jurisprudencia sostiene que los celos no justifican ordinariamente la apreciación de las atenuantes de arrebató u obcecación pues ello supondría privilegiar reacciones coléricas expresivas de un espíritu de dominación¹¹. De este modo, los celos sólo podrán valorarse cuando exista una base patológica que afecte a la imputabilidad del autor.

CONFESIÓN

- Pasando a ocuparnos de la atenuante de confesión, el art. 21.4 dispone que *es circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades*.
- En este sentido, su apreciación exige un requisito objetivo y un requisito cronológico.
- En cuanto al **elemento objetivo**, la jurisprudencia sostiene que la confesión debe ser completa y veraz por lo que no procederá la apreciación de la atenuante si el sujeto aporta información falsa o tendenciosa u oculta aspectos esenciales para eludir su responsabilidad¹². No obstante, procederá la apreciación de la atenuante cuando las primeras manifestaciones sean mendaces si las posteriores son veraces y concurren los demás requisitos de la atenuante¹³.
 - Por otro lado, tampoco procederá la apreciación de la atenuante si el sujeto se limita a denunciar el hecho sin autoinculparse como en el supuesto del homicida que se limita a comunicar la existencia de una persona muerta¹⁴.
 - Finalmente, será indiferente que la confesión provenga del delincuente u otra persona que actúe en su nombre¹⁵ pero debe realizarse ante autoridad o agente de la autoridad cualificados para recibirla.

- En cuanto al **elemento cronológico**, será necesario que la confesión se produzca antes de que el sujeto conozca que el procedimiento judicial se dirige contra él.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que el inicio del procedimiento a efectos de apreciación de la atenuante se produce con la investigación policial¹⁶.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia admite la apreciación de la atenuante cuando el sujeto conocía únicamente la incoación de unas diligencias previas para investigar el hecho pero desconocía que el procedimiento se dirigiera contra él¹⁷.
- En cuanto a su **aplicación como atenuante analógica**, la jurisprudencia la ha apreciado en casos en que la confesión sucedía después de que el sujeto conociera que el procedimiento judicial se dirigía contra él pero siempre que la colaboración con la Administración de Justicia haya sido de especial relevancia¹⁸.

REPARACIÓN DEL DAÑO

- En cuanto a la atenuante de reparación del daño, el art. 21.5 dispone que *es circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral*.
- En este sentido, la apreciación de la atenuante exige la concurrencia de un requisito objetivo y un requisito cronológico.
- En cuanto al **elemento objetivo**, éste consiste en la actividad reparadora que deberá restaurar o disminuir los efectos del delito.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que la reparación deberá ser eficiente y relevante por lo que no procederá la apreciación de la atenuante cuando el sujeto se limite a entregar un aval como garantía de un pago futuro ni tampoco cuando la cuantía del pago sea muy reducida en comparación con el perjuicio causado¹⁹.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia admite la apreciación de la atenuante cuando la reparación es meramente moral o simbólica como la petición de perdón²⁰.
- En cuanto al **elemento cronológico**, será necesario que la actividad reparadora se produzca en cualquier momento anterior a la celebración del juicio oral.
- En cuanto a su **aplicación como atenuante analógica**, la jurisprudencia la ha apreciado en casos en que la actividad reparadora se producía una vez iniciado el juicio oral²¹.

DILACIONES EXTRAORDINARIAS E INDEBIDAS

- Pasando a ocuparnos de la atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas, el art. 21.6 dispone que *es circunstancia atenuante la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa*.
 - En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sostiene que la expresión “dilaciones indebidas” debe valorarse teniendo en cuenta la complejidad del asunto, los márgenes ordinarios de duración de procesos del mismo tipo, la conducta procesal del recurrente, el interés que arriesga en el asunto y la forma en que el asunto haya sido despachado por el órgano judicial²².
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia ha declarado que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no equivale al cumplimiento riguroso de los plazos procesales²³ pero no puede exceptuarse cuando las dilaciones se deban a motivos estructurales no imputables al órgano judicial porque el ciudadano es ajeno a estas circunstancias²⁴.

- En cuanto a sus **requisitos**, será necesario que las dilaciones sean indebidas, extraordinarias, no atribuibles al inculpado y desproporcionadas con la complejidad de la causa.
 - En cuanto al **carácter indebido**, la jurisprudencia ha declarado que el plazo de duración del proceso debe computarse desde que el sujeto adquiere la condición de investigado hasta el pronunciamiento de la sentencia firme.
 - En este sentido, no se considerarán dilaciones indebidas las demoras producidas por la incoación tardía del procedimiento ni por el desarrollo de un delito continuado.
 - En cuanto al **carácter extraordinario**, será necesario que la duración del procedimiento supere los márgenes ordinarios de duración de los procesos del mismo tipo.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha admitido la apreciación de la atenuante como muy cualificada en casos de retrasos extraordinarios y en el de una causa que permaneció paralizada ocho años por la tramitación de una cuestión de inconstitucionalidad²⁵.
 - En cuanto al **carácter no atribuible al inculpado**, la misma jurisprudencia ha rechazado la apreciación de la atenuante en el caso de dilaciones provocadas por la rebeldía del investigado, por el retraso en la devolución de los autos por el Abogado de la defensa o por la renuncia del acusado a su Abogado o Procurador²⁶.
 - En cuanto al **carácter desproporcionado**, la jurisprudencia ha declarado que deberán ponderarse todas las circunstancias que hayan influido en la duración del proceso.
 - Por otro lado, el carácter desproporcionado no dependerá de la duración global del procedimiento sino de la existencia de periodos injustificados de inactividad procesal²⁷.
 - En este sentido, no bastará para la apreciación de la atenuante con una mera alegación sino que será necesario concretar los periodos de interrupción o inactividad procesal para que el órgano jurisdiccional pueda valorar su gravedad y justificación.
- En cuanto a la **atenuante analógica de cuasiprescripción**, la jurisprudencia viene aplicando esta circunstancia en casos de tardanza excesiva en la interposición de la denuncia o querrela que determina que la incoación del proceso se produzca cuando el plazo de prescripción se encuentra avanzado o bien en casos de desidia institucional o inactividad de las autoridades conocedoras de la comisión de un delito²⁸.
- No obstante, no procederá su apreciación cuando el perjuicio derivado del retraso haya dado lugar a la atenuante de dilaciones indebidas.

ATENUANTE ANALÓGICA

- Pasando a ocuparnos de las atenuantes analógicas, el art. 21.7 dispone que *es circunstancia atenuante cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha declarado que será necesaria la existencia de una relación de analogía entre la circunstancia que se trate de apreciar y el sentido inspirador del catálogo de atenuantes genéricas previstas en el Código Penal y sin que sea necesario que la analogía se establezca con una de ellas en particular²⁹.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia sostiene que no procederá la apreciación de la atenuante analógica cuando falten requisitos básicos de una atenuante genérica³⁰ si bien tampoco podrá exigirse una correspondencia total entre la atenuante analógica y aquella con la que pretenda establecerse la analogía³¹.
 - Finalmente, la atenuante analógica podrá apreciarse en relación con las eximentes completas del art. 20 por la vía de la eximente incompleta del art. 21.1. Sin embargo, no cabrá en tales casos la disminución de la pena en uno o dos grados prevista para las eximentes incompletas por el art. 68.

ANÁLISIS DE LAS EXIMENTES INCOMPLETAS

- En cuanto a las eximentes incompletas, el art. 21.1 dispone que *son circunstancias atenuantes las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos*.
- En este sentido, nos referiremos seguidamente a cada una de las eximentes previstas en el art. 20 del Código Penal.
- En cuanto a las **anomalías o alteraciones psíquicas**, la jurisprudencia ha apreciado la eximente incompleta en casos de grave disminución de la imputabilidad del sujeto que no alcancen a una falta absoluta de la misma.
 - En efecto, tratándose de enfermos psicóticos, se ha apreciado la eximente incompleta en el caso de delitos cometidos bajo un estado de intensa alteración de las facultades mentales aunque no se acredite que el sujeto se encontraba en un brote psicótico, como sucede cuando concurre el consumo de alcohol o drogas³².
 - Del mismo modo, tratándose de enfermos de neurosis, se ha apreciado la eximente incompleta en el caso de ludopatía cuando el sujeto actúa con un deseo irrefrenable de participar en el juego que le lleva a realizar actos dirigidos a proporcionarse dinero para satisfacer su adicción³³.
- En cuanto a la **intoxicación plena y el síndrome de abstinencia**, la jurisprudencia sostiene que la apreciación de la eximente completa exigirá que la perturbación de facultades del sujeto sea plena y fortuita.
 - De este modo, la apreciación de una eximente incompleta procederá en los casos en que la perturbación es fortuita pero no plena y si es plena pero no fortuita como sucede con las *actiones liberae in causa*.
 - Finalmente, el síndrome de abstinencia podrá dar lugar a la aplicación de una eximente completa, una eximente incompleta o una atenuante analógica en función de la intensidad de la alteración de las facultades mentales del sujeto.
- En cuanto a las **alteraciones en la percepción**, será necesario que las alteraciones se produzcan desde el nacimiento o desde la infancia por lo que la ausencia de este requisito impide la apreciación de la eximente completa o incompleta.
- De este modo, procederá la apreciación de la eximente incompleta en supuestos de grave disminución de la imputabilidad del sujeto que no alcancen a una falta absoluta de la misma.
- En cuanto a la **legítima defensa**, hay que señalar que su elemento básico viene constituido por la agresión ilegítima por lo que su ausencia impide la apreciación de la eximente completa o incompleta.
- De este modo, podrá apreciarse la eximente incompleta cuando concurra agresión ilegítima pero falte uno de los otros dos requisitos como son la necesidad racional del medio empleado o la falta de provocación suficiente por parte del defensor.
- En cuanto al **estado de necesidad**, hay que señalar que su elemento básico viene constituido por la situación de necesidad, que deberá ser real, actual e inminente, y por la inexistencia de otros medios lícitos o menos gravosos disponibles para eludir el mal.
- De este modo, podrá apreciarse la eximente incompleta cuando concurren estos requisitos pero falte algún otro de los exigidos legalmente como cuando el mal causado no sea mayor que el que se pretenda evitar o cuando la situación de necesidad haya sido provocada intencionalmente por el sujeto o cuando el necesitado tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse.
- En cuanto al **miedo insuperable**, la jurisprudencia ha admitido la apreciación de la eximente incompleta cuando el miedo no fue insuperable en el sentido de que no pudiera ser dominado por la generalidad de las personas y sin considerar a personas especialmente valerosas o temerarias o especialmente pusilánimes o miedosas.

- En cuanto al **cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo**, la jurisprudencia admite la apreciación de la eximente incompleta en casos de extralimitación en el uso de la fuerza por parte de agentes de la autoridad siempre que ello se hubiere producido por motivos relacionadas con el servicio y no por razones de índole personal.

-
- ¹ SSTS 17 de noviembre de 2011 y 19 de diciembre de 2011.
- ² STS 23 de febrero de 1999, 4 de diciembre de 2000, 29 de mayo de 2003, 8 de abril de 2009 y 24 de mayo de 2022.
- ³ STS 2 de abril de 2012.
- ⁴ STS 26 de julio de 2006.
- ⁵ SSTS 12 de noviembre de 2001 y 19 de mayo de 2005.
- ⁶ SSTS 8 de noviembre de 2007 y 30 de diciembre de 2010.
- ⁷ STS 13 de octubre de 2005.
- ⁸ SSTS 12 de diciembre de 2006, 10 de noviembre de 2010 y 1 de julio de 2016.
- ⁹ STS 3 de mayo de 1988.
- ¹⁰ SSTS 2 de abril de 1990 y 25 de enero de 2002.
- ¹¹ STS 18 de enero de 2010.
- ¹² SSTS 27 de mayo de 1992, 11 de marzo de 1997 y 20 de septiembre de 2006.
- ¹³ STS 19 de diciembre de 2024.
- ¹⁴ STS 5 de diciembre de 1990.
- ¹⁵ STS 27 de marzo de 1993.
- ¹⁶ STS 18 de noviembre de 2008.
- ¹⁷ STS 18 de noviembre de 2008.
- ¹⁸ STS 31 de julio de 2008.
- ¹⁹ SSTS 30 de abril de 2003, 30 de junio de 2003 y 8 de febrero de 2011.
- ²⁰ STS 7 de marzo de 2007.
- ²¹ STS 31 de julio de 2008.
- ²² SSTC 54/2014, de 10 de abril y 129/2016, de 18 de julio y 125/2022, de 10 de octubre.
- ²³ STC 58/1999, de 12 de abril.
- ²⁴ STC 81/1989, de 8 de mayo.
- ²⁵ STS 16 de junio de 2007.
- ²⁶ SSTS 29 de septiembre de 2005, 10 de mayo de 2001 y 10 de febrero de 2006.
- ²⁷ STS 19 de diciembre de 2001.
- ²⁸ SSTS 10 de septiembre de 2009, 24 de noviembre de 2016 y 24 de mayo de 2017.
- ²⁹ STS 24 de junio de 2005.
- ³⁰ STS 6 de octubre de 1998.
- ³¹ STS 11 de mayo de 1992.
- ³² STS 7 de marzo de 2010.
- ³³ STS 29 de octubre de 2001.

DERECHO PENAL

TEMA 12

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA AGRAVANTE DE GÉNERO. EL PROBLEMA DE LA COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

- Al estudiar las circunstancias agravantes, hay que comenzar señalando que la gravedad de la pena impuesta por la comisión de un delito depende de su gravedad objetiva, del grado de ejecución y participación, de la personalidad del delincuente y de la concurrencia de determinadas circunstancias que pueden revelar una mayor o menor antijuridicidad o culpabilidad.
- En este sentido, son circunstancias agravantes genéricas las previstas en el art. 22 del Código Penal y específicas, las establecidas para determinados delitos en su Libro II.

ALEVOSÍA

- En cuanto a la alevosía, el art. 22.1 dispone que *es circunstancia agravante ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.*
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia distingue los siguientes:
 - Primero, un elemento normativo consistente en el hecho de concurrir en cualquiera de los delitos contra las personas.
 - Segundo, un elemento objetivo o instrumental consistente en la utilización de medios, modos o formas objetivamente idóneos para asegurar la ejecución del delito y eliminar la defensa del ofendido aunque la eliminación no sea efectiva.
 - En este sentido, la jurisprudencia sostiene que el uso de veneno¹ o armas de fuego contra una víctima inerte integra ordinariamente un ataque alevoso². Por otro lado, la capacidad de defensa del ofendido que debe valorarse no es la consistente en correr u ocultarse sino la procedente de los medios defensivos de que disponga³.
 - Por otra parte, tratándose de riñas mutuamente aceptadas, no procederá apreciar la agravante a menos que se haya producido un cambio cualitativo en el uso de la violencia o haya transcurrido un lapso significativo desde que acabó el incidente inicial⁴.
 - Tercero, un elemento subjetivo consistente en el conocimiento del medio de ejecución empleado y de su idoneidad para asegurar la ejecución del delito y eliminar la defensa del ofendido. De este modo, la jurisprudencia rechaza la apreciación de la alevosía cuando el sujeto actúa con finalidad meramente defensiva⁵.
 - Por último, un elemento teleológico o tendencial consistente en la utilización intencionada del *modus operandi* con el fin de asegurar la ejecución del delito y eliminar la defensa de la víctima⁶.
- En cuanto a las **clases de alevosía**, la jurisprudencia distingue las siguientes:
 - Primero, la alevosía proditoria consistente en el ataque por traición, asechanza, insidia, emboscada, celada o lazo.
 - Segundo, la alevosía aleve consistente en el ataque imprevisto, fulgurante, o repentino. En este sentido, la jurisprudencia alude especialmente a la llamada alevosía doméstica como modalidad específica aplicable a los casos de violencia familiar y que se deriva de la relajación de los recursos defensivos de la víctima por la imprevisibilidad de un ataque de la persona con la que convive día a día⁷.
 - Tercero, la alevosía derivada de situaciones constitucionales de desvalimiento en las que la situación de indefensión no ha sido creada por el sujeto activo como sucede con los ataques a recién nacidos, niños de corta edad o ancianos desvalidos⁸.

- En cuanto a la **compatibilidad con otras circunstancias**, la jurisprudencia ha declarado que la alevosía no es compatible con el abuso de superioridad al tratarse de una alevosía menor.
- Por el contrario, la alevosía sí es compatible con la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y con la atenuante de arrebato u obcecación siempre que el sujeto conserve lucidez suficiente para apercebirse de los medios comisivos empleados⁹.

ABUSO DE SUPERIORIDAD, DISFRAZ Y APROVECHAMIENTO DE CIRCUNSTANCIAS

- Pasando a ocuparnos del disfraz, abuso de superioridad y aprovechamiento de circunstancias, el art. 22.2 dispone que *es circunstancia agravante ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente*.
- En este sentido, nos referiremos a cada una de las circunstancias citadas en el precepto.
- En cuanto a la **agravante de disfraz**, la jurisprudencia exige los siguientes requisitos:
 - Primero, un elemento objetivo consistente en el uso de medios adecuados para ocultar o desfigurar el rostro o aspecto habitual del sujeto. En este sentido, podrá apreciarse la agravante aunque el enmascaramiento sea parcial o insuficiente pero siempre que los medios utilizados no sean excesivamente rudimentarios y con independencia de que el sujeto haya sido identificado por otros datos como la voz o sus rasgos físicos visibles¹⁰.
 - Segundo, un elemento subjetivo consistente en el propósito de ocultar la identidad para debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente.
 - Tercero, un elemento cronológico consistente en la utilización del disfraz al tiempo de la comisión del hecho delictivo. De este modo, la jurisprudencia rechaza la apreciación de la agravante cuando el disfraz se utiliza únicamente para proteger la huida y cuando el sujeto se despoja de él por su propia voluntad la ejecución del delito¹¹.
- En cuanto a la **agravante de abuso de superioridad**, serán necesarios los siguientes requisitos:
 - Primero, será necesaria una situación de superioridad entendida como un desequilibrio importante de fuerzas entre el agresor y la víctima.
 - En este sentido, la superioridad podrá derivarse de la intervención de varios atacantes o de la diferencia de fuerza entre el agresor y la víctima como sucede en los casos de agresiones de una persona joven a una persona anciana.
 - Por otro lado, la superioridad podrá también derivarse de los medios empleados para la agresión como cuando el sujeto hace uso de armas o artes marciales.
 - Segundo, será necesario que esta situación de superioridad provoque una disminución notable de las posibilidades de defensa de la víctima pero sin llegar a eliminarla, en cuyo caso estaríamos ante la agravante de alevosía.
 - Tercero, será necesario el aprovechamiento efectivo de la situación de superioridad por parte del sujeto.
 - Cuarto, será necesario que la situación de superioridad no resulte inherente al delito de que se trate como puede suceder en el caso de las agresiones sexuales a víctimas especialmente vulnerables.
- Finalmente, ya hemos señalado que el abuso de superioridad es incompatible con la alevosía.
 - En este sentido, el abuso de superioridad se diferencia de la alevosía porque no supone una eliminación completa de las posibilidades de defensa sino solamente una minoración.
 - Por otro lado, la alevosía sólo puede apreciarse en delitos contra las personas mientras que el abuso de superioridad puede apreciarse en relación con otros delitos salvo aquéllos a los que resulte inherente.

- En cuanto al **aprovechamiento de circunstancias**, distinguimos varias modalidades:
 - En cuanto a las **circunstancias de lugar**, será necesaria la concurrencia de un elemento objetivo consistente en la ejecución del delito en parajes solitarios o lejanos del núcleo urbano que favorezcan la ejecución del hecho y un elemento subjetivo consistente en el aprovechamiento de esta circunstancia por parte del autor¹².
 - Por otro lado, tratándose de delitos de agresión sexual, la jurisprudencia ha admitido la apreciación de la agravante de modo restrictivo teniendo en cuenta la clandestinidad que suele caracterizar a la ejecución de estos delitos¹³.
 - En cuanto a las **circunstancias de tiempo**, será necesaria la concurrencia del elemento objetivo consistente en la existencia de oscuridad y soledad y un elemento subjetivo consistente en el aprovechamiento de estas circunstancias para facilitar la ejecución.
 - De este modo, la jurisprudencia sostiene que procederá la apreciación de la agravante cuando el delito se cometa a horas nocturnas o intempestivas o bajo condiciones climatológicas que faciliten su ejecución.
 - En cuanto a las **circunstancias de auxilio de otras personas**, la agravante se apreciará cuando el auxilio tienda a facilitar la impunidad del delincuente y, si tiende a debilitar la defensa del ofendido, no se apreciará esta agravante sino la de abuso de superioridad.

MÓVILES LUCRATIVOS

- En cuanto a la agravante de móviles lucrativos, el art. 22.3 dispone que *es circunstancia agravante ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa*.
- En este sentido, la jurisprudencia sostiene que se entiende por precio el valor pecuniario en que se estima una cosa; por recompensa, cualquier cosa o derecho valorable económicamente pero con exclusión de concesiones amorosas, honoríficas o similares y por promesa, una voluntad de comportamiento futuro referida a alguno de los elementos anteriores.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia distingue los siguientes:
 - Primero, la recepción o promesa de una merced de contenido económico.
 - Segundo, la actuación de la merced como motivo determinante de la comisión del delito.
 - Tercero, la entidad económica de la merced de que se trate para ser repudiada socialmente por la inmoralidad y falta de escrúpulo que evidencia¹⁴.

MÓVILES DISCRIMINATORIOS

- En cuanto a la agravante de móviles discriminatorios, el art. 22.4 dispone que *es circunstancia agravante cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurren efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia exige la concurrencia de dos elementos como son la voluntad de considerar a la víctima un ser inferior por razón de las condiciones mencionadas y la entidad de este móvil como causa determinante de la comisión del delito.
- En este sentido, la jurisprudencia valora datos como el empleo de insultos o frases ofensivas relacionadas con la raza, nacionalidad u orientación sexual de la víctima¹⁵.

ENSAÑAMIENTO

- En cuanto al ensañamiento, el art. 22.5 dispone que *es circunstancia agravante aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito*.
- En este sentido, el ensañamiento está expresamente contemplado para los delitos de asesinato del art. 139 y lesiones del art. 148.
- En cuanto a sus **requisitos**, distinguimos los siguientes:
 - En primer lugar, un elemento objetivo consistente en el aumento del sufrimiento de la víctima más allá de lo necesario para la consumación del delito. De este modo, el ensañamiento podrá consistir en la elección de un procedimiento especialmente cruel o doloroso; en la ejecución de actos complementarios para aumentar el sufrimiento; en la prolongación intencionada de la agonía o en el ensañamiento moral que somete a la víctima a una angustia psíquica tan insoportable como el daño físico¹⁶.
 - En segundo lugar, un elemento subjetivo consistente en la voluntad deliberada e inhumana de aumentar el sufrimiento de la víctima. No obstante, la jurisprudencia ha declarado que no será necesaria un ánimo especialmente frío, reflexivo o sereno del autor¹⁷.

ABUSO DE CONFIANZA

- En cuanto a la agravante de abuso de confianza, el art. 22.6 dispone que *es circunstancia agravante obrar con abuso de confianza*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes:
 - Primero, la existencia de una relación de confianza entre el autor del hecho y la víctima que puede provenir de relaciones familiares, laborales, de convivencia, vecindad u otras análogas que originen un deber específico de lealtad.
 - Segundo, el aprovechamiento de las facilidades derivadas de tales relaciones para la comisión del delito.
- Por otro lado, la jurisprudencia sostiene que no procederá la apreciación de la agravante en los delitos a los que resulta inherente como puede ocurrir con algunos tipos agravados de los delitos de estafa, apropiación indebida y contra la libertad sexual.
- Finalmente, la misma jurisprudencia ha declarado que la agravante de abuso de confianza es incompatible con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 por lo que sólo procederá la aplicación de una de ellas¹⁸.

PREVALIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CULPABLE

- En cuanto al prevalimiento del carácter público del culpable, el art. 22.7 dispone que *es circunstancia agravante prevalerse del carácter público que tenga el culpable*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes:
 - Primero, un elemento objetivo consistente en que el sujeto activo reúna la condición de funcionario público o encargado de un servicio público.
 - Segundo, un elemento subjetivo consistente en el aprovechamiento de las ventajas del cargo para abusar de la confianza de la víctima o reducir sus posibilidades de defensa.
- Por otro lado, no procederá la apreciación de la agravante en relación con los delitos a los que resulta inherente como son los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

REINCIDENCIA

- En cuanto a la agravante de reincidencia, el art. 22.8 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *Es circunstancia agravante ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza.*
 - 2º. *A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.*
 - 3º. *Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.*
- Por otra parte, la jurisprudencia sostiene que el fundamento de esta agravante radica en razones de prevención especial consistentes en la necesidad de una mayor represión frente al sujeto que muestra una inclinación a cometer la misma clase de delitos¹⁹.
- Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1991 declaró que la reincidencia no se opone al principio *non bis in idem* ni al principio de culpabilidad.

CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO

- Pasando a ocuparnos de la circunstancia mixta de parentesco, el art. 23 dispone que es *circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.*
 - En este sentido, la apreciación de esta circunstancia procederá aunque el matrimonio o relación estable se hayan extinguido.
 - No obstante, tratándose de relación de afectividad análoga al matrimonio, la jurisprudencia sostiene que no procederá su apreciación cuando se trate de relaciones ocasionales sin convivencia.
- En cuanto a su **eficacia penológica**, la jurisprudencia ha sostenido tradicionalmente que esta circunstancia atenúa la responsabilidad criminal en los delitos patrimoniales y la agrava en los delitos contra las personas y los delitos contra la libertad sexual.
- Por el contrario, el parentesco será irrelevante si no conlleva una mayor reprochabilidad del delito cometido²⁰.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia ha aplicado esta circunstancia como atenuante en casos como la entrega de droga a un hijo en prisión y en el del llamado homicidio *pietatis causa*²¹.
 - Finalmente, la circunstancia mixta de parentesco no se apreciará en los casos en que éste venga recogido en el tipo penal como en los delitos de bigamia, abandono de familia o violencia habitual en el ámbito familiar.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA AGRAVANTE DE GÉNERO

- Pasando a ocuparnos del análisis jurisprudencial de la agravante de género, esta circunstancia fue introducida por la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 a raíz del Convenio de Estambul de 2011, que define la violencia de género como toda violencia contra una mujer por ser una mujer o que afecte a las mujeres de forma desproporcionada.

- Por su parte, la jurisprudencia ha establecido las siguientes pautas interpretativas:
 - Primero, el fundamento de la agravante radica en la mayor reprochabilidad que supone la comisión del delito contra una mujer por el mero hecho de serlo y para hacer patente el sentimiento de superioridad del autor²². De este modo, no bastará que el delito haya sido cometido por un hombre y lesione bienes jurídicos de una mujer sino que será necesario que el autor haya actuado con móviles de dominación sobre la mujer por considerarla un ser inferior y con desprecio de su derecho a la igualdad²³.
 - Segundo, la agravante de género se diferencia de la agravante de discriminación por razón de sexo porque ésta no exige una intención de dominación de la mujer y porque el sexo se refiere a rasgos biológicos y fisiológicos que diferencian a los hombres y las mujeres mientras que el género se refiere a comportamientos o atributos construidos socialmente y que una colectividad considera propios de hombres o de mujeres²⁴.
 - Tercero, la agravante de género es compatible con la agravante de parentesco porque la primera tiene un fundamento subjetivo consistente en la intención de dominación sobre la mujer mientras que ésta tiene un fundamento objetivo consistente en la existencia de una relación presente o pasada de carácter conyugal o análogo²⁵.
 - Cuarto, no procederá la aplicación de las agravantes de género o de parentesco en los delitos que exijan una relación presente o pasada entre víctima y agresor porque ello supondría infracción del principio *non bis in idem*²⁶.
- Finalmente, tratándose de delitos contra la libertad sexual, la jurisprudencia sostiene que sólo procederá la apreciación de la agravante de género cuando las circunstancias demuestren que se trata de un acto de dominio machista aunque el hombre no busque específicamente humillar o dominar a la mujer, para lo que se valorarán circunstancias como el número de los autores, las expresiones proferidas o el carácter especialmente denigratorio de las prácticas realizadas²⁷.

EL PROBLEMA DE LA COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS

- Pasando a ocuparnos del problema de la comunicabilidad de las circunstancias, el art. 65 fija las siguientes reglas:
 - 1º. *Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal servirán agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.*
 - 2º. *Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.*
 - 3º. *Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamenten la culpabilidad del autor, los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.*
- En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que no serán comunicables a los partícipes las causas que afecten a la imputabilidad ni tampoco las causas de exculpación. Sin embargo, sí lo son las causas de justificación porque no cabe hablar de participación en un delito que no existe.
- En cuanto a los **delitos especiales propios**, conviene recordar que son delitos especiales los que sólo pueden ser cometidos por las personas que reúnen una determinada condición.
- Por otro lado, son delitos especiales propios aquellos que carecen de un delito correlativo común que pueda ser cometido por cualquier persona como es el delito de prevaricación.

- En relación con ellos, la jurisprudencia declaró tradicionalmente que en caso de participación de un *extraneus* en un delito especial propio como la malversación, el *extraneus* no podía ser castigado como partícipe en el mismo delito sino por otra figura distinta como el hurto, estafa o apropiación indebida.
 - Por el contrario, la jurisprudencia más moderna entendió que el *extraneus* debía ser castigado por su participación en el delito ejecutado sin ruptura del título de imputación pero con la atenuación derivada de la falta de la condición exigida al *intraneus*.
 - Finalmente, el art. 65 establece una solución legislativa análoga a la jurisprudencial al prever la disminución facultativa de la pena en un grado. Por tanto, el Juez o Tribunal podrá denegar la reducción de pena cuando la intervención del partícipe haya sido muy próxima al dominio del hecho característico de la autoría.

¹ STS 17 de diciembre de 2001.

² STS 22 de febrero de 2012.

³ STS 22 de enero de 2009.

⁴ SSTs 24 de abril de 2000 y 12 de mayo de 2008.

⁵ STS 29 de febrero de 2000.

⁶ SSTs 10 de junio de 2014,

⁷ SSTs 29 de junio de 2012 y 14 de marzo de 2017.

⁸ SSTs 31 de octubre de 2007 y 24 de octubre de 2008

⁹ SSTs 10 de febrero de 2003 y 11 de marzo de 1996.

¹⁰ SSTs 10 de noviembre de 2000, 1 de marzo de 2002 y 20 de julio de 2022.

¹¹ STS 25 de junio de 2002

¹² SSTs 10 de mayo de 1993, 19 de abril de 1994 y 23 de marzo de 2017.

¹³ STS 1 de julio de 2008.

¹⁴ SSTs 7 de julio de 1983 y 14 de septiembre de 1992.

¹⁵ SSTs 13 de marzo de 2003 y 22 de abril de 2010.

¹⁶ SSTs 13 de noviembre de 2015 y 19 de enero de 2017.

¹⁷ SSTs 27 de febrero de 2001 y 13 de julio de 2005.

¹⁸ STS 16 de octubre de 2001.

¹⁹ SSTs 14 de enero de 2003 y 30 de septiembre de 2003.

²⁰ STS 8 de junio de 2011.

²¹ SSTs 19 de diciembre de 2013 y 6 de febrero de 2004.

²² STS 19 de noviembre de 2018.

²³ STS 15 de enero de 2019.

²⁴ STS 25 de septiembre de 2018.

²⁵ STS 19 de noviembre de 2018.

²⁶ SSTs 25 de septiembre de 2018 y 19 de noviembre de 2018.

²⁷ SSTs 14 de septiembre de 2020 y 29 de septiembre de 2023.

DERECHO PENAL

TEMA 13

LAS FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO. EL «ITER CRIMINIS». LOS ACTOS PREPARATORIOS. LA CONSPIRACIÓN, LA PROPOSICIÓN Y LA PROVOCACIÓN PARA DELINQUIR. LA TENTATIVA. EL DESISTIMIENTO. EL DELITO IMPOSIBLE.

LAS FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO: EL *ITER CRIMINIS*

- Al estudiar las formas de aparición del delito, podemos comenzar definiendo el *iter criminis* como *el conjunto de fases que se suceden desde que nace la idea criminal hasta su completa realización*.
- En este sentido, el *iter criminis* viene integrado por dos fases como son la fase interna, que se desarrolla en la mente del autor y a través de la cual se formaliza la voluntad delictiva, y la fase externa que surge cuando la resolución criminal se exterioriza.
 - En cuanto a la fase interna, ésta consta de tres momentos como son la ideación que se produce cuando el sujeto concibe la idea criminal; la deliberación que se produce cuando el sujeto contrapone la idea criminal con sus sentimientos de deber y temor al castigo y la resolución que se produce cuando el sujeto decide ejecutar la acción.
 - En este sentido, el Derecho Penal no castiga la fase interna de ideación, deliberación y resolución previa a la comisión de un delito sino que será necesario que la resolución criminal se exteriorice para que tenga lugar la acción represora.
 - En cuanto a la fase externa, ésta consta de otros tres momentos como son los actos preparatorios, la fase de ejecución y la consumación.

LOS ACTOS PREPARATORIOS

- En cuanto a los actos preparatorios, podemos definirlos como *aquellas acciones que el sujeto realiza para proveerse de los medios necesarios para la comisión del delito sin constituir propiamente actos de ejecución del mismo*.
- En relación con ellos, se plantea la cuestión de determinar cuál sea el criterio diferenciador que permita distinguir los actos preparatorios y actos ejecutivos. En este sentido, la respuesta que se ofrezca a la cuestión es de la máxima relevancia ya que permitirá dilucidar la relevancia penal de una conducta en la medida que los actos preparatorios son generalmente impunes salvo algunos supuestos especialmente peligrosos como los delitos relativos a la posesión de drogas preordenada al tráfico del art. 368.
- En relación con esta cuestión, se han manejado distintas posturas doctrinales:
 - En primer lugar, algunos autores como Carrara distinguen entre actos unívocos o actos equívocos según revelen la intención criminal del sujeto o puedan dirigirse a fines lícitos o ilícitos. De este modo, los actos unívocos serían actos de ejecución mientras que los actos equívocos serían meramente preparatorios.
 - En segundo lugar, otros autores como Beling sostienen que son actos de ejecución aquéllos que implican la realización de la actividad expresada en el verbo que describe la conducta típica. Por el contrario, serían actos preparatorios aquéllos que no pueden quedar englobados en aquel verbo e integran la llamada zona periférica del tipo.
 - Por último, otros autores como Mayer sostiene que son actos de ejecución los que atacan o ponen en peligro un bien jurídico y son actos preparatorios los que mantienen invariable dicho bien.

LA CONSPIRACIÓN, LA PROPOSICIÓN Y LA PROVOCACIÓN PARA DELINQUIR

- Pasando a ocuparnos de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir, hay que señalar que todas ellas se engloban en la denominación de resoluciones manifestadas, formulada por Jiménez de Asúa, en la medida en que suponen la exteriorización de una resolución criminal una vez superada las fases de ideación y deliberación previas.

- En cuanto a su **sistema de incriminación**, distinguimos un sistema de incriminación genérica como el existente bajo la vigencia del Código Penal anterior y un sistema de excepcionalidad o *numerus clausus* como el mantenido por el Código Penal de 1995.
 - En este sentido, el 17.3 dispone que *la conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley*.
 - Por su parte, el art. 18.2 dispone que *la provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la ley así lo prevea*.

CONSPIRACIÓN

- En cuanto a la conspiración, el art. 17.1 dispone que *la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes:
 - En primer lugar, será necesaria la intervención de dos o más personas que reúnan las condiciones exigibles para la autoría del delito proyectado¹.
 - En segundo lugar, será necesario un concierto de voluntades para la comisión de un delito concreto y sin que baste el concierto dirigido a la comisión de delitos en general.
 - En tercer lugar, será necesaria la resolución de ejecutar el delito por lo que no bastará el concierto dirigido a la realización de actos de mero auxilio. En este sentido, la jurisprudencia sostiene que será necesario el transcurso de un cierto lapso de tiempo entre el concierto y la ejecución del delito por lo que no bastará el acuerdo surgido espontáneamente cuando se presenta la oportunidad inmediata de delinquir².
 - Por último, será necesario que no se haya iniciado la fase de ejecución ya que, en ese caso, el hecho se castigaría como tentativa o consumación.

PROPOSICIÓN

- En cuanto a la proposición, el art. 17.2 dispone que *la proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes³:
 - Primero, será necesaria la resolución del proponente de ejecutar un delito concreto hasta su consumación. De este modo, la proposición se diferencia de la provocación y la inducción ya que el provocador y el inductor no tienen voluntad de ejecutar el delito.
 - Segundo, será necesario la invitación a participar en un delito, ya sea mediante actos de coautoría, cooperación necesaria o complicidad.
 - Tercero, será necesario que la invitación se dirija a un sujeto que no había decidido ejecutar el delito por sí mismo.
 - Cuarto, será necesario que la invitación sea seria, directa, persuasiva y que se refiera a la comisión de un delito concreto con independencia de si es aceptada. Sin embargo, si la invitación es aceptada, estaríamos ante un caso de conspiración⁴.

PROVOCACIÓN

- En cuanto a la provocación, el art. 18.1 dispone que *la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito*.

- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes:
 - Por un lado, será necesaria una incitación directa a cometer un delito concreto y sin que basten expresiones ambiguas o encubiertas ni tampoco la incitación a la comisión de delitos en general.
 - En segundo lugar, será necesario que la incitación se dirija a un destinatario colectivo en el sentido de realizarse a través de un medio de difusión o ante una concurrencia de personas.
- En cuanto a su **diferencia con la inducción**, el art. 18.2 dispone que *si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción*.
 - En este sentido, conviene recordar que la inducción tiene lugar cuando una persona hace nacer en otra la decisión de ejecutar un delito. De este modo, la provocación puede considerarse como una inducción frustrada o tentativa de inducción.
 - Por otro lado, conviene señalar que la provocación se dirige a un destinatario colectivo mientras que la inducción deberá dirigirse a una persona determinada.
- En cuanto a la **apología delictiva**, el art. 18.1 dispone que *es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito*.
 - Por otro lado, conviene señalar que la apología aparece especialmente contemplada en relación con los delitos de terrorismo. En efecto, el art. 578 castiga *el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares*.
 - Por su parte, el art. 607 contemplaba en su redacción originaria la apología en relación con el delito de genocidio. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007 declaró inconstitucional el castigo de la difusión de ideas o doctrinas que nieguen los delitos de genocidio por infracción del derecho a la libertad de expresión.

LA TENTATIVA

- Pasando a ocuparnos de la tentativa, el art. 15 del Código Penal dispone que *son punibles el delito consumado y la tentativa de delito*.
- Por su parte, el art. 16.1 dispone que *hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y, sin embargo, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor*.
- En cuanto a sus **elementos**, la doctrina ha señalado los siguientes:
 - En primer lugar, será necesario que el sujeto dé principio a la ejecución directamente y por hechos exteriores.
 - En segundo lugar, será necesaria la realización de todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. En relación con este requisito, la doctrina distingue entre tentativa acabada e inacabada o entre tentativa idónea e inidónea en los términos que señalaremos más adelante.
 - En tercer lugar, será necesaria la falta de producción del resultado a menos que éste no se haya producido por el desistimiento del sujeto en cuyo caso no estaríamos ante un caso de tentativa.
 - Por último, será necesario el dolo del sujeto por lo que no procederá la apreciación de la tentativa en relación con los delitos imprudentes pero sí en caso de dolo eventual.

- En cuanto a sus **clases**, conviene señalar que el Código Penal de 1995 ha abandonado la distinción entre tentativa y frustración establecida en el Código Penal de 1973 si bien mantiene la distinción entre tentativa acabada e inacabada.
 - En este sentido, se entiende por tentativa inacabada aquella que tiene lugar cuando el sujeto realiza sólo parte de los actos necesarios para la consumación del delito.
 - Por el contrario, se entiende por tentativa acabada o frustración aquella que tiene lugar cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito y el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad.
- Por otra parte, dentro de la tentativa acabada, la doctrina distingue entre tentativa reversible o irreversible.
 - En este sentido, se entiende por tentativa acabada reversible aquella que tiene lugar cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios para la ejecución del delito pero la producción del resultado requiere un lapso de tiempo en que el sujeto puede impedir el resultado mediante el desistimiento activo como sucede en el caso de la persona que coloca una bomba con un temporizador que todavía puede ser desactivado.
 - Por el contrario, se entiende por tentativa acabada irreversible aquella que tiene lugar cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios para la ejecución del delito pero no cabe desistimiento como sucede en el caso de la persona que dispara un arma para matar y no acierta en el blanco.
- En cuanto a la **penalidad de la tentativa**, el art. 62 dispone que *a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.*
- En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que la pena se reducirá un grado en los casos de tentativa acabada o cuando la ejecución hubiese alcanzado un grado de desarrollo muy avanzado y dos grados en los supuestos de tentativa inacabada o cuando la actividad del delincuente revele una escala potencia criminal⁵.

EL DESISTIMIENTO

- Pasando a ocuparnos del desistimiento en la tentativa, la doctrina distingue entre desistimiento omisivo y activo.

DESISTIMIENTO OMISIVO

- En cuanto al desistimiento omisivo, éste tiene lugar cuando el sujeto realiza parte de los actos necesarios para la consumación del delito y la ejecución se interrumpe por causa dependiente de su voluntad.
- En relación con él, el art. 16.2 dispone que *quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados si éstos fueren ya constitutivos de delito.*
- En cuanto a sus **requisitos**, será necesario un elemento objetivo consistente en la renuncia a seguir realizando los actos de ejecución necesarios para la producción del resultado y un elemento subjetivo consistente en la voluntariedad de la renuncia.
- En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que el desistimiento no eximirá de pena en los casos en que el sujeto dejare de actuar por la aparición de obstáculos imprevisibles o dificultades que hagan más arriesgada o complicada la consumación⁶.

DESISTIMIENTO ACTIVO

- En cuanto al desistimiento activo, éste tiene lugar cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito pero el resultado no llega a producirse por causas dependientes de su voluntad. De este modo, el desistimiento activo exige la realización de un comportamiento activo para evitar el resultado.
- En relación con él, el art. 16.3 dispone que *cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir seria, firme y decididamente la consumación sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.*
- En cuanto a sus **requisitos**, será necesaria la concurrencia de dos elementos:
 - En primer lugar, un elemento objetivo consistente en la realización de actos que eviten la producción del resultado una vez realizados todos los que objetivamente deberían producirlo. En este sentido, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2002 declaró que la exención de pena procederá igualmente cuando sea el propio sujeto el que impide directamente la producción del resultado o cuando desencadena la acción de otras personas que son las que finalmente lo consiguen.
 - En segundo lugar, un elemento subjetivo consistente en la voluntariedad de la acción.

EL DELITO IMPOSIBLE

- Pasando a ocuparnos del delito imposible, hay que señalar que la doctrina penalista española ha empleado tradicionalmente este término o el de tentativa inidónea para designar aquellos supuestos en los que no es posible la comisión de delito por falta de idoneidad del sujeto, del objeto o del medio empleado.
 - En este sentido, hay inidoneidad del sujeto cuando una persona intenta cometer un delito que exige la condición de autoridad o funcionario público pero desconociendo la nulidad de su nombramiento como tal.
 - Por otro lado, hay inidoneidad del objeto cuando una persona intenta dar muerte a un cadáver o intenta provocar el aborto de una mujer que no se halla encinta.
 - Finalmente, hay inidoneidad de los medios cuando una persona intenta causar la muerte de otra administrándole una sustancia inocua.
- En cuanto a la **punición de la tentativa inidónea o delito imposible**, el art. 52 del Código Penal de 1973 sancionaba con la pena prevista para la tentativa *los casos de imposibilidad de ejecución o de producción del delito.*
 - En relación con este precepto, la jurisprudencia distinguió entre imposibilidad absoluta y relativa en función de que los medios de ejecución empleados hubieran sido inidóneos sólo en el caso concreto o en cualquier circunstancia al tiempo que se estableció el carácter punible de uno y otro supuesto.
 - No obstante, la misma jurisprudencia admitió la impunidad de la llamada tentativa irreal, imaginaria o supersticiosa en la que el medio de ejecución empleado sólo resulta apto para producir el resultado en la imaginación del sujeto activo como cuando éste intenta matar a una persona empleado conjuros mágicos.
- Por su parte, el Código Penal vigente ha prescindido de esta regla por lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que la tentativa inidónea o delito imposible será impune con arreglo al art. 4.1 que dispone que *las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.*

- No obstante, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2012 declaró que el art. 16 del Código Penal no impide la punibilidad de la tentativa inidónea cuando los medios de ejecución empleados, valorados objetivamente *ex ante*, hubieran sido abstracta y racionalmente aptos para producir el resultado.
- En cuanto a la **distinción de la tentativa inidónea y el delito putativo**, hay que señalar que la primera supone una creencia errónea del sujeto acerca de la concurrencia de alguno de los elementos del tipo por lo que algunos autores la han denominado error de tipo al revés. Por el contrario, el delito putativo supone una creencia errónea acerca de la significación antijurídica de la acción que realiza por lo que también se denomina error de prohibición al revés.
 - De este modo, comete tentativa inidónea la persona que oculta al funcionario de aduanas un reloj que considera valioso pero que, en realidad, es una falsificación. Sin embargo, incurre en delito putativo quien oculta al funcionario de aduanas un reloj valioso en el caso de que los relojes hubieran sido suprimidos de la lista de productos gravados.
 - En este sentido, el delito putativo debe considerarse impune por falta de tipicidad de la conducta desplegada por el sujeto.

¹ STS 16 de diciembre de 1998.

² STS 16 de diciembre de 1998.

³ STS 24 de marzo de 2014 y 3 de noviembre de 2016.

⁴ STS 23 de noviembre de 2006.

⁵ SSTS 14 de mayo de 2004 y 6 de marzo de 2006.

⁶ STS 18 de abril de 2000.

DERECHO PENAL

TEMA 14

LA AUTORÍA. AUTORÍA DIRECTA Y MEDIATA. LA COAUTORÍA. LA PARTICIPACIÓN:
FUNDAMENTO; LA ACCESORIEDAD. INDUCCIÓN, COOPERACIÓN NECESARIA Y
COMPLICIDAD.

LA AUTORÍA

- Al estudiar el concepto de autoría, hay que comenzar señalando el art. 27 del Código Penal que dispone que *son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices*.
 - En este sentido, el concepto de autoría engloba dos modalidades como son la autoría inmediata y la autoría mediata según el sujeto ejecute por sí mismo todos los elementos del delito o utilice a otra persona como instrumento para cometerlo.
 - Por otro lado, el concepto de participación engloba la inducción y la cooperación. Por su parte, esta última comprende la cooperación necesaria y la complicidad.

DIFERENCIA ENTRE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

- En cuanto a la diferencia entre autores y partícipes, se han manejado históricamente distintas posturas doctrinales de las que distinguiremos entre teorías unitarias y teorías restrictivas.
 - En cuanto a las teorías unitarias, éstas no distinguen entre autores y partícipes al entender que cualquier persona que contribuye causalmente a la realización de un hecho delictivo debe ser considerada como autor con independencia de la importancia de su contribución causal.
 - En cuanto a las teorías restrictivas, éstas sostienen que no basta una contribución causal para ser considerado autor sino que será necesario que dicha contribución encaje en la descripción formulada por el tipo penal. Por otro lado, dentro de ellas, distinguimos una serie de variantes como son la teoría formal-objetiva, la teoría material-objetiva y la teoría del dominio del hecho.
- En cuanto a la teoría formal-objetiva, ésta distingue entre autor y partícipe en función del aspecto externo de sus respectivos comportamientos. De este modo, sería autor la persona que realiza la conducta expresada en el verbo que describe la conducta típica y partícipe la persona que realiza actos no englobables en el tipo.
- En cuanto a la teoría material-objetiva, ésta distingue entre autor y partícipe en función de la peligrosidad de su conducta para el bien jurídico protegido. De este modo, sería autor la persona que realiza una contribución causal de mayor relevancia para la lesión del bien jurídico protegido y partícipe la persona que realiza actos de carácter accesorio o de menor relevancia para el mismo fin.
- En cuanto a la teoría del dominio del hecho, ésta concibe al autor como cualquiera de las personas que comparten el dominio del curso causal por lo que pueden decidir que el hecho delictivo se ejecute o no.
- Por otro lado, este dominio puede adoptar tres manifestaciones como son el dominio efectivo de la conducta típica que da lugar a la autoría directa; el dominio funcional que da lugar a la coautoría y el dominio de la voluntad de otro que daría lugar a la autoría mediata.

CLASES DE AUTORÍA

- En cuanto a las clases de autoría, el art. 28 del Código Penal dispone que *son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores:*
 - 1º. *Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.*
 - 2º. *Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría ejecutado.*
- De este modo, el art. 28 distingue entre autoría en sentido estricto y en sentido amplio. En este sentido, la autoría en sentido estricto engloba la autoría directa y la autoría mediata. Por su parte, la autoría en sentido amplio engloba la inducción y la cooperación necesaria.

AUTORÍA DIRECTA

LA COAUTORÍA

- En cuanto a la autoría directa, ésta incluye dos modalidades como son la autoría individual y la coautoría según que el sujeto realiza por si solo todos los elementos del tipo delictivo o éste se ejecute con la intervención de varios sujetos.
- En cuanto a los **requisitos de la coautoría**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes¹:
 - En primer lugar, será necesaria la existencia de un concierto de voluntades o *pactum scaeleris* entre los coautores de modo que pueda afirmarse que la ejecución del delito les corresponde a todos ellos. No obstante, este concierto puede ser expreso o tácito como sucede en los casos en que los coautores demuestran la existencia del acuerdo precisamente a través de su aportación.
 - En segundo lugar, será necesario el dominio funcional del hecho por parte de todos los coautores, lo que implica la existencia de un reparto de funciones entre ellos de modo que cada uno pueda decidir la ejecución de la conducta típica sin subordinación de unos respecto de otros².
 - En tercer lugar, será necesaria la realización por cada uno de los coautores de una contribución causal imprescindible a la ejecución del hecho aunque no todos realicen la actividad expresada por el verbo que describe la conducta típica. En este sentido, será indiferente que las contribuciones causales de algunos de los coautores se produzcan una iniciada la ejecución del delito como sucede en los casos de coautoría sucesiva o adhesiva en los que uno de los coautores une su conducta a la realizada previamente por otros³.
 - En cuarto lugar, será necesaria la existencia de una finalidad compartida por todos los coautores ya que sólo pueden ser dominados aquellos actos que se conocen.
 - Por último, será necesaria la concurrencia en todos los coautores de las cualidades, condiciones o relaciones exigidas por el tipo para ser considerado como autor.
- En relación con este último requisito, conviene recordar que son delitos especiales los que sólo pueden ser cometidos por las personas que reúnen una determinada condición. Por otro lado, son delitos especiales propios aquellos que carecen de un delito común correlativo que pueda ser cometido por cualquier persona como es el delito de malversación.
 - En relación con ellos, la jurisprudencia declaró tradicionalmente que en supuestos de participación de un particular o *extraneus* en un delito especial propio como la malversación, el *extraneus* no podía ser castigado como partícipe en el propio delito cometido sino por otra figura distinta como el hurto, estafa o apropiación indebida.
 - Por el contrario, la jurisprudencia más moderna entendió que el *extraneus* debía ser castigado por su participación en el delito realmente ejecutado evitando la ruptura del título de imputación si bien con la atenuante analógica derivada de la falta de la condición exigida al *intraneus*.
 - Finalmente, el apartado 3 del art. 65 ha establecido una solución legislativa análoga a la jurisprudencial al disponer que *cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurren las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamenten la culpabilidad del autor, los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate*. De este modo, el Juez o Tribunal podrá denegar la reducción de pena en los casos en que la intervención del partícipe hubiera sido muy próxima al dominio del hecho propio de la autoría.
- En cuanto a la **responsabilidad de los coautores**, la jurisprudencia ha declarado que ésta se extiende hasta donde alcanza el acuerdo de voluntades⁴.
- Sin embargo, puede suceder que uno de los coautores realice un acto no acordado expresamente y que implique una mayor responsabilidad como sucedería con la causación de un homicidio en el desarrollo de un delito de robo con armas de fuego.

- En relación con este supuesto, la jurisprudencia ha declarado que la responsabilidad por la desviación del concierto de voluntades se extenderá a los demás coautores en concepto de dolo eventual siempre que no aparezca como imprevisible en función de las circunstancias del caso.
- No obstante, será necesario examinar la actuación de los coautores distinguiendo entre quienes hubieran colaborado en la desviación del acuerdo de voluntades y los que hubiesen expresado su oposición.

AUTORÍA MEDIATA

- En cuanto a la autoría mediata, podemos definirla como *la utilización de una persona exenta de responsabilidad penal como instrumento para la comisión de un delito*.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes:
 - En primer lugar, será necesario que el autor mediato no realice el hecho personalmente sino a través de otra persona a la que utiliza como instrumento.
 - En segundo lugar, será necesario que el dominio del hecho característico de la autoría corresponda al autor mediato. De este modo, no existirá autoría mediata sino inducción cuando la persona utilizada como instrumento pueda responder del hecho en concepto de dolo.
 - En tercer lugar, será necesario que el autor mediato reúna las condiciones objetivas y subjetivas requeridas para responder como autor del tipo penal del que se trate.
- En relación con este requisito, ya hemos señalado que son delitos especiales propios aquellos delitos especiales que carecen de un delito común correlativo que pueda ser cometido por cualquier persona como es el delito de malversación.
 - Por otro lado, son delitos de propia mano aquéllos que exigen una intervención física del autor como son los delitos sexuales o los delitos de falso testimonio.
 - En este sentido, tanto los delitos especiales propios como los delitos de propia mano excluyen la autoría directa y la autoría mediata de las personas que no reúnan la condición exigida en el tipo penal o que no hayan realizado la intervención física exigida pero no presentan limitaciones a la participación delictiva en concepto de inducción o complicidad.
- En cuanto a las **causas de exención de responsabilidad del ejecutor material**, ésta puede obedecer a los siguientes motivos:
 - Primero, que la conducta del ejecutor material sea atípica como sucede cuando alguien se mata o causa lesiones a sí mismo bajo la influencia decisiva de otro.
 - Segundo, que el ejecutor material actúe amparado por una causa de justificación como sucede en el caso de la persona que recibe una orden antijurídica pero obligatoria de su superior jerárquico.
 - Tercero, que el ejecutor material actúe sin dolo como sucede en el caso del agente policial que practica la detención de un inocente por una denuncia falsa.
 - Cuarto, que el ejecutor material actúe amparado en una causa de inimputabilidad como sucede cuando se utiliza a una persona con una anomalía o alteración psíquica grave.
 - Quinto, que el ejecutor material actúe amparado por una causa de exculpación como sucede en el caso de la persona que obliga a otra a falsificar un documento bajo miedo insuperable o coacción.
 - Por último, que el ejecutor material no reúna las cualidades personales exigidas para la autoría como sucede con los delitos especiales propios que exigen la condición de autoridad o funcionario público.

ACTUACIÓN EN LUGAR DE OTRO

- En cuanto a la autoría por actuación en lugar de otro, el art. 31 dispone que *el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responderá personalmente, aunque no concurren en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.*
- En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que el mismo no establece una presunción de culpa o un sistema de responsabilidad objetiva a cargo del representante de una persona o entidad en aquellos casos en que no pueda averiguarse la identidad de los responsables directos de una conducta delictiva realizada en el ámbito de una persona jurídica o una relación representativa.
 - Por el contrario, el citado precepto constituiría un mero recurso técnico para evitar la impunidad de conductas delictivas realizadas en el ámbito de una persona jurídica por sujetos perfectamente individualizables cuando las cualidades exigidas por el tipo sólo concurren en la persona jurídica y no en sus integrantes.
 - Por tanto, hay que entender que el art. 31 no exime de prueba de la participación en el hecho delictivo y de la culpabilidad de quienes hubieren actuado en nombre o representación de la persona o entidad de que se trate.

LA PARTICIPACIÓN: FUNDAMENTO

LA ACCESORIEDAD

- Pasando a ocuparnos de la participación delictiva, ya hemos señalado que ésta engloba dos modalidades como son la inducción y la cooperación. Por su parte, esta última engloba la cooperación necesaria y la complicidad.
- En cuanto al **fundamento de la punición de los partícipes**, la doctrina y la jurisprudencia sostienen que éste radica en la accesoriedad o dependencia de la conducta del partícipe respecto al hecho delictivo del autor⁵.
- En este sentido, se ha planteado la cuestión de determinar cuál sea el grado de accesoriedad que debe existir entre tales hechos para lo cual se han manejado varias posturas doctrinales:
 - En primer lugar, la teoría de la accesoriedad máxima que sostiene que el partícipe sólo responderá penalmente cuando el hecho del autor sea típico, antijurídico y culpable. De este modo, el partícipe no responderá penalmente cuando el autor sea inimputable ni cuando esté amparado por una causa de justificación o de exculpación.
 - En segundo lugar, la teoría de la accesoriedad limitada que sostiene que el partícipe sólo responderá penalmente cuando el hecho del autor sea típico y antijurídico aunque no sea culpable. De este modo, el partícipe no responderá penalmente cuando el autor esté amparado por una causa de justificación pero sí cuando sea inimputable o cuando esté amparado por una causa de exculpación.
 - En tercer lugar, la teoría de la accesoriedad mínima que sostiene que el partícipe sólo responderá penalmente cuando el hecho del autor sea típico aunque no sea antijurídico o culpable. De este modo, el partícipe responderá penalmente aunque el autor del hecho sea inimputable o esté amparado por una causa de justificación o exculpación.
- En cuanto a la **posición de la jurisprudencia**, ésta ha acogido la teoría de la accesoriedad media o accesoriedad limitada⁶.
- Por otro lado, la misma jurisprudencia ha declarado que la responsabilidad penal del partícipe exige la existencia de un hecho típico y antijurídico pero no que el autor haya sido condenado efectivamente⁷.

INDUCCIÓN

- En cuanto a la inducción, ésta tiene lugar cuando una persona hace nacer en otra la decisión de ejecutar un delito.
- En cuanto a sus **requisitos**, la jurisprudencia ha señalado los siguientes⁸:
 - Primero, que la inducción se dirija a una persona que no estaba previamente decidida a ejecutar la infracción.
 - Segundo, que la inducción se dirija a una persona determinada y para la comisión de un delito también determinado.
 - Tercero, que la inducción alcance la intensidad suficiente para convencer al sujeto de cometer el delito de manera que éste ejecute efectivamente el delito en cuestión.
 - Por último, que el dolo del inductor comprenda no sólo la intención de persuadir a la persona inducida sino también la de que el delito llegue a ejecutarse aunque no se haya producido la consumación sino una mera tentativa.
- En cuanto a su **diferencia con la provocación**, conviene recordar el art. 18 que dispone que *la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.*
 - En este sentido, la provocación puede considerarse como una inducción frustrada o tentativa de inducción.
 - Por otro lado, conviene señalar que la provocación se dirige a un destinatario colectivo mientras que la inducción deberá dirigirse a una persona determinada.
- En cuanto a su **diferencia con el agente provocador**, hay que señalar que éste no trata de provocar la comisión de un delito sino de descubrir una actividad delictiva preexistente.

COOPERACIÓN NECESARIA Y COMPLICIDAD

- En cuanto a la cooperación, ésta tiene lugar cuando un sujeto interviene dolosamente en un hecho delictivo ejecutado por otro posibilitando o facilitando su ejecución. En este sentido, ya hemos señalado que, dentro de la cooperación, cabe distinguir entre cooperación necesaria y complicidad de modo que la primera se equipara a efectos de penalidad con la autoría.
 - En relación con la complicidad, el art. 29 dispone que *son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.*
 - Por su parte, el art. 63 dispone que *a los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito.*
- En cuanto a la **distinción entre cooperación necesaria y complicidad**, la doctrina sostiene que el carácter necesario o accesorio de la cooperación deber valorarse en concreto mediante la aplicación de la fórmula de la *condictio sine qua non* de modo que, si suprimida mentalmente la conducta del partícipe, el delito no se hubiera realizado, entonces el partícipe es cooperador necesario.
 - Por su parte, la teoría de los bienes escasos, defendida por Gimbernat, sostiene que el partícipe responderá como cooperador necesario si su aportación hubiera sido imposible o muy difícil de conseguir por otros medios.
 - Finalmente, la teoría del aplazamiento, representada por Rodríguez Mourullo, sostiene que el partícipe responderá como cooperador necesario si el autor, en caso de faltar la intervención de aquél, hubiera tenido que renunciar a la ejecución del hecho o aplazarla hasta conseguir una colaboración equivalente.

DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MECÁNICOS

- En cuanto a los delitos cometidos por medios de difusión mecánicos, el art. 30 dispone que *en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieran favorecido personal o realmente. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:*
 - 1º. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.*
 - 2º. Los directores de la publicación o programa en que se difunda.*
 - 3º. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.*
 - 4º. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.*
- Finalmente, se establece que *cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.*

¹ STS 14 de octubre de 2009.

² SSTS 7 de octubre de 2002 y 14 de octubre de 2009.

³ SSTS 24 de marzo de 1998 y 17 de marzo de 2005.

⁴ STS 9 de octubre de 1992.

⁵ STS 26 de marzo de 2013.

⁶ SSTS 20 de junio de 2001 y 4 de marzo de 2010.

⁷ STS 26 de marzo de 2013.

⁸ STS 5 de mayo de 1988.

DERECHO PENAL

TEMA 15

LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFERENCIAS DOCTRINALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. RÉGIMEN DE INCRIMINACIÓN: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. PENAS Y CRITERIOS DE DETERMINACIÓN. RESPONSABILIDAD CIVIL.

LAS PERSONAS JURÍDICAS

REFERENCIAS DOCTRINALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL...

- Al estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay que comenzar señalando que la doctrina científica se mostró tradicionalmente contraria a la consideración de la persona jurídica como sujeto activo del delito sobre la base del principio *societas delinquere non potest*.
- Sin embargo, este principio vino a quebrar con la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010 que supuso la trasposición al Derecho español de diversos instrumentos internacionales como el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europea de 1999, y determinadas Decisiones Marco de la Unión Europea.
- En cuanto a las **posturas contraria a esta responsabilidad**, se han manejado las siguientes:
 - Primero, que las personas jurídicas carecen de capacidad de acción ya que no pueden realizar por sí solas un comportamiento dependiente de la voluntad humana.
 - Segundo, que las personas jurídicas carecen de imputabilidad ya que no reúnen las condiciones biopsíquicas necesarias para comprender la significación antijurídica de sus propios actos y actuar conforme a esa comprensión.
 - Tercero, que las personas jurídicas carecen de capacidad de pena o, al menos, de las penas más relevantes como son las privativas de libertad.
 - Cuarto, que la tesis favorable atentaría contra el principio de personalidad de las penas y el principio de responsabilidad individual al suponer una sanción indirecta para todos los miembros de una colectividad.
- En cuanto a las **posturas favorables**, éstas sostienen que la responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye un imperativo de política criminal vinculado a la necesidad de perseguir eficazmente la delincuencia en el seno de las grandes corporaciones modernas.
- Por otro lado, existen casos en que resulta imposible identificar a la persona física responsable de los delitos cometidos en el ámbito de la persona jurídica debido a la multiplicidad de sujetos que intervienen en su funcionamiento y al hecho de que las cualidades exigidas para la autoría de algunos delitos no concurren en la persona física sino en la persona jurídica.

RÉGIMEN DE INCRIMINACIÓN: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL

- Pasando a ocuparnos del régimen de incriminación en el Código Penal, hay que señalar que la regulación de esta materia responde a los siguientes principios:
 - Primero, el establecimiento de un sistema de *numerus clausus* conforme al cual las personas jurídicas sólo responden penalmente de los delitos expresamente previstos.
 - Segundo, el establecimiento de un sistema de autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica de modo que no será necesaria la condena de la persona física para exigir responsabilidad penal a aquélla si bien sí será indispensable la comisión de un delito por parte de una persona física integrada en la persona jurídica.
 - Tercero, el establecimiento de un sistema de responsabilidad por la propia conducta y no por el hecho ajeno. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 sostiene que la persona jurídica responderá cuando el delito cometido por la persona física haya sido posibilitado o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, traducida en la existencia de sistemas de vigilancia y control del comportamiento de los directivos y subordinados.
 - Cuarto, el establecimiento de un sistema respetuoso con los principios característicos del Derecho Penal como son los principios de culpabilidad y presunción de inocencia.
 - Por último, el establecimiento de un sistema de incriminación de doble vía en función de que el delito haya sido cometido por los administradores de la persona jurídica o por los empleados sometidos a la autoridad de aquéllos.

ACTOS DE LOS ADMINISTRADORES

- En cuanto a los actos de los administradores, el art. 31 bis dispone que *en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.*
- En relación con este precepto, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 sostiene que no será necesario un elemento subjetivo de beneficiar a la entidad sino que bastará que la conducta sea idónea para reportarle algún tipo de ventaja aunque sea meramente estratégica, intangible o reputacional y aunque el resultado no haya llegado a producirse.
- En cuanto a los **supuestos de exención de responsabilidad** el apartado 2 se refiere a los modelos de prevención o *compliance guides* de la práctica empresarial al disponer que *la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:*
 - 1º. *El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.*
 - 2º. *La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.*
 - 3º. *Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.*
 - 4º. *No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2ª.*
- Por otro lado, se establece que en los casos en que las circunstancias anteriores sólo puedan acreditarse parcialmente, este hecho se valorará a efectos de atenuación de la pena.
- En cuanto a las **personas jurídicas de pequeñas dimensiones**, el apartado 3 dispone que *en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.*
- En cuanto a los **requisitos de los modelos**, el apartado 5 se refiere a los siguientes:
 - Primero, identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan llegar a cometerse los delitos que deban prevenirse.
 - Segundo, establecerán protocolos o procedimientos de formación de la voluntad de la persona jurídica y adopción y ejecución de decisiones.
 - Tercero, establecerán modelos adecuados de gestión de los recursos financieros para impedir la comisión de los delitos que deban prevenirse.
 - Cuarto, establecerán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo.
 - Quinto, establecerán un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas previstas en el modelo.
 - Por último, preverán una verificación periódica del modelo y su eventual modificación cuando existan infracciones relevantes o se produzcan cambios en la organización, la estructura de control o la actividad desarrollada que lo hagan necesario.

ACTOS DE LOS EMPLEADOS

- En cuanto a la responsabilidad por actos de los empleados, el art. 31 bis dispone que *en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.*
 - En relación con este precepto, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 rechaza la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el incumplimiento de dichos deberes sea de escasa entidad sin perjuicio de las sanciones administrativas o mercantiles que puedan imponerse.
 - Por otro lado, el apartado 4 contempla la exención de responsabilidad de la persona jurídica en términos análogos a los previstos para los actos de los administradores.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

- En cuanto a la autonomía e independencia de la responsabilidad de las personas jurídicas, el art. 31 ter establece las siguientes reglas:
 - 1º. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los Jueces o Tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.*
 - 2º. *La concurrencia en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.*

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

- En cuanto a las circunstancias atenuantes aplicables a las personas jurídicas, el art. 31 quater dispone que *sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales las siguientes actividades:*
 - 1º. *Haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella a confesar la infracción a las autoridades.*
 - 2º. *Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas en cualquier momento del proceso que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.*
 - 3º. *Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.*
 - 4º. *Haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.*

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL

- En cuanto a los supuestos de exención de responsabilidad penal, el art. 31 quinquies dispone que el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas no será aplicable al Estado, las administraciones públicas territoriales e institucionales, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público y demás entidades que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
 - Por su parte, las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general sólo podrán sancionadas con las penas de multa e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
 - No obstante, esta limitación no se aplicará si el Juez o Tribunal apreciaren que se trata de formas jurídicas creadas por los promotores, fundadores, administradores o representantes para eludir su eventual responsabilidad penal.

PENAS

- Pasando a ocuparnos de las penas, el art. 33.7 dispone que las penas aplicables a personas jurídicas se estimarán graves y pueden ser las siguientes:
 - Primero, la multa por cuotas o la multa proporcional.
 - Segundo, la disolución de la persona jurídica.
 - Tercero, la suspensión de actividades por un plazo no superior a cinco años.
 - Cuarto, la clausura de locales y establecimientos por un plazo no superior a cinco años.
 - Quinto, la prohibición de realizar las actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. En este sentido, la prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo y, en el primer caso, no podrá exceder de quince años.
 - Sexto, la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un plazo no superior a quince años.
 - Séptimo, la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario, que no podrá exceder de cinco años.
- En cuanto a la **pena de multa por cuotas**, el art. 50.3 dispone que la misma tendrá una extensión máxima de cinco años mientras que la cuota diaria tendrá un mínimo de treinta y un máximo de cinco mil euros.
- Por otro lado, el art. 53.5 dispone que si la persona jurídica no satisficiera voluntariamente o en vía de apremio la multa impuesta en el plazo señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.
- En cuanto a la **pena de multa proporcional**, el art. 52.4 dispone que siempre que se prevea la imposición de la multa en proporción al beneficio obtenido o facilitado, el perjuicio causado, el valor del objeto del delito o la cantidad defraudada o indebidamente obtenida y que no sea posible calcular el importe de la multa conforme a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará esta imposibilidad e impondrá una multa por cuotas en los términos señalados en el precepto.
- En cuanto a la **pena de intervención judicial**, el art. 33. 7 dispone que ésta podrá afectar a la totalidad de la organización o a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. Por otro lado, la intervención se podrá modificar o suspender en cualquier momento con previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal.
- En cuanto a la **clausura de locales o establecimientos y suspensión de actividades**, el art. 33.7 dispone que el Juez de Instrucción podrá también adoptarlas como medidas cautelares durante la instrucción de la causa.

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN

- En cuanto a los criterios de determinación de las penas, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010 dispone que la multa será la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad penal de personas jurídicas mientras que el resto de penas se reservarán para los supuestos cualificados.
- Por otro lado, el art. 66 bis dispone que estas penas se individualizarán conforme a las reglas generales de los apartados 1 a 4 y 6 a 8 del art. 66.1 y las que señalamos a continuación:
 - En primer lugar, para decidir sobre la imposición y extensión de las penas previstas en los apartados b) a g) del art. 33.7, se tendrá en cuenta su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva y sus efectos; sus consecuencias económicas y sociales con especial atención a sus efectos para los trabajadores y el puesto ocupado en la estructura de la persona jurídica por la persona física u órgano que incumplió el deber de control.
 - En segundo lugar, las penas previstas en los apartados c) a g) del art. 33.7 y que se impongan con duración limitada no podrán exceder de la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista si el delito hubiere sido cometido por una persona física.
 - En tercer lugar, las penas previstas en los apartados c) a g) del art. 33.7 sólo podrán imponerse por plazo superior a dos años si la persona jurídica fuere reincidente o fuere utilizada como instrumento para la comisión de ilícitos penales. En este sentido, se entenderá que la persona jurídica se utiliza como instrumento para la realización de ilícitos penales cuando su actividad legal sea menos relevante que su actividad ilegal.
 - En cuarto lugar, las penas previstas en los apartados c) a g) del art. 33.7 no podrán imponerse por un plazo superior a dos años cuando la responsabilidad de la persona jurídica se funde en actos de sus empleados sometidos a la autoridad de los mandos de la empresa y se derive del incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave.
 - Por último, las penas de disolución de la persona jurídica o prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito sólo podrán imponerse con carácter permanente en caso de multireincidencia conforme al art. 66.1.5º o si la persona jurídica fuere utilizada como instrumento para la comisión de ilícitos penales. Del mismo modo, esta regla se aplicará también para la imposición de las penas de prohibición de realización de actividades o inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas por tiempo superior a cinco años.
- En cuanto a la **extinción de la responsabilidad penal**, el art. 130.2 dispone lo siguiente:
 - En primer lugar, la transformación, fusión, absorción o escisión de la persona jurídica no extingue su responsabilidad penal sino que ésta se trasladará a la entidad o entidades resultantes. No obstante, el Juez o Tribunal podrá moderar este traslado de la pena a la nueva persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable guarde con ella.
 - En segundo lugar, la disolución encubierta o aparente de la persona jurídica no eximirá de responsabilidad penal. De este modo, se entenderá que existe disolución encubierta o aparente cuando la persona jurídica continúe su actividad económica con identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados o de la mayor parte de ellos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- Pasando a ocuparnos de la responsabilidad civil de las personas jurídicas, conviene señalar que el Código Penal contempla desde su redacción originaria la exigencia de responsabilidad civil directa o subsidiaria a las personas jurídicas en determinados supuestos.

- Por su parte, la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010 introdujo un nuevo supuesto de responsabilidad civil de las personas jurídicas.
- En efecto, el art. 116.3 dispone que *la responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.*

DERECHO PENAL

TEMA 16

TEORÍA DEL CONCURSO: CONCURSO DE LEYES. CONCURSO DE DELITOS. EL DELITO CONTINUADO Y EL DELITO MASA.

TEORÍA DEL CONCURSO

- Al estudiar la teoría del concurso, hay que comenzar señalando que el concepto de concurso viene a englobar dos tipos de situaciones:
 - En primer lugar, el concurso de leyes que se produce cuando un mismo hecho resulta subsumible en dos o más normas penales de las que sólo una es realmente aplicable para evitar la infracción del principio *non bis in ídem*.
 - En segundo lugar, el concurso de delitos que se produce cuando uno o varios hechos dan lugar a una pluralidad de infracciones.

CONCURSO DE LEYES

- En cuanto al concurso de leyes, el Código Penal recurre a una serie de principios para decidir la norma aplicable como son los de especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. En efecto, el art. 8 dispone que *los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:*
 - 1º. *El precepto especial se aplicará con preferencia al general.*
 - 2º. *El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.*
 - 3º. *El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.*
 - 4º. *En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.*
- En cuanto a la **relación de especialidad**, ésta tiene lugar cuando un precepto penal contiene todos los elementos de otro y, además, incorpora un elemento adicional en cuyo caso la ley especial prevalece sobre la ley general.
- En este sentido, la relación de especialidad se produce siempre entre los tipos básicos y los tipos agravados o privilegiados de cada delito como sucede entre el homicidio del art. 138 y el asesinato del art. 139.
- En cuanto a la **relación de subsidiariedad**, ésta tiene lugar cuando un precepto penal sólo es aplicable en defecto de otro ya se declare expresamente la subsidiariedad o ya sea deducible por vía interpretativa en cuyo caso la ley principal prevalece sobre la ley subsidiaria.
- En este sentido, la relación de subsidiariedad se produce en los siguientes supuestos:
 - En primer lugar, cuando dos normas penales protegen un mismo bien jurídico en distintas fases del ataque. De este modo, los delitos de peligro son subsidiarios de los delitos de resultado y las resoluciones manifestadas y la tentativa son subsidiarias del delito consumado.
 - En segundo lugar, cuando un sujeto interviene en un hecho delictivo como autor y como partícipe o realizando conductas de participación de distinta intensidad en cuyo caso la participación es subsidiaria de la autoría y la complicidad lo es de la inducción y de la cooperación necesaria.
 - En tercer lugar, cuando un mismo delito aparece tipificado en su modalidad dolosa y su modalidad imprudente en cuyo caso el delito imprudente es subsidiario del doloso.
- En cuanto a la **relación de consunción**, ésta tiene lugar cuando el contenido de injusto de un delito aparece recogido por otro delito en cuyo caso la ley que consume prevalece sobre la ley consumida.

- En este sentido, la relación de consunción se produce en los siguientes casos:
 - En primer lugar, cuando el sujeto realiza actos posteriores a un primer hecho delictivo que tienden a materializar la ganancia obtenida. De este modo, el delito de estafa absorbe al delito de apropiación indebida de la ganancia obtenida¹.
 - En segundo lugar, cuando un hecho delictivo viene acompañado de conductas típicas características. De este modo, el hurto de uso de vehículos a motor consume al hurto del combustible.
- En cuanto a la **relación de alternatividad**, ésta tiene lugar cuando un hecho delictivo aparece incardinado en varias normas penales en cuyo caso la norma que establezca la pena más grave prevalece sobre la que establezca la pena más leve.
- En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que existe relación de alternatividad entre la estafa con tarjetas de crédito del art. 249 y el delito de utilización de tarjetas de crédito falsas sin haber intervenido en su falsificación del art. 399 bis².

CONCURSO DE DELITOS

- Pasando a ocuparnos del concurso de delitos, hay que señalar que la pluralidad de éstos puede producirse debido a la comisión de una sola acción, dando lugar al concurso ideal, o debido a la comisión de varias acciones, dando lugar al concurso real.

CONCURSO REAL

- En cuanto al concurso real, éste tiene lugar cuando una persona comete varios delitos que son juzgados en un solo proceso o bien en diferentes procesos siempre que pudieran haberse juzgado en uno solo.
 - De este modo, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006 declaró que existe concurso real entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301 y el delito antecedente como sucedería en el caso de que los capitales provengan de un delito de tráfico de drogas³.
 - Del mismo modo, la jurisprudencia ha declarado que existe concurso real entre el delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas y el delito contra la Hacienda Pública en la medida que la falta de tributación de los beneficios de procedencia ilícita imposibilitaría la tributación de las sucesivas inversiones y beneficios generados⁴.
- Por otro lado, hay que señalar que la ley resolvía tradicionalmente el concurso real mediante un sistema de acumulación material con arreglo al cual el culpable debía cumplir todas las penas relativas a los distintos delitos.
- Sin embargo, el Código Penal de 1995 establece un sistema mixto que combina los principios de acumulación material y acumulación jurídica.
- En cuanto a la **acumulación material**, el art. 73 dispone que *al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas*.
- Por su parte, el art. 75 dispone que *cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible*.

- En cuanto a la **acumulación jurídica**, el art. 76 establece las siguientes reglas:
 - 1º. *No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de veinte años. Excepcionalmente, este límite máximo será:*
 - a) *De veinticinco años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta veinte años.*
 - b) *De treinta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - c) *De cuarenta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - d) *De cuarenta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - e) *Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.*
 - 2º. *La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.*
- Por otro lado, el art. 78 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *Si, a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76, la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.*
 - 2º. *En estos casos, el Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable:*
 - a) *Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.*
 - b) *A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.*
- Finalmente, el art. 78 bis establece reglas específicas para el acceso al tercer grado y la suspensión de la ejecución del resto de la pena en caso de que el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con la pena de prisión permanente revisable.
- Del mismo modo, se establecen exigencias más agravadas para el caso de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo.

- En cuanto a los **efectos de la acumulación jurídica en los beneficios penitenciarios**, se ha planteado la cuestión de determinar si los límites del art. 76 suponen la refundición de todas las penas impuestas en una pena nueva o si cada una de ellas mantienen su autonomía
 - En relación con esta cuestión, la jurisprudencia declaró tradicionalmente que la pena resultante de la acumulación debía estimarse una pena nueva y autónoma a efectos de permisos de salida y demás beneficios penitenciarios⁵.
 - Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 introdujo la llamada doctrina Parot, conforme a la cual las penas resultantes de la acumulación no debían estimarse una pena nueva por lo que los beneficios penitenciarios deberían aplicarse sucesivamente a cada una de las penas acumuladas hasta alcanzar el límite máximo de cumplimiento del art. 76.
 - Finalmente, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de julio de 2012, relativa al caso Del Río Prada, declaró la vulneración de los arts. 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por la aplicación retroactiva de un cambio jurisprudencial no previsible al tiempo de comisión de los hechos.

CONCURSO IDEAL

- Pasando a ocuparnos del concurso ideal, el art. 77.1 dispone que *lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro*.
- En este sentido, distinguiremos entre el concurso ideal en sentido propio y concurso medial.
- En cuanto al **concurso ideal en sentido propio**, éste tiene lugar cuando una acción produce varias infracciones como sucede cuando una persona comete una violación y causa lesiones a la víctima en el curso de la misma.
 - En relación con él, el apartado 2 dispone que *se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado*.
 - En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que la comparación entre las penas deberá realizarse en concreto y valorando las reglas de individualización relativas al grado de ejecución, el grado de participación y circunstancias modificativas⁶.
- En cuanto al **concurso medial**, éste tiene lugar cuando un delito constituye el medio necesario para cometer otro delito distinto como sucede cuando el delito de allanamiento de morada se comete como medio para cometer un delito contra el patrimonio.
- En relación con estos casos, el apartado 3 dispone que *se impondrá una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el Juez o Tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior*.
 - Por su parte, la Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2015 sostiene que el art. 77 castiga el concurso medial con una pena híbrida o pena síntesis situada entre la pena concreta que se impondría por el delito más grave y la suma de la pena concretas que se impondrían a cada uno de los delitos por separado.
 - De este modo, el Juez o Tribunal individualizará la pena dentro de estos límites y en función de los criterios generales de la regla 6ª del art. 66.1 como son la gravedad del hecho y las circunstancias personales del delincuente. Sin embargo, no se aplicarán las reglas específicas del art. 66 cuya funcionalidad se haya agotado para la construcción de los límites máximo y mínimo de la pena síntesis.

EL DELITO CONTINUADO

- Pasando a ocuparnos del delito continuado éste tiene lugar cuando la ley unifica a efectos de penalidad una serie de conductas que, en caso contrario, se sancionarían como infracciones distintas según las reglas del concurso real.
- En este sentido, el art. 74 del Código Penal dispone lo siguiente:
 - 1º. *No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito continuado con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.*
 - 2º. *Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.*
- En cuanto a sus **requisitos**, la doctrina viene exigiendo los siguientes:
 - En primer lugar, será necesario que el sujeto haya realizado una pluralidad de acciones u omisiones con independencia de que ofendan a uno o varios sujetos pasivos y de la posible intervención de terceros en alguna de ellas.
 - En segundo lugar, será necesario que todas las acciones u omisiones estén enlazadas por un plan preconcebido o que se cometan aprovechando idéntica ocasión por lo que será necesaria una cierta conexión espacial y temporal entre ellas.
 - En tercer lugar, será necesario que todas las acciones u omisiones infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza.
 - En cuarto lugar, será necesario que las acciones u omisiones no atenten contra bienes jurídicos eminentemente personales salvo que se trate de infracciones contra el honor o contra la libertad sexual que afecten al mismo sujeto pasivo en cuyo caso la continuidad delictiva podrá apreciarse en función de la naturaleza del hecho y del precepto infringido.
 - Por último, será indiferente que alguna de las acciones se hubiere realizado en grado de tentativa⁷. Por otro lado, las circunstancias agravantes que concurran en alguna de las acciones u omisiones se aplicarán al delito continuado en su conjunto⁸.

EL DELITO MASA

- Pasando a ocuparnos del delito masa, se trata de aquella modalidad de delito continuado que tiene lugar cuando un sujeto realiza una pluralidad de acciones u omisiones que, aisladamente consideradas, serían constitutivas de varios delitos contra el patrimonio a través de las cuales se defrauda a una pluralidad de personas.
- En este sentido, el art. 74.2 dispone que *si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones, el Juez o Tribunal impondrá motivadamente la pena superior en uno o dos grados en la extensión que estime conveniente si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.*

- En relación con este precepto, se planteó la cuestión de determinar si el mismo es compatible con el apartado 1 del art. 74 o, lo que es lo mismo, si los delitos masa o delitos continuados patrimoniales deben castigarse siempre con la pena señalada para la infracción más grave en su mitad superior además de sancionarse en función del perjuicio total causado.
 - En este sentido, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007 declaró que los dos apartados del art. 74 son compatibles salvo que ello comporte infracción del principio *non bis in idem*.
 - Por tanto, no procederá la aplicación de la pena en su mitad superior cuando el tipo aplicado en función del perjuicio total causado sea un tipo agravado por la cuantía. Sin embargo, sí procederá la aplicación de la pena en su mitad superior cuando uno o varios de los hechos integrantes del delito continuado alcance cuantía suficiente para integrar el tipo agravado.

¹ STS 21 de octubre de 2011.

² STS 21 de septiembre de 2011.

³ STS 1 de diciembre de 2006.

⁴ SSTS 7 de diciembre de 1996 y 23 de febrero de 2007.

⁵ STS 15 de septiembre de 2005.

⁶ SSTS 19 de septiembre de 1996 y 31 de enero de 2000.

⁷ SSTS 28 de abril de 1994 y 4 de febrero de 2000.

⁸ STS 7 de febrero de 2005.

DERECHO PENAL

TEMA 17

LA PENA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES. CLASES DE PENAS. LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

LA PENA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES

- Al estudiar el concepto de la pena, siguiendo a Cuello Calón, podemos comenzar definiéndola como la *privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al culpable de una infracción penal*.
- En cuanto a sus **caracteres**, podemos destacar los siguientes:
 - Primero, su origen legal. En este sentido, el art. 2 del Código Penal dispone que *no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad*.
 - Segundo, su carácter jurisdiccional. En este sentido, el art. 3.1 dispone que *no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales*.
 - Tercero, su proporcionalidad a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor. En este sentido, el art. 5 dispone que *no hay pena sin dolo o imprudencia*.
 - Por último, su carácter humanitario. En efecto, el art. 15 de la Constitución dispone que *todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra*.
- En cuanto a su **fundamento**, siguiendo a Jescheck, distinguimos entre una justificación política, consistente en la necesidad de mantener el orden jurídico como condición de la convivencia en comunidad; una justificación social, consistente en la necesidad de satisfacer las demandas de justicia de la comunidad y una justificación ética, consistente en la necesidad de satisfacer la aspiración del delincuente a liberarse de culpa mediante una prestación de carácter expiatorio.
- En cuanto a sus **finés**, distinguimos entre teorías absolutas y relativas.
 - En cuanto a las **teorías absolutas**, representadas por autores como Kant y Hegel, éstas sostienen que el fin de la pena es retribuir el mal causado por el delincuente conforme a un principio de justicia distributiva.
 - En cuanto a las **teorías relativas**, éstas distinguen la prevención general, consistente en la amenaza de pena dirigida a los miembros de la sociedad para que se abstengan de delinquir y la prevención especial, consistente en la actuación sobre la persona que comete un delito para evitar que vuelva a delinquir.

En cuanto a los **finés constitucionales de la pena**, el art. 25 de la Constitución dispone que *las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados*.

CLASES DE PENAS

- En cuanto a las clases de penas, podemos manejar distintos criterios de clasificación.
- En cuanto a su **formulación**, distinguimos entre penas únicas, conjuntas y alternativas según el tipo penal establezca una sola pena o establezca varias de forma que el Juez deba imponer todas o elegir una de ellas.
- En cuanto a su **autonomía**, distinguimos entre penas principales y accesorias según vengan establecidas por la ley para cada delito o su imposición se derive de la imposición de una pena principal.
- En cuanto a la **naturaleza del bien jurídico afectado**, el art. 32 dispone que *las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código bien con carácter principal bien como accesorias son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa*.

- En cuanto a su **gravedad**, el art. 33 dispone que son penas graves:
 - Primero, la prisión permanente revisable.
 - Segundo, la prisión superior a cinco años.
 - Tercero, la inhabilitación absoluta.
 - Cuarto, las inhabilitaciones especiales y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
 - Quinto, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
 - Sexto, la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos por tiempo superior a cinco años.
 - Séptimo, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que el Juez o Tribunal determine por tiempo superior a cinco años.
 - Por último, la privación de la patria potestad.
- Por otro lado, el art. 33 dispone que son penas menos graves las siguientes:
 - Primero, la prisión de tres meses a cinco años.
 - Segundo, las inhabilitaciones especiales y la suspensión de empleo o cargo público de hasta cinco años.
 - Tercero, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
 - Cuarto, la inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
 - Quinto, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos de seis meses a cinco años.
 - Sexto, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que el Juez o Tribunal determine de seis meses a cinco años.
 - Séptimo, la multa de más de tres meses y la multa proporcional con independencia de su cuantía excepto las impuestas a personas jurídicas.
 - Por último, los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
- Por su parte, el art. 33 dispone que son penas leves las siguientes:
 - Primero, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de tres meses a un año.
 - Segundo, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
 - Tercero, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
 - Cuarto, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo inferior a seis meses.
 - Quinto, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los familiares u otras personas que el Juez o Tribunal determine de un mes a menos de seis meses.
 - Sexto, la multa de hasta tres meses.
 - Séptimo, la localización permanente de un día a tres meses.
 - Por último, los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.
- Finalmente, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa será menos grave o leve en función de la pena a la que sustituya.

- Finalmente, el art. 34 dispone que *no se reputarán penas:*
 - 1º. *La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.*
 - 2º. *Las multas y demás correcciones que, en uso de sus atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.*
 - 3º. *Las privaciones de derechos y las sanciones reparatoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.*

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- Pasando a ocuparnos de las penas privativas de libertad, el art. 35 dispone que *son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.*

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

- En cuanto a la prisión permanente revisable, el art. 36 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.*
 - 2º. *La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico favorable e individualizado de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código; b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva en el resto de los casos.*
 - 3º. *En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión en el caso previsto en la letra a) y ocho años de prisión en el previsto en la letra b).*
- En cuanto a la **prisión permanente revisable en casos de concurso de delitos**, el art. 78 bis dispone que si el penado ha sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno está castigado con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado exigirá cumplir los siguientes plazos de prisión:
 - Primero, dieciocho años si uno de los delitos está castigado con prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas suman más de cinco años.
 - Segundo, veinte años si uno de los delitos está castigado con prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas suman más de quince años.
 - Tercero, veintidós años si dos o más delitos están castigados con prisión permanente revisable o bien uno está castigado con prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas suman veinticinco o más años.
- Por otro lado, la suspensión de la ejecución del resto de la pena exigirá en estos casos que el penado haya extinguido un mínimo de veinticinco años de prisión en los dos primeros casos y de treinta años en el tercero.
- Finalmente, se establecen unos plazos más prolongados para la progresión a tercer grado y la suspensión de la ejecución en el caso de condenados por delitos de terrorismo o delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas u organizaciones criminales.

- En cuanto a la **legitimidad de esta pena**, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la prisión perpetua no vulnera la prohibición de las penas o tratos inhumanos o degradantes del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos siempre que ley interna permita la conmutación, remisión, liberación condicional o terminación¹.
- Por otro lado, la misma jurisprudencia sostiene que el hecho de que un recluso haya cumplido un periodo largo de prisión no debilita la obligación del Estado de proteger a la sociedad por lo que el Estado podrá mantener al recluso en prisión mientras continúe representando un peligro para aquélla².
 - Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021 declaró que esta pena no vulnera el derecho fundamental a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes del art. 15 de la Constitución porque no abarca toda la vida del reo; porque le ofrece una esperanza realista de recuperar la libertad; porque cuenta con un procedimiento claro y cognoscible para recuperarla y porque tiene en cuenta la evolución del reo durante la ejecución de la pena.
 - Finalmente, la misma jurisprudencia declaró que la prisión permanente revisable no es desproporcionada ni vulnera el derecho fundamental a la libertad del art. 17 ni el principio de legalidad penal del art. 25.1 ni los principios de reeducación y reinserción social del art. 25.2 de la Constitución.
- En cuanto a la **suspensión de la ejecución**, el art. 92 dispone que el Tribunal la acordará en un procedimiento contradictorio con intervención del Ministerio Fiscal y el penado asistido por su Abogado si concurren los siguientes requisitos:
 - Primero, que el penado haya cumplido veinticinco años de condena sin perjuicio de la posibilidad de progresión a tercer grado en los casos previstos en el art. 78 bis.
 - Segundo, que el penado se encuentre clasificado en tercer grado.
 - Tercero, que el Tribunal pueda emitir un pronóstico favorable de reinserción social del penado conforme a determinadas circunstancias como su personalidad y antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados en caso de reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento de la condena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución y de las medidas impuestas y todo ello, a la vista de los informes del centro penitenciario y los especialistas que el Tribunal determine.
 - Por último, tratándose de condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, se establecen unos requisitos específicos de abandono de la actividad terrorista y colaboración con las autoridades.
- En cuanto a la **duración de la suspensión**, ésta tendrá una duración de cinco a diez años y se contará desde la fecha de la puesta en libertad del penado.
- Por su parte, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la suspensión y la libertad condicional cuando exista un cambio de las circunstancias que dieron lugar a aquéllas y no sea posible mantener el pronóstico de falta de peligrosidad del penado.
- En cuanto a la **libertad condicional**, ésta podrá concederse de oficio o a instancia del penado.
 - En efecto, el art. 92.4 dispone que el Tribunal verificará cada dos años el cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional una vez extinguida la parte de la condena a que se refieren el art. 78 bis o el art. 92.1. De igual modo, el Tribunal resolverá las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado pero podrá fijar un plazo no superior a un año en el que no se dará curso a nuevas solicitudes.
 - Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sostiene que el precepto citado resulta también aplicable a los penados que hayan reingresado en prisión después de la revocación de la libertad condicional³.

LA PRISIÓN

- Pasando a ocuparnos de la pena de prisión, el art. 36.2 establece las siguientes reglas:
 - 1º. *La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.*
 - 2º. *Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.*
 - 3º. *En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código; b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal; c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código cuando la víctima sea una persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección; d) Delitos del artículo 181; e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código cuando la víctima sea menor de dieciséis años.*
 - 4º. *En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de prisión la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.*
 - 5º. *La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el apartado anterior.*
 - 6º. *En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad.*

LA LOCALIZACIÓN PERMANENTE

- En cuanto a la pena de localización permanente, el art. 37 establece las siguientes reglas:
 - 1º. *La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado.*
 - 2º. *Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el Ministerio Fiscal, el Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada.*
 - 3º. *Si el condenado incumpliere la pena, el Juez o Tribunal sentenciador deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el art. 468.*
 - 4º. *Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.*

- Finalmente, conviene señalar que el cumplimiento de la pena de localización permanente en centro penitenciario aparece regulado en el Real Decreto 840/2011.

LA RESONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIRIA

- En cuanto a la responsabilidad personal subsidiaria, el art. 53 dispone lo siguiente:
 - 1º. *Si el condenado no satisficiera voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el artículo 37.*
 - 2º. *También podrá el Juez o Tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo.*
 - 3º. *En los supuestos de multa proporcional, los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder en ningún caso de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.*
 - 4º. *Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.*
 - 5º. *El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa aunque mejore la situación económica del penado.*

REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- En cuanto a las reglas generales aplicables a las penas privativas de libertad, el Código Penal establece las siguientes.
- En cuanto al **cómputo de la pena**, el art. 38 dispone que *cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme. Cuando el resto no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.*
- En cuanto al **abono de la prisión provisional**, el art. 58 dispone lo siguiente:
 - 1º. *El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.*
 - 2º. *El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del Ministerio Fiscal.*
 - 3º. *Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar.*
 - 4º. *Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.*

- Por su parte, el art. 59 dispone que *cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada*.
- En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que la compensación procede en casos como los siguientes⁴:
 - Primero, cuando la medida cautelar y la pena impuesta afectan a un mismo derecho con intensidad diferente como sucede con la compensación de la medida de comparecencia periódica ante el Tribunal con la pena de prisión. En este sentido, la jurisprudencia ha admitido esta compensación a raíz de un día de prisión por cada diez comparecencias⁵.
 - Segundo, cuando la medida cautelar y la pena impuesta afectan a derechos diferentes como sucede con la compensación de la medida de prisión provisional con la pena de multa. En este sentido, la compensación se realizará a razón de un día de prisión por cada dos cuotas de multa y con independencia de que el penado sea o no insolvente⁶.

¹ SSTEDH 12 de febrero de 2008 (Caso Kafkaris).

² STEDH 15 de diciembre de 2009 (Caso Majorano y otros).

³ STC 169/2021, de 6 de octubre.

⁴ STS 20 de mayo de 2021.

⁵ Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013 y STS 7 de enero de 2014.

⁶ STS 13 de marzo de 2024.

DERECHO PENAL

TEMA 18

LA PENA DE MULTA. LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS PROHIBICIONES DE APROXIMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA Y DE RESIDENCIA EN DETERMINADOS LUGARES EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. LAS PENAS ACCESORIAS.

LA PENA DE MULTA

- Al estudiar la pena de multa, siguiendo a Cuello Calón, podemos comenzar definiendo la pena como la *privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al culpable de una infracción penal*.
 - En este sentido, el art. 32 del Código Penal dispone que *las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa*.
 - En relación con la pena de multa, hay que señalar que el Código Penal contempla dos modalidades como son el sistema de días-multa y el sistema de multa proporcional.

SISTEMAS DE DÍAS-MULTA

- En cuanto al sistema de días-multa, se trata de un método de individualización de la pena con el que se pretende graduar su intensidad afflictiva en función de la capacidad económica del reo. En relación con él, el art. 50 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria.*
 - 2º. *La pena de multa se impondrá, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa.*
 - 3º. *Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.*
 - 4º. *La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de cuatrocientos euros, excepto en el caso de las multas imponibles a personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de treinta y un máximo de cinco mil euros.*
 - 5º. *A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.*
 - 6º. *Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia el importe de estas cuotas teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.*
 - 7º. *El Tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.*
- En cuanto a la **individualización de la pena**, hay que señalar que el número de días multa se fijará en función de la gravedad del delito y las reglas generales de individualización del art. 66.
 - Por otro lado, la jurisprudencia y la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2004 han declarado que la fijación del importe de las cuotas no exigirá una investigación exhaustiva de la situación económica del reo sino que bastará considerar aquellos datos esenciales de los que pueda inferirse una ponderación razonable de la cuota¹.
 - Por su parte, la cuota mínima deberá reservarse para los casos de indigencia mientras que, en los demás casos, procederá la aplicación de una cuota situada en el tramo inferior y próxima al mínimo sin necesidad de mayor justificación en la sentencia.
- En cuanto a la **modificación del importe de las cuotas**, el art. 51 dispone que *si después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago*.

SISTEMAS DE MULTA PROPORCIONAL

- En cuanto a la multa proporcional, el art. 52 establece las siguientes reglas:
 - 1º. *No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo.*
 - 2º. *En estos casos, los Jueces y Tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito considerando, para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho sino principalmente la situación económica del culpable.*
 - 3º. *Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate o autorizar su pago en los plazos que se determinen.*
- Finalmente, el Código Penal contempla el sistema de multa proporcional para delitos como el blanqueo de capitales del art. 301, el tráfico de drogas del art. 368 y el cohecho del art. 419.

LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS

- Pasando a ocuparnos de las penas privativas de derechos, éstas aparecen recogidas en el art. 39 mientras que su duración se recoge en el art. 40 conforme señalamos a continuación.
- En cuanto a la **inhabilitación absoluta**, el art. 41 señala que *la pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena.*
- Por otro lado, su duración será de seis a veinte años.
- En cuanto a la **inhabilitación especial**, dentro de ella distinguimos las siguientes clases:
 - Primero, el art. 42 dispone que *la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere aunque sea electivo y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.*
 - Segundo, el art. 44 dispone que *la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.*
 - Tercero, el art. 45 dispone que *la inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.*
 - Por último, el art. 46 dispone que *la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena.*
- Por otro lado, la duración de estas penas será de tres meses a veinte años.

- En cuanto a la **suspensión de empleo o cargo público**, el art. 43 dispone que *la suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena.*
- Por otro lado, su duración será de tres meses a seis años.
- En cuanto a la **privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores**, el art. 47 dispone que *la imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.*
- Por otro lado, su duración será de tres meses a diez años.
- En cuanto a la **privación del derecho a la tenencia y porte de armas**, el art. 47 dispone que *la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.*
- Por otro lado, su duración será de tres meses a diez años.
- En cuanto a lo **trabajos en beneficio de la comunidad**, el art. 49 dispone que *los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.*
- Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:
 - 1º. *La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a tal efecto, podrá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.*
 - 2º. *No atentará a la dignidad del penado.*
 - 3º. *El trabajo en beneficio de la comunidad será proporcionado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.*
 - 4º. *Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.*
 - 5º. *No se supeditará al logro de intereses económicos.*
- Por otra parte, se establece que los servicios sociales penitenciarios comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes en la ejecución de la pena y, en todo caso, la ausencia del penado durante al menos dos jornadas laborales siempre que implique el rechazo voluntario al cumplimiento de la pena.
- Del mismo modo, también se comunicará al Juez de Vigilancia Penitenciaria el rendimiento del penado sensiblemente inferior al mínimo exigible; la oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto de instrucciones del responsable y la conducta por la que el responsable se niegue a mantener al penado en el centro.
 - Por su parte, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar que el penado cumpla la pena en el mismo centro o en otro centro distinto o bien entender que ha incumplido la pena en cuyo caso deducirá testimonio para proceder por delito de quebrantamiento de condena conforme al art. 468.
 - Por otro lado, se establece que las faltas justificadas del penado no se estimarán como abandono de la actividad si bien el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena en la que se harán constar los días efectivamente trabajados del total que se le hubiera impuesto.
- Por otra parte, conviene señalar que el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad aparece regulado en el Real Decreto 840/2011.
- Por otro lado, la duración de la pena será de un día a un año.

- Finalmente, hay que señalar la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2020 que declaró que el Juez o Tribunal que conozca de un delito castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad deberá recabar el consentimiento del reo para la imposición de esta pena y, si no es posible, el fallo deberá condicionar la ejecución de la pena al consentimiento del condenado y deberá prever también la imposición subsidiaria de la pena alternativa para el caso de que aquél no preste su consentimiento.
- En cuanto a la **privación de la patria potestad**, el art. 46 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo de la persona condenada.*
 - 2º. *Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias del caso concreto.*
 - 3º. *A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.*

ESPECIAL REFERENCIA A LAS PROHIBICIONES DE APROXIMACIÓN Y COMUNICACIÓN...

- Pasando a ocuparnos de las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima y de residencia en determinados lugares en los delitos de violencia doméstica y de género, el art. 48 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o a aquél en que resida la víctima o su familia si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.*
 - 2º. *La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal impide al penado acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellas, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.*
 - 3º. *La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.*
- En relación con este precepto, conviene señalar que, tratándose de la privación del derecho a residir a determinados lugares o acudir a ellos, la sentencia deberá especificar los lugares a los que el penado no pueda acudir o en los que no pueda fijar su residencia.
- Por otro lado, tratándose de la prohibición de comunicación, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2019 declaró que existirá delito consumado de quebrantamiento de la condena por el mero hecho de llamar al teléfono de la persona protegida aunque la llamada no haya sido atendida pero siempre que pueda identificarse su procedencia.

- En cuanto al **control del cumplimiento de estas penas**, el art. 48 dispone que *el Juez o Tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.*
- En cuanto al **consentimiento de la víctima**, se planteó la cuestión de determinar la relevancia de este consentimiento a efectos de apreciación del delito de quebrantamiento de condena.
 - En este sentido, el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008 declaró que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal en el caso de quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento.
 - Por otro lado, la misma jurisprudencia sostiene que el consentimiento de la víctima no operará tampoco como atenuante analógica².

LAS PENAS ACCESORIAS

- Pasando a ocuparnos de las penas accesorias, el art. 54 dispone que *las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la ley declare que otras penas las llevan consigo.*
- Por su parte, el art. 33.6 dispone que *la pena accesoria tendrá la misma duración que la pena principal a la que acompañe salvo lo dispuesto expresamente en otros preceptos del Código Penal.*

PENAS ACCESORIAS A LA PENA DE PRISIÓN

- En cuanto a las penas accesorias de la pena de prisión, distinguimos dos supuestos:
 - En primer lugar, tratándose de penas de prisión igual o superior a diez años, el art. 55 dispone que ésta llevará consigo la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena salvo que estuviere prevista como pena principal para el delito. No obstante, el Juez podrá imponer también la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o bien la privación de la patria potestad cuando tales derechos tuvieren relación directa con el delito cometido y así se establezca en la sentencia.
 - En segundo lugar, tratándose de penas de prisión inferiores a diez años, el art. 56 dispone que los Jueces o Tribunales impondrán como penas accesorias, en función de la gravedad del delito, alguna o algunas de las penas de suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo o inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o privación de la patria potestad, cuando tales derechos tuvieren relación directa con el delito cometido y así se establezca en la sentencia.

PENAS ACCESORIAS POR LA COMISIÓN DE DETERMINADOS DELITOS

- En cuanto a las penas accesorias por la comisión de determinados delitos, el art. 57 dispone que tratándose de delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad sexual, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares, el Juez o Tribunal podrá imponer una o varias de las prohibiciones del art. 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito es grave o de cinco años si el delito es menos grave y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos o el peligro representado por el delincuente.

- No obstante, si la pena impuesta fuera de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en el caso de que el delito fuera grave y entre uno y cinco años si fuera menos grave.
- Finalmente, la pena de prisión y las prohibiciones citadas se cumplirán de forma simultánea.
- En cuanto a los **supuestos de violencia doméstica**, el art. 57 dispone que si los delitos se hubieran cometido contra determinadas personas del círculo familiar del condenado, el Juez o Tribunal acordará en todo caso la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que el mismo órgano determine por un plazo que no excederá de diez años si el delito fuere grave o cinco años si fuere menos grave.
 - En este sentido, será necesario que el delito se cometa contra quien sea o haya sido el cónyuge del condenado o persona que esté o haya estado ligado a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
 - Finalmente, estas prohibiciones podrán también imponerse por la comisión de delitos leves de los citados en el apartado 1 por un plazo que no excederá de seis meses.

¹ STS 11 de julio de 2001.

² STS 14 de enero de 2020.

DERECHO PENAL

TEMA 19

LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS: EL DECOMISO. MEDIDAS APLICABLES A LAS AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA.

LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS

- Al estudiar las consecuencias accesorias, hay que comenzar señalando que el Código Penal incluye en esta denominación una serie de consecuencias de la comisión de un delito que no revisten el carácter de penas ni medidas de seguridad como son el decomiso; las medidas aplicables a agrupaciones sin personalidad jurídica y la toma de muestras biológicas para la obtención de identificadores de ADN.

EL DECOMISO

- En cuanto al decomiso, art. 127 del Código Penal establece las siguientes reglas:
 - 1º. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.*
 - 2º. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.*

CLASES

- En cuanto a las clases de decomiso, distinguimos tres modalidades como son el de los bienes, medios o instrumentos del delito; el de los efectos procedentes del delito y el de las ganancias obtenidas por el mismo.
 - Por su parte, la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015 ha establecido una regulación novedosa del decomiso en la que se incluyen también el decomiso por valor equivalente, el decomiso ampliado, el decomiso en supuestos de actividad delictiva continuada previa y el decomiso sin sentencia condenatoria.
 - Por otro lado, el Código Penal establece también una regulación especial del decomiso para algunos delitos como el blanqueo de capitales, los delitos de tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad vial. De igual modo, también el decomiso viene regulado en leyes penales especiales como la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
- En cuanto al **decomiso de bienes, medios e instrumentos del delito**, la doctrina sostiene que el decomiso cumple en este caso una finalidad de prevención especial dirigida a evitar la peligrosidad de los instrumentos del delito en manos del delincuente.
 - Por su parte, la jurisprudencia sostiene que el concepto deberá interpretarse de forma restrictiva por lo que sólo serán decomisables los bienes, medios o instrumentos que constituyan de forma próxima y directa un medio necesario para la comisión del delito¹.
 - De este modo, tratándose de delitos de tráfico de drogas, no procederá el decomiso de los vehículos utilizados a menos que se hayan empleado de forma insustituible como lugar de ocultación o como auxilio necesario para el transporte de la droga².
- En cuanto al **decomiso de efectos del delito**, la doctrina sostiene que el decomiso cumple también en este caso una finalidad de prevención especial.
- Por su parte, la jurisprudencia ha declarado que el concepto incluye cualquier objeto que se encuentre en poder del delincuente de forma mediata o inmediata como consecuencia de la infracción³.

- En cuanto al **decomiso de ganancias del delito**, la doctrina sostiene que el decomiso cumple en este caso la finalidad de evitar un enriquecimiento ilícito del delincuente⁴.
 - Por otro lado, este decomiso se extiende no sólo a las ganancias directas derivadas del delito sino también a las ganancias indirectas obtenidas mediante la transformación de las primeras, dando lugar al llamado decomiso subrogatorio.
 - En este sentido, tratándose de delitos de tráfico de drogas, la jurisprudencia considera prueba suficiente para acordar el decomiso de las ganancias la dedicación estable del sujeto al tráfico de drogas y la inexistencia de patrimonio o actividades económicas lícitas que puedan justificar el incremento patrimonial⁵.

LÍMITES

- En cuanto a los límites del decomiso, la jurisprudencia ha declarado que su imposición está sujeta a una serie de garantías como el principio acusatorio y el principio de contradicción⁶.
 - Por otro lado, la resolución que lo acuerde deberá ser motivada y apreciar la conexión entre el delito cometido y el bien decomisado salvo en los supuestos excepcionales previstos en el Código Penal⁷.
 - Por otra parte, el Código Penal establece unos límites adicionales como el principio de proporcionalidad y el principio de respeto a los derechos de terceros de buena fe.
- En cuanto al **principio de proporcionalidad**, el art. 128 dispone que *cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente*.
- En cuanto al **principio de respeto a los terceros de buena fe**, el art. 127 quater dispone que los Jueces o Tribunales podrán acordar el decomiso de los bienes, efectos y ganancias transferidos a terceras personas o de bienes por un valor equivalente en los siguientes casos:
 - En primer lugar, tratándose de efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar en función de las circunstancias del caso de su origen ilícito.
 - En segundo lugar, tratándose de otros bienes distintos, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar en función de las circunstancias del caso de que de ese modo se dificultaba su decomiso.
- Por su parte, el apartado 2 dispone que se presumirá salvo prueba en contrario que el tercero tuvo motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que se transferían para evitar su decomiso cuando los bienes o efectos hayan sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al precio real de mercado.

DECOMISO IMPROPIO O POR VALOR EQUIVALENTE

- En cuanto al decomiso por valor equivalente, el art. 127.3 dispone que *si por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo, se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición*.

- En relación con este precepto, hay que señalar que el decomiso podrá recaer sobre bienes pertenecientes a personas distintas del responsable del delito a diferencia de la situación existente hasta la reforma aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 en la que se exigía que los bienes pertenecieran a los criminalmente responsables del hecho.
- Por otro lado, la imposibilidad del decomiso propio puede responder a múltiples causas como el hecho de que los bienes hayan sido transferidos a terceros de buena fe.

DECOMISO AMPLIADO

- En cuanto al decomiso ampliado, el art. 127 bis dispone que el Juez o Tribunal ordenará el decomiso de los bienes, efectos y ganancias de los condenados por una serie de delitos cuando estime en virtud de indicios objetivos y fundados que provienen de una actividad ilícita y no se acredite su origen lícito.
- Por su parte, el apartado 2 dispone que se valorarán especialmente los siguientes indicios:
 - Primero, la desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito del condenado.
 - Segundo, la ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad interpuestos o mediante la utilización de paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
 - Tercero, la transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.
- Finalmente, se establecen las siguientes reglas aplicables al decomiso ampliado:
 - En primer lugar, si el penado fuera posteriormente condenado por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad al decomiso, el Juez o Tribunal valorará el alcance del decomiso anterior para resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.
 - En segundo lugar, no se acordará el decomiso cuando el delito del que provengan los bienes o efectos esté prescrito o haya sido objeto de otro proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.
 - Finalmente, también se aplicará en este caso el decomiso por valor equivalente al que se refiere el apartado 3 del art. 127.

DECOMISO SIN CONDENA

- En cuanto al decomiso sin condena, el art. 127 ter dispone que el Juez o Tribunal podrá acordar el decomiso aunque no medie sentencia condenatoria si la situación patrimonial ilícita queda acreditada en un proceso contradictorio y concurre alguno de los siguientes supuestos:
 - Primero, que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos.
 - Segundo, que el sujeto se encuentre en rebeldía y ello impida el enjuiciamiento de los hechos en un plazo razonable.
 - Tercero, que no se imponga pena al sujeto por estar exento de responsabilidad penal o por haberse extinguido.
- Por su parte, el apartado 2 dispone que este decomiso sólo podrá acordarse contra personas formalmente acusadas o imputados sobre los que existan indicios racionales de criminalidad y cuando las situaciones descritas hayan impedido la continuación del proceso penal.

DECOMISO DE BIENES PROCEDENTES DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA

- En cuanto al decomiso de bienes derivados de otras actividades delictivas previas, el art. 127 quinquies dispone que los Jueces o Tribunales podrán acordar el decomiso de bienes, efectos y ganancias procedentes de la actividad delictiva previa del condenado siempre que concurren los siguientes requisitos:
 - Primero, que el sujeto haya sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el apartado 1 del art. 127 bis.
 - Segundo, que el delito se haya cometido en el marco de una actividad delictiva previa y continuada.
 - Tercero, que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa.
- Por otro lado, se entenderá que el delito se cometió en el contexto de una actividad delictiva continuada siempre que concorra alguno de los siguientes supuestos:
 - Primero, que el sujeto sea o haya sido condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos de los que se haya derivado un beneficio económico directo o indirecto o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones penales de las que se haya derivado un beneficio económico directo o indirecto.
 - Segundo, que en el plazo de los seis años anteriores al inicio del procedimiento en el que haya sido condenado por alguno de los delitos previstos en el apartado 1 del art. 127 bis, el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de los que se haya derivado un beneficio económico o por un delito continuado que incluya, al menos, dos infracciones penales de las que haya obtenido un beneficio económico.
- Finalmente, se establece que son indicios relevantes de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa los siguientes:
 - Primero, la desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito del condenado.
 - Segundo, la ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad interpuestos o mediante la utilización de paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
 - Tercero, la transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.
- Finalmente, esta regla sólo se aplicará cuando existan indicios fundados de que el sujeto haya obtenido a partir de su actividad delictiva un beneficio superior a 6000 euros.
- En cuanto a las **presunciones legales**, el art. 127 sexies dispone que a los efectos del artículo anterior, se aplicarán las siguientes presunciones:
 - En primer lugar, se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado en los seis años anteriores a la fecha de apertura del procedimiento penal proceden de su actividad delictiva. En este sentido, se entenderá que los bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en que conste que el sujeto haya dispuesto de ellos.
 - En segundo lugar, se presumirá que todos los gastos realizados por el condenado en el periodo anterior se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.
 - En tercer lugar, se presumirá que todos los bienes citados fueron adquiridos libres de cargas.
- Finalmente, el Juez o Tribunal podrá acordar la inaplicación de estas presunciones en relación con ciertos bienes, efectos o ganancias cuando resulten incorrectas o desproporcionadas en función de las circunstancias del caso.

EJECUCIÓN DEL DECOMISO

- Pasando a ocuparnos de la ejecución del decomiso, el Código Penal establece una serie de reglas en los términos que exponemos a continuación.
- En cuanto al **decomiso por sustitución**, el art. 127 septies dispone que si el decomiso no hubiera podido ejecutarse en todo o en parte por la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias o por cualquier otra circunstancia, el Juez o Tribunal podrá acordar por medio de auto el decomiso de otros bienes de los responsables penales del hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso acordado y aunque se trate de bienes de origen lícito.
- Por otro lado, el Juez o Tribunal podrá también proceder de este modo cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.
- En cuanto a la **garantía del decomiso y el destino de los bienes**, el art. 127 octies dispone que para garantizar la efectividad del decomiso, el Juez o Tribunal podrá ordenar el embargo, aprehensión o depósito de los bienes, medios, instrumentos y ganancias desde las primeras diligencias.
 - De igual modo, el Juez o Tribunal resolverá sobre la realización anticipada o utilización provisional de los efectos intervenidos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 - Finalmente, los bienes decomisados por resolución firme se adjudicarán al Estado salvo que deban aplicarse al pago de indemnizaciones a las víctimas. Por su parte, el Estado les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.

MEDIDAS APLICABLES A LAS AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

- Pasando a ocuparnos de las medidas aplicables a las agrupaciones sin personalidad jurídica, el art. 129 dispone que tratándose de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones no comprendidas en el art. 31 bis por carecer de personalidad jurídica, el Juez o Tribunal podrá imponerles motivadamente una o varias consecuencias accesorias de la pena correspondiente al autor del delito.
- Por otro lado, el contenido de las consecuencias accesorias será el previsto en los apartados c) a g) del art. 33.7 como son las siguientes:
 - Primero, la suspensión de actividades por un plazo no superior a cinco años.
 - Segundo, la clausura de locales y establecimientos por plazo no superior a cinco años.
 - Tercero, la prohibición de realizar las actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. En este sentido, la prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo y, en el primer caso, no podrá exceder de quince años.
 - Cuarto, la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un plazo no superior a quince años.
 - Quinto, la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario que no podrá exceder de cinco años.
 - Por último, el Juez o Tribunal podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad aunque sea lícita.
- En cuanto a los **supuestos de aplicación de estas medidas**, el apartado 2 dispone que estas medidas sólo podrán imponerse en casos expresamente previstos por el Código Penal o cuando se trate de delitos para los que se contemple la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

- Finalmente, el Juez de Instrucción podrá también acordar la clausura temporal de locales o establecimientos, la suspensión de actividades sociales y la intervención judicial durante la instrucción de la causa.

OBTENCIÓN DE PERFIL GENÉTICO

- En cuanto a la obtención del perfil genético del delincuente, el art. 129 bis dispone que tratándose de condenados por delitos graves contra la vida, la integridad, la libertad, la libertad sexual, terrorismo u otros delitos graves que conlleven riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física, el Juez o Tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas del delincuente y su análisis para la obtención de identificadores de ADN y su inscripción en la base de datos policial.
- No obstante, esta medida sólo se aplicará cuando se aprecie riesgo relevante de reiteración delictiva en función de las circunstancias del hecho, los antecedentes, la valoración de la personalidad del penado u otra información disponible.
 - Por otro lado, si el penado se opusiere a la toma de las muestras, el Juez o Tribunal podrá acordar su ejecución forzosa con las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias y respetar la dignidad del penado.
 - Finalmente, se establece que sólo podrán realizarse análisis necesarios para obtener la información genética de la identidad de la persona y su sexo.

¹ SSTS 12 de julio de 2012 y 22 de marzo de 2013.

² SSTS 1 de julio de 2008 y 12 de diciembre de 2010.

³ SSTS 9 de noviembre de 2012 y 18 de diciembre de 2013.

⁴ STS 9 de noviembre de 2012.

⁵ SSTS 12 de julio de 2012, 23 de mayo de 2013 y 18 de diciembre de 2013.

⁶ SSTS 15 de septiembre de 2003 y 11 de junio de 2014.

⁷ SSTS 4 de julio de 2012 y 9 de noviembre de 2012.

DERECHO PENAL

TEMA 20

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.
ESPECIALIDADES EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA.
REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- Al estudiar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, hay que comenzar señalando que el Código Penal contempla esta figura con el propósito de evitar que la ejecución de una pena privativa de libertad pueda frustrar los fines inherentes a la misma.
- En este sentido, el art. 80 del Código Penal dispone lo siguiente:
 - 1º. *Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no será necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.*
 - 2º. *Para adoptar esta resolución, el Juez o Tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.*
- Por su parte, el apartado 2 dispone que serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena las siguientes:
 - 1º. *Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, salvo que estos integren un tipo agravado por multirreincidencia de delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.*
 - 2º. *Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.*
 - 3º. *Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el Juez o Tribunal determine. El Juez o Tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y el impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.*
- Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado que la suspensión de la ejecución no es un derecho subjetivo del penado sino una facultad potestativa y discrecional del Juez o Tribunal sin perjuicio de su carácter motivado atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor¹.
- En cuanto a la **suspensión sustitutiva**, el apartado 3 contempla una modalidad excepcional de suspensión caracterizada por la flexibilización de los requisitos ordinarios y dispone lo siguiente:
 - 1º. *Excepcionalmente, aunque no concurren las condiciones 1ª y 2ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.*
 - 2º. *En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1ª del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2º o 3º del mismo precepto con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.*

- Por otro lado, las medidas que deben imponerse conforme a los numerales 2º y 3º del art. 84.1 consistirán en el pago de una multa o la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad en los términos que señalaremos más adelante.
- En este sentido, el art. 94 dispone que *se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo en un plazo no superior a cinco años y hayan sido condenados por ello. Para realizar este cómputo se considerarán, por una parte, el momento de posible suspensión o sustitución de la pena conforme al artículo 88 y, por otra parte, la fecha de comisión de aquellos delitos que fundamenten la apreciación de la habitualidad.*
- En cuanto a la **suspensión para enfermos graves**, el apartado 4 dispone que *los Jueces y Tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables salvo que, en el momento de la comisión del delito, tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.*
- En cuanto a la **suspensión en casos de drogadicción**, el apartado 5 dispone lo siguiente:
 - 1º. *Aun cuando no concurren las condiciones 1ª y 2ª previstas en el apartado 2 de este artículo, el Juez o Tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2º del artículo 20 siempre que se certifique suficientemente por un centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado que el condenado se encuentra deshabitado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.*
 - 2º. *El Juez o Tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.*
 - 3º. *En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si éstas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.*
- En cuanto a la **audiencia de la víctima**, el apartado 6 dispone que, tratándose de delitos sólo perseguibles por denuncia o querrela del ofendido, los Jueces o Tribunales oirán al ofendido o su representante legal antes de conceder la suspensión de la ejecución de la pena.

CIRCUNSTANCIAS DE LA SUSPENSIÓN

- En cuanto a las circunstancias de la suspensión, nos referiremos sucesivamente a su duración, sus condiciones, el control de su cumplimiento, las prestaciones o medidas exigibles al penado y la modificación de unas y otras.
- En cuanto a la **duración**, el art. 81 dispone que el plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas leves y se determinará en función de los criterios del párrafo 2º del art. 80.1.
- No obstante, tratándose de la suspensión en caso de drogadicción a que se refiere el apartado 5, el plazo será de tres a cinco años.
 - Por su parte, el art. 82 dispone que el Juez o Tribunal resolverá sobre la suspensión en la sentencia siempre que sea posible y, en caso contrario, se pronunciará con la mayor urgencia, una vez declarada la firmeza de la sentencia y con audiencia de las partes.
 - Finalmente, el plazo de suspensión se contará desde la fecha de la resolución que la acuerde y, si se hubiera acordado en la sentencia, desde la fecha de su firmeza. Sin embargo, no se computará el tiempo en que el penado haya permanecido en rebeldía.

- En cuanto a las **condiciones de la suspensión**, el art. 83 dispone que el Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de los siguientes deberes y prohibiciones si es necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos pero sin que puedan imponerse deberes y prohibiciones desproporcionados o excesivos:
 - Primero, prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que el Juez o Tribunal determine, a sus domicilios, lugares de trabajo u otros lugares habitualmente frecuentados por ellos o de comunicarse con ellos por cualquier medio. En este sentido, la medida se comunicará a las personas afectadas.
 - Segundo, prohibición de establecer contacto con determinadas personas o miembros de un grupo determinado cuando existan indicios fundados de que tales sujetos puedan facilitar al penado la ocasión de cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.
 - Tercero, mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con la prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del Juez o Tribunal.
 - Cuarto, prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando se pueda encontrar en ellos la ocasión o el motivo para cometer nuevos delitos.
 - Quinto, comparecer personalmente ante el Juez o Tribunal, en dependencias policiales o el servicio administrativo que se determine para informar y justificar sus actividades con la periodicidad que se determine.
 - Sexto, participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, defensa del medio ambiente, protección de los animales, igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.
 - Séptimo, participar en programas de deshabituación del consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o tratamiento de otros comportamientos adictivos.
 - Octavo, prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación de las condiciones físicas del conductor cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida sea necesaria para prevenir la comisión de nuevos delitos.
 - Por último, los demás deberes que se estimen convenientes para la rehabilitación social del penado con su previa conformidad y siempre que no atenten a su dignidad.
- En cuanto a los **controles del cumplimiento**, el art 83 dispone que la imposición de las medidas de los apartados 1 a 4 se comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 - Por su parte, estas últimas informarán al Ministerio Fiscal y al Juez o Tribunal responsable de la ejecución de cualquier quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado o la posibilidad de comisión de nuevos delitos.
 - Finalmente, se establece que el control del cumplimiento de las medidas de los apartados 6 a 8 corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria, que informarán periódicamente al Juez y, en todo caso, al tiempo de conclusión de la medida.
- En cuanto a las **prestaciones o medidas exigibles**, el art. 84 dispone que el Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión a alguna o algunas de las siguientes:
 - Primero, el cumplimiento del acuerdo de mediación alcanzado por las partes.
 - Segundo, el pago de una multa cuya extensión se fijará en función de las circunstancias del caso y que no podrá superar la que resulte de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión y sobre un límite de dos tercios de su duración.
 - Tercero, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cuando sea adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. En este sentido, el Juez o Tribunal fijará la duración de los trabajos en atención a dichas circunstancias y no podrá superar la que resulte de aplicar un día de trabajos por cada día de prisión y sobre un límite de dos tercios de su duración.

- En cuanto a **modificación de las condiciones**, el art. 85 dispone que el Juez o Tribunal podrá modificar las medidas adoptadas conforme a los arts. 83 y 84 durante el periodo de suspensión y a la vista del cambio de las circunstancias que hubiere valorado.
 - En este sentido, la modificación podrá consistir en el alzamiento, la modificación o la sustitución de las medidas impuestas por otras menos gravosas.
 - Finalmente, tratándose de condenados por delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, la progresión a tercer grado exigirá el cumplimiento de veinticuatro años de prisión en los dos primeros casos y treinta y dos años en el tercer caso. Del mismo modo, la suspensión de la ejecución del resto de la pena exigirá un mínimo de veintiocho y treinta y cinco años de prisión respectivamente.

ESPECIALIDADES EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

- En cuanto a las especialidades en supuestos de violencia de género y doméstica, distinguimos dos especialidades.
- En cuanto a las **condiciones de la suspensión**, el art. 83 dispone que tratándose de delitos cometidos contra una mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aun sin convivencia, el Juez impondrá siempre las prohibiciones y deberes de los apartados 1, 4 y 6.
- Por otro lado, estas prohibiciones y deberes también se impondrán en los casos de delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos.
- En cuanto a las **prestaciones o medidas exigibles**, el art. 84 dispone que, tratándose de delitos cometidos contra la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aun sin convivencia o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago de la multa sólo podrá imponerse cuando conste que no existen relaciones económicas entre ellos derivadas de una relación conyugal o convivencia, de filiación o de una descendencia común.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

- En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, el art. 92 dispone que el Tribunal la acordará en un procedimiento contradictorio con intervención del Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su Abogado, si concurren los siguientes requisitos:
 - Primero, que el penado haya cumplido veinticinco años de condena sin perjuicio de la posibilidad de progresión a tercer grado en los casos previstos en el art. 78 bis.
 - Segundo, que el penado se encuentre clasificado en tercer grado.
 - Tercero, que el Tribunal pueda emitir un pronóstico favorable de reinserción social del penado conforme a determinadas circunstancias como su personalidad y antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados en caso de reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento de la condena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la suspensión de la ejecución y de las medidas impuestas y todo ello, a la vista de los informes del centro penitenciario y los especialistas que el propio Tribunal determine.
 - Por último, tratándose de condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, también se establecen unos requisitos específicos de abandono de la actividad terrorista y colaboración con las autoridades.

- En cuanto a la **duración de la suspensión**, ésta tendrá una duración de cinco a diez años y se contará desde la fecha de la puesta en libertad del penado.
- Por su parte, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la suspensión y la libertad condicional cuando exista un cambio de las circunstancias que dieron lugar a aquéllas y no sea posible mantener el pronóstico de falta de peligrosidad del penado.
- En cuanto a la **libertad condicional**, ésta podrá concederse de oficio o a instancia del penado.
 - En efecto, el art. 92.4 dispone que el Tribunal verificará cada dos años el cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional una vez extinguida la parte de la condena a que se refieren el art. 78 bis o el art. 92.1. De igual modo, el Tribunal resolverá las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado pero podrá fijar un plazo no superior a un año en el que no se dará curso a nuevas solicitudes.
 - Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sostiene que este precepto debe interpretarse en el sentido de ser aplicable también a los penados que hayan reingresado en prisión tras la revocación de la libertad condicional²l.

REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

- En cuanto a la revocación de la suspensión, el art. 86 dispone que el Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena en los siguientes casos:
 - Primero, cuando el penado sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión y ello muestre que la expectativa en que se fundaba la suspensión no puede ser mantenida.
 - Segundo, cuando el penado incumpla de forma grave o reiterada las obligaciones y deberes impuestos conforme al art. 83 o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.
 - Tercero, cuando el penado incumpla de forma grave o reiterada las prestaciones que se le hubieran impuesto con arreglo al art. 84.
 - Cuarto, cuando el penado facilite información inexacta sobre el paradero de bienes u objetos sobre los que se hubiere acordado el decomiso o incumpla el compromiso de pago de las responsabilidades civiles, salvo que carezca de capacidad económica para ello, o facilite información inexacta sobre su patrimonio.
- Finalmente, se establece que si los incumplimientos de obligaciones o prestaciones no fueren graves o reiterados, el Juez o Tribunal podrá imponer otras distintas, modificar las impuestas o prorrogar el plazo de suspensión siempre que no supere la mitad del fijado inicialmente.
- Por otro lado, el apartado 4 dispone que el Juez o Tribunal adoptarán estas decisiones con audiencia del Ministerio Fiscal y las demás partes.
 - Sin embargo, el Juez o Tribunal podrá revocar la suspensión y ordenar el ingreso en prisión inmediato del sujeto cuando se estime imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva o el riesgo de huida o para asegurar la protección de la víctima.
 - Finalmente, el Juez podrá también acordar las diligencias de comprobación que estime necesarias y acordar la celebración de una vista oral.

REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA

- En cuanto a la remisión definitiva de la pena, el art. 87 dispone que el Juez o Tribunal la acordará una vez transcurrido el plazo de suspensión sin que el sujeto hubiera cometido ningún delito que revele que la expectativa en que se fundaba la suspensión no puede ser mantenida y siempre que haya cumplido suficientemente las reglas de conducta impuestas.

- No obstante, tratándose de la suspensión en caso de drogadicción a que se refiere el apartado 5 del art. 80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento.
- De este modo, si no se acreditan estas circunstancias, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la pena a menos que estime necesaria la continuación del tratamiento a la vista de los informes correspondientes en cuyo caso podrá prorrogar el plazo de suspensión por un periodo no superior a dos años.

¹ STC 224/1992, de 14 de diciembre y STC 57/2007, de 12 de marzo.

² STC 169/2021, de 6 de octubre.

DERECHO PENAL

TEMA 21

SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. LA LIBERTAD
CONDICIONAL.

SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- Al estudiar la sustitución de las penas privativas de libertad, hay que comenzar señalando que el Código Penal de 1995 preveía en su redacción originaria dos instituciones dirigidas a evitar que la ejecución de una pena de este tipo pudiera frustrar los fines inherentes a la misma como eran la suspensión de la ejecución y la sustitución de la pena.
- Por su parte, la Ley Orgánica 1/2015 modificó esta regulación al establecer un régimen único en el que la sustitución de la pena pasa a configurarse como una modalidad de la suspensión sin perjuicio del mantenimiento de la sustitución por expulsión del territorio español para los extranjeros condenados a pena de prisión.
 - En este sentido, la sustitución de la pena como modalidad de suspensión es materia de otro tema del programa por lo que nos ocuparemos exclusivamente de la sustitución por expulsión del territorio español.
 - En relación con ella, hay que señalar que la sustitución por expulsión podrá acordarse frente a todos los ciudadanos extranjeros, incluyendo los que residan legalmente en España y los pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea.
- En cuanto a la **expulsión de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea**, el art. 89 distingue dos supuestos en función de la duración de la pena impuesta.
 - En cuanto a las **penas de prisión superiores a un año**, éstas serán sustituidas por la expulsión del territorio español.
 - No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar excepcionalmente la ejecución de una parte de la pena que no exceda de dos tercios cuando sea necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y para restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida en cuyo caso el resto de la pena se sustituirá por la expulsión.
 - Del mismo modo, el resto de la pena también se sustituirá por la expulsión cuando el penado obtenga el tercer grado o acceda a la libertad condicional.
 - En cuanto a las **penas de prisión superiores a cinco años**, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de la totalidad o parte de la pena en la medida en que sea necesario para los fines del caso anterior. De igual modo, también se aplicará esta regla si se hubieran impuesto varias penas de prisión que excedan conjuntamente de cinco años.
 - Por otra parte, el resto de la pena se sustituirá por la expulsión una vez que el penado cumpla la parte de pena que se hubiera establecido u obtenga el tercer grado o acceda a la libertad condicional.
- En relación con estas reglas, la jurisprudencia ha declarado que la pena que deberá tomarse en consideración no es la pena en abstracto establecida para el delito cometido sino la pena efectivamente impuesta en la sentencia¹.
- Por otro lado, la Circular de la Fiscalía General del Estado 7/2015 sostiene que tratándose de condenados a una o varias penas de prisión inferiores a un año, no procederá la sustitución por expulsión aunque la suma de las penas impuestas supere dicho límite.
 - Por otro lado, tratándose de condenados a una o varias penas de prisión de entre uno y cinco años, los Fiscales solicitarán la sustitución completa de la pena por expulsión a menos que se aprecie una necesidad de afirmación del ordenamiento jurídico mediante el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario.
 - Finalmente, esta situación se apreciará en casos como delitos cometidos con violencia o intimidación particularmente intensas; delitos que impliquen vejación, degradación o ensañamiento graves y delitos que afecten a bienes jurídicos especialmente valiosos como la libertad, la libertad sexual y la inviolabilidad domiciliaria.
- En cuanto a la **expulsión de extranjeros pertenecientes a la Unión Europea**, el art. 89 dispone que ésta sólo procederá cuando el penado represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en función de la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito, sus antecedentes y sus circunstancias personales.

- Por otra parte, el art. 89 dispone que si el penado hubiera residido en España en los diez años anteriores, la sustitución por expulsión sólo procederá cuando concorra también alguno de los siguientes requisitos:
 - Primero, que el penado hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, la libertad, la integridad física o la libertad sexual castigados con pena máxima de prisión superior a cinco años y que se aprecie un riesgo fundado de que pueda cometer nuevos delitos de la misma naturaleza.
 - Segundo, que el penado hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales.
- Finalmente, el art. 89 dispone que a los extranjeros que se encuentren en estos supuestos se les aplicará en todo caso el régimen previsto para los no pertenecientes a la Unión Europea cuando la pena de prisión impuesta o la suma de las impuestas excedan de cinco años.

PROCEDIMIENTO

- En cuanto al procedimiento para la sustitución de la pena por expulsión del territorio español, el art. 89 dispone que el Juez o Tribunal resolverá sobre ella en la sentencia siempre que ello sea posible y, en caso contrario, se pronunciará con la mayor urgencia, una vez declarada la firmeza de la sentencia y con audiencia del Ministerio Fiscal y demás partes.
- Por otro lado, se establece que el Juez o Tribunal no acordará la sustitución de la pena de prisión por expulsión cuando ésta resulte desproporcionada en función de las circunstancias del hecho y las personales del autor y, particularmente de su arraigo en España.
 - En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional declaró que la sustitución de la pena de prisión por expulsión sólo podrá acordarse con audiencia del penado y sin que sea suficiente a estos efectos el derecho a la última palabra al que se refiere el art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal².
 - Por otra parte, la Circular de la Fiscalía General del Estado 7/2015 sostiene que para apreciar la proporcionalidad de la medida deberá atenderse al tiempo de residencia del penado en España; su situación familiar y económica; su integración social, laboral y cultural y sus vínculos con su país de origen. Por su parte, el arraigo familiar deberá provenir de relaciones con los parientes próximos o con otros familiares con los que se acredite una relación estable de dependencia material o económica.
- En cuanto a la **reconsideración de la expulsión**, la Circular de la Fiscalía General del Estado 7/2015 sostiene que si transcurrieren más de dos años desde la firmeza de la sentencia o el auto que acuerden la sustitución por expulsión sin que ésta se hubiera ejecutado, el Juez o Tribunal podrán reconsiderar la decisión si la situación del penado hubiera cambiado de forma relevante y el cumplimiento de la medida hubiera devenido desproporcionado.
- Finalmente, también podrá reconsiderarse la sustitución por expulsión antes del transcurso de dos años por causas justificadas.

CONSECUENCIAS

- En cuanto a las consecuencias de la expulsión, el art. 89 contempla las siguientes:
 - En primer lugar, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años desde la fecha de la expulsión, atendiendo a la duración de la pena sustituida y a sus circunstancias personales.
 - En segundo lugar, la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

- En tercer lugar, si el extranjero regresare a España antes de transcurrir dicho plazo, el mismo deberá cumplir la pena sustituida a menos que el Juez o Tribunal reduzca excepcionalmente su duración en el caso de que el cumplimiento sea innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida. No obstante, si el penado es sorprendido en la frontera, el mismo será expulsado por la autoridad gubernativa y comenzará a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
- En cuarto lugar, el Juez o Tribunal podrá acordar el ingreso del penado en un centro de internamiento de extranjeros en los términos previstos para la expulsión gubernativa en el caso de que, al tiempo de acordarse su expulsión, el mismo no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad.
- En quinto lugar, si la expulsión no pudiera ejecutarse una vez acordada, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del tiempo de condena pendiente o bien se concederá el beneficio de la suspensión de la ejecución.
- Por último, no se aplicará este régimen a las penas impuestas por delitos de trata de seres humanos del art. 177 bis ni por delitos contra los derechos de los trabajadores de los arts. 312, 313 y 318 bis.

LA LIBERTAD CONDICIONAL

- Pasando a ocuparnos de la libertad condicional, hay que señalar que la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 la ha venido a configurar como una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena de prisión por lo que, en caso de revocación de la libertad condicional, el tiempo transcurrido en esta situación no se abonará para el cómputo de la pena.

RÉGIMEN ORDINARIO

- En cuanto a su régimen ordinario el art. 90 dispone que *el Juez de Vigilancia Penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:*
 - 1º. *Que se encuentre clasificado en tercer grado.*
 - 2º. *Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.*
 - 3º. *Que haya observado buena conducta.*
- Por otro lado, se establece que para decidir sobre la concesión de este beneficio, el Juez de Vigilancia Penitenciaria valorará los siguientes parámetros:
 - Primero, la personalidad del penado, sus antecedentes y las circunstancias del delito cometido.
 - Segundo, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados en caso de reiteración en el delito.
 - Tercero, la conducta del penado durante el cumplimiento de la pena.
 - Cuarto, las circunstancias familiares y sociales del penado.
 - Por último, los efectos que puedan esperarse de la suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas.
- Finalmente, no procederá la suspensión si el penado no hubiera satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los casos y con arreglo a los requisitos previstos en el art. 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

- En cuanto a los **supuestos de adelantamiento de la libertad condicional**, el art. 90 dispone que ésta también podrá concederse a los penados que reúnan los siguientes requisitos:
 - 1º. *Que hayan extinguido dos terceras partes de su condena.*
 - 2º. *Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.*
 - 3º. *Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena.*
- Por otra parte, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá adelantar la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de noventa días por cada año de cumplimiento efectivo de condena siempre que el penado haya extinguido la mitad de la condena, se halle clasificado en tercer grado y haya observado buena conducta.
 - No obstante, esta medida requerirá que el penado haya participado continuadamente en las actividades mencionadas y que acredite su participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación.
 - Por otro lado, la medida deberá adoptarse a propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y demás partes.

SUPUESTOS EXCEPCIONALES

- En cuanto al **régimen aplicable a delincuentes primarios**, el art. 90 dispone que el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá excepcionalmente suspender la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que reúnan los siguientes requisitos:
 - 1º. *Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres años de duración.*
 - 2º. *Que hayan extinguido la mitad de su condena.*
 - 3º. *Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1 salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena así como el regulado en la letra b) del apartado anterior, relativo a la participación en determinadas actividades.*
- Finalmente, se establece que este régimen no podrá aplicarse a los condenados por delitos contra la libertad sexual.
- En cuanto al **régimen aplicable a mayores de 70 años y enfermos graves**, el art. 91 dispone los penados que hubieren cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la ejecución de la condena y que cumplan los requisitos del art. 90 podrán obtener la libertad condicional aunque no hubieren cumplido las tres cuartas partes, las dos terceras partes o la mitad de la condena.
- Por otro lado, también se aplicará este régimen a los enfermos muy graves con padecimientos incurables siempre que ello se acredite con los informes médicos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria estime necesarios. En este sentido, el Juez adoptará su decisión valorando las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.
 - Por otro lado, si el peligro para la vida del interno fuera patente por estar acreditado por el dictamen del Médico Forense y por los servicios médicos del centro penitenciario, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá conceder la libertad condicional valorando la peligrosidad criminal del penado y sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final para realizar dicha valoración.
 - Finalmente, el penado estará obligado a facilitar al Médico Forense, al servicio médico penitenciario o al designado por el Juez o Tribunal la información necesaria para valorar la evolución de la enfermedad y el incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la libertad condicional.

- En cuanto al **régimen aplicable a los penados por determinados delitos**, el art. 90 dispone que tratándose de penados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o delitos de terrorismo, la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional exigirá que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y que haya colaborado activamente con las autoridades de alguna de las siguientes formas:
 - Primero, para impedir la comisión de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista.
 - Segundo, para atenuar los efectos del delito.
 - Tercero, para la identificación, captura y procesamiento de los responsables de delitos terroristas.
 - Cuarto, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.
- Por otro lado, el cumplimiento de estos requisitos podrá acreditarse de las siguientes formas:
 - Primero, por una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.
 - Segundo, por los informes técnicos que acrediten que el condenado está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
- Finalmente, se establece que los regímenes de adelantamiento de la libertad condicional a que nos hemos referido no podrán aplicarse a los condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por delitos de terrorismo.

PROCEDIMIENTO

- En cuanto al procedimiento para la concesión de la libertad condicional, el art. 90 dispone que el Juez de Vigilancia Penitenciaria resolverá de oficio sobre la misma a petición del penado.
 - De este modo, si la petición no fuere estimada, el Juez podrá establecer un plazo de seis meses para que pueda plantearse nuevamente la petición. Del mismo modo, este plazo podrá prolongarse motivadamente a un año.
 - Por otro lado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de los deberes y prohibiciones a que se refiere el art. 83 o modificar la decisión anteriormente adoptada a la vista del cambio de las circunstancias valoradas.
- En cuanto a las **causas de denegación de la libertad condicional**, el art. 90 dispone que el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá denegarla por los siguientes motivos:
 - Primero, si el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente del paradero de bienes u objetos cuyo decomiso se hubiera acordado.
 - Segundo, si hubiera facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio con infracción de la obligación prevista en el art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 - Tercero, si no hubiera cumplido conforme a su capacidad el compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado.
 - Por último, tratándose de condenados por delitos contra la Administración Pública, si el penado hubiera eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración.
- En cuanto a la **revocación de la libertad condicional**, el art. 90 dispone que el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional cuando exista un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a ella y no pueda mantenerse el pronóstico de falta de peligrosidad criminal del sujeto.

- De este modo, la revocación de la libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de pena pendiente de cumplimiento y sin que pueda computarse el tiempo transcurrido en libertad condicional.
- En cuanto al **plazo de suspensión**, el art. 90 dispone que éste será de dos a cinco años pero no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento.
- Finalmente, este plazo se computará desde la fecha de la puesta en libertad del penado.

¹ STS 26 de mayo de 2020.

² STC 242/1994, de 20 de julio y STC 203/1997, de 25 de noviembre.

DERECHO PENAL

TEMA 22

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. REGLAS GENERALES Y ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA.

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA

- Al estudiar la individualización de la pena, hay que comenzar señalando que se entiende por dosimetría penal *aquella actividad consistente en determinar la pena que debe imponerse al responsable de un hecho delictivo partiendo del marco penal abstracto establecido por la ley.*
- En cuanto a los **sistemas de individualización**, se han manejado distintos sistemas como son el sistema de determinación legislativa absoluta y el sistema de sentencia indeterminada, en el que la extensión de la pena se fija en el curso de su ejecución.
- Por su parte, nuestro ordenamiento distingue un momento legislativo que supone la fijación por parte del legislador de la clase de la pena y de los límites máximo y mínimo de la pena que deberá imponerse; un momento judicial que supone la fijación por parte del Juez de la pena impuesta en función de las circunstancias del caso y de la personalidad del delincuente y un momento ejecutivo que cobra especial relevancia en el caso de las penas de libertad, en cuya ejecución intervienen el Juez o Tribunal sentenciador, el Juez de Vigilancia y la Administración penitenciaria.

REGLAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA

- Pasando a ocuparnos de las reglas generales para la aplicación de la pena, nos ocuparemos primero de las reglas sobre elevación y reducción de grado.
- En este sentido, el Código Penal prescinde de la división en escalas graduales y de la división en grados mínimo, medio y máximo del Código Penal anterior en lugar de la cual se establece una división entre mitad inferior y mitad superior.
- En cuanto a las **normas generales**, el art. 70.1 dispone lo siguiente:
 - 1º. *La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.*
 - 2º. *La pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada por la ley para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.*
- Por su parte, el art. 70.2 dispone que *a los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuarán como unidades penológicas de más o menos, según los casos.*
- Finalmente, el art. 70.4 dispone que la pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años.
- En cuanto a las **normas especiales**, el art. 71 dispone lo siguiente:
 - 1º. *En la determinación de la pena inferior en grado, los Jueces o Tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase de pena sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente.*
 - 2º. *No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores, proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente.*

GRADO DE EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN

- En cuanto al **grado de ejecución**, el art. 61 dispone que *cuando la ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada*.
 - Por su parte, el art. 62 dispone que *a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado*.
 - En este sentido, la jurisprudencia sostiene que la pena se reducirá un grado en los casos de tentativa acabada o cuando la ejecución haya alcanzado un grado muy avanzado y en dos grados en casos de tentativa inacabada o cuando la actividad del delincuente revele una escala potencia criminal¹.
- En cuanto al **grado de participación**, el art. 63 dispone que *a los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito*.
- Por su parte, el art. 64 dispone que *las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la complicidad se hallen especialmente penadas por la ley*.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES

- En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes, el art. 66.1 establece reglas aplicables a los delitos dolosos en los términos que señalamos a continuación.
 - Por su parte, el apartado 2 dispone que *en los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las reglas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves*.
 - Por otro lado, el art. 67 dispone que *las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse*.
- En cuanto a las **circunstancias atenuantes**, el art. 66 dispone que cuando concurra sólo una atenuante, se aplicará la pena en su mitad inferior.
 - No obstante, si concurren dos o más atenuantes o una o varias muy cualificadas y no concurre ninguna agravante, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la prevista por la ley para el delito del que se trate atendiendo al número y entidad de las atenuantes.
 - En relación con este supuesto, conviene señalar que la reducción de la pena en un grado es preceptiva mientras que la reducción en dos grados es potestativa.
- En cuanto a las **circunstancias agravantes**, el art. 66 dispone lo siguiente:
 - Primero, cuando concurren sólo una o dos agravantes, se aplicará la pena en la mitad superior de la prevista por la ley para el delito.
 - Segundo, cuando concurren más de dos agravantes y no concurra ninguna atenuante, los Jueces o Tribunales podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito del que se trate en su mitad inferior.
 - Tercero, cuando concurra la agravante de reincidencia con la cualificación de que, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por, al menos, tres delitos comprendidos en el mismo título del mismo Código y que sean de la misma naturaleza, los Jueces y Tribunales podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate teniendo en cuenta las condenas precedentes y la gravedad del nuevo delito cometido. No obstante, no se computarán a estos efectos los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

- En cuanto a la **ausencia de atenuantes y agravantes**, el art. 66 dispone que si no concurren atenuantes ni agravantes, se aplicará la pena prevista por la ley para el delito de que se trate en la extensión que se estime adecuada atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho.
- En cuanto a la **conurrencia de atenuantes y agravantes**, el art. 66 dispone que si concurren unas y otras, los Jueces y Tribunales las compensarán racionalmente para individualizar la pena.
- No obstante, si persiste un fundamento cualificado de atenuación, se aplicará la pena inferior en grado y si persiste un fundamento cualificado de agravación, la pena en su mitad superior.
- En cuanto a las **eximentes incompletas**, el art. 68 dispone que se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley atendidos el número y entidad de los requisitos que falten o concurren y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del Código Penal.
- En cuanto a la **minoría de veintiún años**, el art. 69 dispone que *al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga.*
- En este sentido, la posibilidad contemplada en el art. 69 venía inicialmente contemplada en el art. 4 de la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores pero fue eliminada por la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2006.
- En cuanto a la **pena imponible a las personas jurídicas**, el art. 66 bis establece unas reglas específicas sobre la materia cuyo estudio es materia de otro tema del programa.

REGLAS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA

- Pasando a ocuparnos de las reglas especiales para la aplicación de la pena, nos referiremos a las normas sobre concurso real, concurso ideal, delito continuado y delito masa.

CONCURSO REAL

- En cuanto al concurso real de delitos, el Código Penal prevé la aplicación de un sistema mixto que contempla el sistema de acumulación material y de acumulación jurídica.

- En cuanto a la **acumulación material**, el art. 73 dispone que *al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.*
- Por su parte, el art. 75 dispone que *cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.*
- En cuanto a la **acumulación jurídica**, el art. 76.1 dispone que *no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de veinte años. Excepcionalmente, este límite máximo será:*
 - a) *De veinticinco años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta veinte años.*
 - b) *De treinta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - c) *De cuarenta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - d) *De cuarenta años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.*
 - e) *Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.*
- Por su parte, el art. 76.2 dispone que *la limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.*
- Por otro lado, el art. 78 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *Si, a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76, la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.*
 - 2º. *En estos casos, el Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable:*
 - a) *Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.*
 - b) *A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.*

- Finalmente, el art. 78 bis dispone lo siguiente:

- 1º. *Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:*
 - a) *De un mínimo de dieciocho años de prisión cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.*
 - b) *De un mínimo de veinte años de prisión cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.*
 - c) *De un mínimo de veintidós años de prisión cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.*
- 2º. *En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido:*
 - a) *Un mínimo de veinticinco años de prisión en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior.*
 - b) *Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.*
- 3º. *Si se tratase de delitos referentes a organizaciones o grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1º y de treinta y dos años en el de la letra c) del apartado 1º.*
- 4º. *En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1º y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado 1º.*

CONCURSO IDEAL Y MEDIAL

- En cuanto al concurso ideal y el concurso medial de delitos, el art. 77 dispone lo siguiente:
 - 1º. *Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.*
 - 2º. *En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.*
 - 3º. *En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el Juez o Tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.*

DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA

- En cuanto al delito continuado y el delito masa, el art. 74 dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.*
 - 2º. *Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones, el Juez o Tribunal impondrá motivadamente la pena superior en uno o dos grados en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.*
 - 3º. *Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.*

PENAS ACCESORIAS

- En cuanto a las penas accesorias, el art. 79 dispone que *siempre que los Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras accesorias, condenarán también expresamente al reo a estas últimas.*

¹ SSTS 14 de mayo de 2004 y 6 de marzo de 2006.

DERECHO PENAL

TEMA 23

LA MEDIDA DE SEGURIDAD: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES. CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNAMIENTO. CONCURRENCIA DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

LA MEDIDA DE SEGURIDAD: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES

- Al estudiar la medida de seguridad, podemos comenzar definiéndola *aquella consecuencia jurídica del delito a través de la cual se pretende la curación o inocuización de las personas que han cometido un hecho delictivo y que presentan un elevado nivel de peligrosidad criminal.*
- En cuanto a sus **caracteres**, cabe destacar los siguientes:
 - En primer lugar, las medidas de seguridad están sometidas a las garantías del principio de legalidad penal como muestran los siguientes preceptos:
 - Primero, el art. 1.2 del Código Penal dispone que *las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurren los presupuestos establecidos previamente por la ley.*
 - Segundo, el art. 2.1 dispone que *no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.*
 - Tercero, el art. 3.1 dispone que *no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales.*
 - Cuarto, el art. 3.2 dispone que *tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prevista por la ley y reglamentos que la desarrollen, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.*
 - En segundo lugar, las medidas de seguridad sólo podrán basarse en la comisión de un hecho previsto como delito. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 23/1986, relativa a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, declaró la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad predelictuales, impuestas a personas no condenadas por la comisión de ningún delito.
 - En tercer lugar, las medidas de seguridad deberán basarse en la peligrosidad criminal del sujeto y deberán ser proporcionadas a su grado de peligrosidad. En efecto, el art. 6.2 dispone que *las medidas de seguridad no podrán resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.*
 - Por último, el Código Penal prevé la imposición de medidas de seguridad a personas inimputables o semiimputables si bien también se contemplan excepcionalmente para sujetos imputables como sucede con la imposición de la medida de libertad vigilada a los condenados por delitos contra la libertad sexual conforme al art. 192.
- En cuanto a su **fundamento**, el art. 6.1 dispone que *las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.*
- En este sentido, las medidas de seguridad se justifican por la necesidad de protección de la sociedad frente a delincuentes peligrosos y por la necesidad de tratamiento asistencial de las personas que padecen minusvalías de las que se deriva una peligrosidad criminal.
- En cuanto a su **fin**, el art. 25.2 de la Constitución dispone que *las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.*
- Por su parte, la doctrina sostiene que las medidas cumplen fines de prevención especial consistentes en evitar que el autor de un hecho delictivo vuelva a delinquir sin perjuicio de que algunas pueden cumplir otros fines adicionales como sucede con la medida de internamiento en centros de deshabituación, que cumple también una finalidad asistencial.

CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En cuanto a las clases de medidas, el art. 96 dispone que *las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no privativas de libertad.*
- En cuanto a las **medidas privativas de libertad**, el apartado 2 se refiere al internamiento en centro psiquiátrico o en centro de deshabituación o en centro educativo especial.
- En cuanto a las **medidas no privativas de libertad**, el apartado 3 se refiere a las siguientes:
 - 1º. *La inhabilitación profesional.*
 - 2º. *La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.*
 - 3º. *La libertad vigilada.*
 - 4º. *La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.*
 - 5º. *La privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores.*
 - 6º. *La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.*

APLICACIÓN

- En cuanto a la aplicación de las medidas de seguridad, el art. 95 dispone que *las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el Capítulo siguiente de este Código siempre que concurren estas circunstancias:*
 - 1º. *Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.*
 - 2º. *Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.*

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- En cuanto a la aplicación de las medidas privativas de libertad, el art. 95.2 dispone que éstas sólo procederán cuando el delito cometido lleve aparejada una pena privativa de libertad.
- En cuanto al **internamiento en centro psiquiátrico**, el art. 101 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración que se aprecie, en cuyo caso no podrán abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.
- En cuanto al **internamiento en centro de deshabituación**, el art. 102 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad por intoxicación plena o síndrome de abstinencia se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado, acreditado u homologado, en cuyo caso tampoco podrán abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.
- En cuanto al **internamiento en centro educativo especial**, el art. 103 dispone que a los declarados exentos de responsabilidad por alteraciones en la percepción se les podrá aplicar si fuere necesaria la medida de internamiento en centro educativo especial, en cuyo caso no podrán abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.

- Por último, el art. 104 dispone que si se apreciara una eximente incompleta en relación con cualquiera de las circunstancias citadas, el Juez o Tribunal podrá imponer además de la pena correspondiente, las medidas de seguridad mencionadas siempre que la pena prevista para el delito sea privativa de libertad y con los límites que señalaremos más adelante.

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

- En cuanto a la aplicación de las medidas no privativas de libertad, el art. 105 dispone que *en los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.*
 - En este sentido, las medidas de libertad vigilada y custodia familiar podrán imponerse por un plazo no superior a cinco años.
 - Por su parte, las medidas de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores podrán imponerse por un plazo de hasta diez años. No obstante, también la medida de libertad vigilada podrá imponerse hasta diez años en los casos expresamente previstos.
- En cuanto a la **inhabilitación**, el art. 107 dispone que se podrá decretar razonadamente la inhabilitación para el ejercicio de un derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por el tiempo de uno a cinco años cuando el sujeto haya cometido un delito con abuso de dicho ejercicio o en relación con él y cuando de la valoración de las circunstancias pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponer la pena correspondiente por concurrir alguna de las eximentes de los números 1º, 2º y 3º del art. 20.
- En cuanto a la **libertad vigilada**, el art. 106 dispone que *la libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes medidas:*
 - 1º. *La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.*
 - 2º. *La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.*
 - 3º. *La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.*
 - 4º. *La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal.*
 - 5º. *La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.*
 - 6º. *La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.*
 - 7º. *La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.*
 - 8º. *La prohibición de residir en determinados lugares.*
 - 9º. *La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.*
 - 10º. *La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.*
 - 11º. *La obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.*

- Por su parte, el apartado 2 dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 105 y siempre que el Código Penal así lo disponga expresamente, el Juez o Tribunal impondrá la medida de libertad vigilada en la propia sentencia para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta.

EJECUCIÓN

- Pasando a ocuparnos de la ejecución de las medidas de seguridad, el art. 97 dispone que una vez iniciada la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará por el procedimiento previsto en el art. 98 alguna de las siguientes decisiones:
 - Primero, mantener la ejecución de la medida impuesta.
 - Segundo, decretar su cese si la peligrosidad criminal del sujeto hubiere desaparecido.
 - Tercero, sustituir la medida por otra más adecuada entre las previstas para el hecho de que se trate. No obstante, si el sujeto evolucionara desfavorablemente, el Juez o Tribunal dejará sin efecto la sustitución y volverá a aplicarse la medida inicial.
 - Por último, dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado obtenido por un plazo no superior al que reste hasta el máximo fijado en la sentencia. En este sentido, la suspensión vendrá condicionada a que el sujeto no delinca en el plazo fijado y podrá dejarse sin efecto si resurgieren los presupuestos del art. 95.
- En cuanto al **procedimiento de revisión**, el art. 98 dispone que tratándose de medidas de seguridad privativas de libertad o de una medida de libertad vigilada posterior al cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia elevará al Juez o Tribunal sentenciador al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida. En este sentido, la propuesta se formulará valorando los informes emitidos por los facultativos o profesionales que asistan al condenado o por las Administraciones públicas competentes y, en su caso, el resultado de las actuaciones ordenadas para el mismo fin.
 - Por otro lado, tratándose de medidas de seguridad no privativas de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente los informes sobre la situación y evolución del penado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reiteración delictiva.
 - Finalmente, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente y con audiencia del Ministerio Fiscal, el condenado y las demás partes. Del mismo modo, el Juez o Tribunal sentenciador oír a las víctimas del delito que no estuvieran personadas si lo hubieran solicitado durante la ejecución de la sentencia y estuvieran localizables.
- En cuanto a la **ejecución de la medida de libertad vigilada**, el art. 106 dispone que en los casos en que la misma deba ejecutarse tras el cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria elevará al Juez o Tribunal sentenciador al menos dos meses antes de la extinción de la pena una propuesta sobre el contenido de la medida y las obligaciones o prohibiciones que el condenado deba cumplir entre las previstas en el art. 106 y sin perjuicio de las posibilidades previstas en el art. 97. Por su parte, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá por el procedimiento previsto en el art. 98.
 - Por otro lado, si se hubieran impuesto al penado varias medidas de libertad vigilada por otros tantos delitos y no pudieran ejecutarse simultáneamente debido a las obligaciones o prohibiciones establecidas, el penado las cumplirá de forma sucesiva.
 - Finalmente, el Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar por el cauce previsto en el art. 98 la modificación de las obligaciones o prohibiciones impuestas; la reducción de la duración de la medida o el cese de la medida si el pronóstico positivo de reinserción hiciera innecesarias o contraproducentes las obligaciones o prohibiciones impuestas. Del mismo modo, también podrá dejar sin efecto la medida si estas circunstancias se pusieran de manifiesto al tiempo de fijar el contenido de la libertad vigilada.

- En cuanto a la **sustitución por expulsión del territorio nacional**, el art. 108 dispone que las medidas de seguridad impuestas a los extranjeros que no residan legalmente en España se sustituirán en la misma sentencia, previa audiencia de aquéllos, por su expulsión del territorio nacional salvo que el Juez o Tribunal aprecie excepcional y motivadamente con audiencia del Ministerio Fiscal que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la medida en España.
- Por otro lado, la expulsión estará sujeta a las siguientes condiciones:
 - En primer lugar, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de diez años desde la fecha de la expulsión.
 - En segundo lugar, el extranjero que intentare quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada en territorio nacional será devuelto por la autoridad gubernativa y comenzará a computarse de nuevo el plazo de prohibición.
 - En tercer lugar, la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
 - Por último, si la expulsión no pudiera llevarse a efecto una vez acordada, el Juez o Tribunal ordenará la ejecución de la medida originariamente impuesta.

QUEBRANTAMIENTO

- Pasando a ocuparnos del quebrantamiento de las medidas de seguridad, el art. 100 distingue según se trate de medidas privativas o no privativas de libertad.
 - En efecto, tratándose de medidas de internamiento, el apartado 1 dispone que el Juez o Tribunal ordenará el reingreso del sujeto en el centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
 - Por el contrario, tratándose de medidas no privativas de libertad, el apartado 2 dispone que el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución de la medida quebrantada por la medida de internamiento siempre que ésta estuviere prevista para el caso de que se trate y que el quebrantamiento ponga de manifiesto la necesidad de aplicarla.
- Finalmente, el mismo precepto dispone que el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento en los dos supuestos señalados.
- Sin embargo, no se estimará quebrantamiento la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar el inicialmente consentido si bien el Juez o Tribunal podrá acordar su sustitución por otra medida de las aplicables al caso de que se trate.
- En cuanto al **quebrantamiento de la medida de libertad vigilada**, el art. 106 dispone que el Juez o Tribunal podrá modificar las obligaciones o prohibiciones fijadas por el procedimiento previsto en el art. 98.
- Finalmente, si el incumplimiento fuere reiterado o grave y revelare la voluntad del condenado de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá testimonio por delito de quebrantamiento de condena del art. 468.

DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNAMIENTO

- En cuanto a la determinación de la duración de la medida de internamiento, distinguimos dos supuestos según se hubiere apreciado una eximente completa o incompleta.
- En cuanto a la **eximentes completas**, los arts. 101 a 103 disponen que el internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable del hecho. En este sentido, será necesario que el Juez o Tribunal fijen en la sentencia dicho límite máximo.

- En cuanto a las **eximentes incompletas**, el art. 104 dispone que el internamiento no excederá de la pena prevista por el Código Penal para el delito de que se trate.
 - Por su parte, el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2009 declaró que la duración máxima de la medida se determinará en función de la pena en abstracto señalada para el delito de que se trate.
 - No obstante, la jurisprudencia reciente viene declarando que deberá tenerse en cuenta las reglas de individualización derivadas del grado de participación y ejecución pero sin considerar las circunstancias atenuantes o agravantes de carácter genérico¹.

CONCURRENCIA DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Pasando a ocuparnos de la concurrencia de penas y medidas de seguridad, el Código Penal acoge el llamado sistema vicarial conforme al cual la medida de seguridad se ejecuta antes que la pena pero el tiempo de duración de aquélla se abona para el cumplimiento de ésta sin perjuicio de la posibilidad de suspensión del cumplimiento del resto de la pena.
- En este sentido, el art. 99 dispone lo siguiente:
 - 1º. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.*
 - 2º. Una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.*

¹ STS 1 de febrero de 2012.

DERECHO PENAL

TEMA 24

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. LAS COSTAS PROCESALES.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

- Al estudiar la responsabilidad civil derivada del delito, hay que comenzar señalando que la comisión de un hecho delictivo puede llevar consigo no sólo la imposición de una pena o una medida de seguridad sino también la obligación de reparar el daño causado.
 - En efecto, el art. 109 del Código Penal dispone que *la ejecución de un hecho previsto por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos por las leyes, los daños y perjuicios por él causados.*
 - Por su parte, el art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que *de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados por el hecho punible.*
- En cuanto a los **caracteres de la acción civil ex delicto**, distinguimos los siguientes:
 - Primero, se trata de una acción civil por lo que está sometida a los principios generales de las acciones civiles sin perjuicio de la aplicación preferente de las especialidades legales para su ejercicio en el proceso penal.
 - Segundo, se trata de una acción accesoria de la acción penal porque solamente podrá ejercerse ante la jurisdicción penal en el seno de un proceso penal abierto. Del mismo modo, el Juez sólo se pronunciará sobre ella si recae sentencia condenatoria a menos que la absolución se funde en alguna de las eximentes previstas en el Código Penal.
 - Tercero, se trata de una acción contingente porque el perjudicado podrá ejercitarla en el proceso penal o en un proceso civil separado. En efecto, el art. 109 del Código Penal que dispone que *el perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil.*
 - Por otra parte, el art. 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que las acciones que nacen de un delito podrán ejercitarse junta o separadamente pero, si la acción penal estuviese pendiente, la acción civil no podrá ejercitarse por separado en tanto recaiga sentencia firme sobre la primera.
 - Por su parte, el art. 112 dispone que la acción civil se entiende ejercitada junto con la acción penal a menos que el perjudicado renuncie a ella o se la reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el proceso penal. Sin embargo, si se ejercitare sólo la acción civil en relación con delitos perseguibles por querrela del ofendido, se considerará extinguida la acción penal.
 - Cuarto, se trata de una acción sujeta al principio dispositivo por lo que el Juez no se pronunciará sobre ella de oficio y las partes podrán disponer de ella mediante actos como la renuncia, el desistimiento, el allanamiento y transacción.
 - En efecto, el art. 106 dispone que la acción civil se extingue por la renuncia de la persona ofendida.
 - No obstante, el art. 112 dispone que la renuncia podrá revocarse por resolución judicial, a solicitud del perjudicado y con audiencia de las partes en el caso de que las consecuencias del delito sean más graves de las que previstas en el momento de la renuncia o que ésta pudiera haber estado condicionada por la relación de la víctima con alguno de los responsables del delito y siempre que la solicitud se formule antes del trámite de calificación del delito.
 - Quinto, se trata de una acción transmisible activa y pasivamente. En efecto, el art. 115 dispone que la acción penal se extingue por la muerte del culpable pero la acción civil subsistirá contra los herederos y causahabientes y sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción civil.
 - Sexto, se trata de una acción de contenido patrimonial porque se dirige a la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios causados frente a la acción penal que se dirige a la imposición de una pena o medida de seguridad.

CONTENIDO

- En cuanto al contenido de la responsabilidad civil, el art. 110 del Código Penal dispone que *la responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende:*
 - 1º. *La restitución.*
 - 2º. *La reparación del daño.*
 - 3º. *La indemnización de perjuicios materiales y morales.*
- En cuanto a la **restitución**, el art. 111 dispone lo siguiente:
 - 1º. *Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito.*
 - 2º. *Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable.*
- En relación con este precepto, conviene señalar que la restitución tiene carácter preferente siempre que sea posible pero será compatible con la indemnización de perjuicios cuando se acredite su producción.
- En cuanto a la **reparación**, el art. 112 dispone que *la reparación del daño podrá consistir en obligaciones dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.*
- Por otro lado, la jurisprudencia ha declarado que la reparación del daño podrá consistir en la restauración del orden jurídico perturbado con la consiguiente declaración de nulidad de los contratos ilícitos como sucede en los siguientes casos¹:
 - Primero, el art. 172 bis del Código Penal dispone que *en las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos.*
 - Segundo, el art. 216 dispone que *en los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.*
 - Tercero, tratándose de delitos de alzamiento de bienes, la jurisprudencia ha declarado que la responsabilidad civil no consiste en el pago de la deuda sino en la nulidad del negocio jurídico de que se trate y la restitución de los bienes al patrimonio del deudor.
- En cuanto a la **indemnización de perjuicios**, se establecen tres reglas:
 - Primero, el art. 113 dispone que *la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o terceros.*
 - Segundo, el art. 114 dispone que *si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización.*
 - Tercero, el art. 115 dispone que *los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.*
- Finalmente, la jurisprudencia ha declarado que los perjuicios no se presumen por lo que será necesaria la prueba de su existencia y de la relación de causalidad con el delito².

PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES

- En cuanto a las personas civilmente responsables, distinguiremos entre la responsabilidad civil directa y la responsabilidad civil subsidiaria.

RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS

- En cuanto a los responsables civiles directos, el art. 116 dispone lo siguiente:
 - 1º. *Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito, los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.*
 - 2º. *Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables.*
 - 3º. *La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva primero en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices.*
 - 4º. *Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.*
- En cuanto a las **personas jurídicas**, el art. 116.3 dispone que *la responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.*
- En cuanto a los **aseguradores**, el art. 117 dispone que *los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.*
 - En relación con este precepto, la jurisprudencia ha declarado que la responsabilidad civil del asegurador no se extingue cuando el daño haya sido causado dolosamente por el asegurado sin perjuicio de su derecho de repetición contra éste³.
 - Finalmente, el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2007 declaró que el asegurador del perjudicado por el delito que satisfaga cantidades en virtud del seguro podrá reclamar en el proceso penal contra el causante de los daños y subrogarse en la posición del perjudicado.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL

- En cuanto a la responsabilidad civil directa en casos de exención de responsabilidad penal, hay que señalar que la apreciación de ciertas eximentes completas no implica la exención de responsabilidad civil.
- En cuanto a la **anomalías, alteraciones psíquicas y alteraciones en la percepción**, el art. 118.1.1ª dispone que *son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.*
- En cuanto a la **intoxicación plena**, el art. 118.1.2ª dispone que *son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado.*

- En cuanto al **estado de necesidad**, el art. 118.1.3ª dispone las siguientes reglas:
 - 1º. *Serán responsables civiles directos las persona en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.*
 - 2º. *Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.*
- En cuanto al **miedo insuperable**, el art. 118.1.4ª dispone que *responderán principalmente los que hayan causado el miedo y, en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.*
- En cuanto al **error**, el art. 118.2 dispone que *serán responsables civiles los autores del hecho.*
- Finalmente, el art. 119 dispone que *en todos los supuestos del artículo anterior, el Juez o Tribunal que dicte sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamar en la vía que corresponda.*

RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS

- Pasando a ocuparnos de la responsabilidad civil subsidiaria, ésta exige tres requisitos:
 - Primero, la condena del responsable civil directo como autor o partícipe de un delito.
 - Segundo, la existencia entre éste y el responsable civil subsidiario de cualquiera de las relaciones de dependencia legalmente previstas.
 - Tercero, la insolvencia total o parcial del responsable civil directo.
- En cuanto a los **curadores**, el art. 120.1º dispone que *son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.*
- En cuanto a los **titulares de medios de difusión**, el art. 120.2º se refiere a *las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el art. 212 de este Código.*
- Por su parte, el art. 212 dispone que, *en los delitos de calumnia e injuria cometidos con publicidad, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.*
- En cuanto a los **titulares de establecimientos**, distinguimos dos preceptos:
 - Por un lado, el art. 120.3º se refiere a *las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.*
 - Por otro lado, el art. 120.4º se refiere a *las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.*

- En cuanto a los **titulares de vehículos**, el art. 120.5º se refiere a *las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquéllos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.*
- En cuanto a los **entes públicos**, el art. 121 establece lo siguiente:
 - 1º. *El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.*
 - 2º. *Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.*

PARTÍCIPIES A TÍTULO LUCRATIVO

- En cuanto a la responsabilidad de los partícipes a título lucrativo, el art. 122 dispone que *el que, por título lucrativo, hubiere participado de los efectos de un delito está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.*
 - En relación con este precepto, la jurisprudencia sostiene que se trata de una especie de receptación civil y que exige dos requisitos como son que el partícipe en los efectos del delito no haya sido condenado por éste y que la participación sea a título lucrativo por lo que no bastará que se trate de adquirentes a título oneroso y de buena fe⁴:
 - Por el contrario, no será necesario el conocimiento del origen ilícito de los bienes en cuyo caso podría existir responsabilidad penal.

PAGO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

- En cuanto al pago de la responsabilidad civil, el art. 125 dispone que *cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez o Tribunal, previa audiencia del perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el periodo e importe de los plazos.*
- En cuanto a la **imputación de pagos**, el art. 126 dispone que *los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:*
 - 1º. *A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.*
 - 2º. *A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.*
 - 3º. *A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.*
 - 4º. *A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.*
 - 5º. *A la multa.*

- Por otro lado, el apartado 2 dispone que *cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.*

EJECUCIÓN DE LA CONDENA CIVIL

- En cuanto a la ejecución de la condena civil, el art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la ejecución de pronunciamientos sobre responsabilidad civil se ajustará a las disposiciones de Ley de Enjuiciamiento Civil con la salvedad de que será promovida de oficio por el Juez que hubiera dictado la condena.
- No obstante, el Letrado de la Administración de Justicia podrá encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria u órganos tributarios de las Haciendas Forales las actuaciones de investigación necesarias para la averiguación de las rentas y el patrimonio del condenado hasta que haga efectiva la responsabilidad civil.
- En cuanto a la **prescripción de la reclamación**, la jurisprudencia consideró tradicionalmente que la acción para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos civiles de una sentencia prescribía en caso de paralización de la ejecutoria durante los plazos previstos en los arts. 1964 y 1971 del Código Civil
- Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2020 declaró que, una vez declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles podrá continuar hasta la satisfacción completa del acreedor conforme a lo dispuesto para el proceso de ejecución forzosa en el art. 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sin que resulten aplicables plazos de prescripción ni caducidad.

LAS COSTAS PROCESALES

- Pasando a ocuparnos de las costas procesales, conviene recordar que son gastos procesales los derivados directa e inmediatamente de la existencia del proceso y costas procesales los que deben soportar las partes.
- En cuanto a la **condena en costas**, el art. 123 del Código Penal dispone que *las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.*
 - En este sentido, el art. 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberán pronunciarse sobre el pago de las costas.
 - Por su parte, el art. 240 dispone que este pronunciamiento podrá consistir en declarar las costas de oficio, en imponerlas a los procesados con expresión de la parte de que deba responder cada uno o en imponerlas al querellante particular o actor civil en caso de que hubieran actuado con temeridad o mala fe. Sin embargo, las costas nunca se impondrán a los procesados que resultaren absueltos.
- En cuanto a la **composición de las costas**, el art. 124 del Código Penal dispone que *las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.*
- Finalmente, el art. 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye en el concepto de costas los honorarios de Abogados y peritos, el pago de los gastos de arancel, las indemnizaciones de los testigos que las reclamen y los demás gastos originados en la instrucción de la causa.

¹ SSTS 31 de enero de 1989 y 4 de junio de 1993.

² STS 5 de febrero de 2007.

³ SSTS 16 de abril de 2011, 20 de marzo de 2013, 5 de noviembre de 2018 y 23 de abril de 2019.

⁴ SSTS 27 de marzo de 2009, 15 de julio de 2011 y 1 de abril de 2016.

DERECHO PENAL

TEMA 25

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL. LA CANCELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PENALES. BREVE REFERENCIA AL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES Y TRATA DE SERES HUMANOS.

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

- Al estudiar la extinción de la responsabilidad criminal, hay que comenzar señalando el art. 130 del Código Penal que dispone que *la responsabilidad criminal se extingue*:
 - 1º. *Por la muerte del reo.*
 - 2º. *Por el cumplimiento de la condena.*
 - 3º. *Por la remisión definitiva de la pena conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87.*
 - 4º. *Por la amnistía o el indulto.*
 - 5º. *Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea.*
 - 6º. *Por la prescripción del delito.*
 - 7º. *Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.*
- En cuanto a la **extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas**, el apartado 2 dispone lo siguiente:
 - 1º. *La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.*
 - 2º. *No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.*

MUERTE DEL REO

- Pasando a ocuparnos de la muerte del reo, ésta producirá efectos distintos según tenga lugar antes o después del pronunciamiento de la sentencia.
 - En este sentido, si el reo fallece antes de recaer sentencia, la muerte producirá la extinción de la acción penal pero no de la acción civil. En efecto, el art. 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que *la acción penal se extingue por la muerte del culpable pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos o causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil.*
 - Por el contrario, si el reo fallece después de recaer sentencia condenatoria firme, la muerte producirá la extinción de la pena impuesta.
- Por otro lado, conviene advertir que la responsabilidad penal no se extingue por la declaración de fallecimiento porque el Código Penal no contempla esta posibilidad y, además, se trata de una presunción *iuris tantum* que quedará sin efecto si el declarado fallecido se presenta o se tienen noticias de su existencia.

CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA

- En cuanto al cumplimiento de la condena, se trata de la causa ordinaria de extinción de la responsabilidad criminal.

- En este sentido, el cumplimiento de la pena extingue la responsabilidad penal pero no cancela los antecedentes penales, que pueden resultar relevantes a efectos de apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia o apreciación de la habitualidad conforme a los arts. 22 y 94.

REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA

- En cuanto a la remisión definitiva de la pena, el art. 80 dispone que *los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no será necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.*
- Por su parte, el art. 87 dispone que el Juez o Tribunal acordará la remisión definitiva de la pena una vez transcurrido el plazo de suspensión sin que el sujeto hubiera cometido ningún delito que revele que la expectativa en que se fundaba la suspensión no puede ser mantenida y siempre que haya cumplido suficientemente las reglas de conducta impuestas.

AMNISTÍA

- En cuanto a la amnistía, ésta fue introducida por la reforma del art. 130 del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
- No obstante, el 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplaba anteriormente la amnistía como artículo de previo pronunciamiento.
- Por otro lado, conviene señalar el auto del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2024 que planteó cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2024 por vulneración del derecho constitucional a la igualdad ante la ley y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.

INDULTO

- En cuanto al indulto, podemos definirlo como *aquel acto del Poder Ejecutivo a través del cual se perdonan o atenúan las consecuencias jurídicas de un delito impuestas por sentencia firme.*
 - En relación con él, el art. 62 de la Constitución dispone que *corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.*
 - Por otro lado, el indulto viene regulado en la Ley sobre Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870.
- En cuanto a las **clases de indulto**, el art. 4 dispone que el indulto podrá ser total o parcial si bien el indulto total sólo se otorgará cuando existan razones de justicia, equidad o utilidad pública a juicio del Juez o Tribunal sentenciador.
 - En este sentido, el indulto total supondrá la remisión de todas las penas impuestas y que todavía no hubiesen sido cumplidas por el delincuente.
 - Por su parte, el indulto parcial supondrá la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o de parte de las impuestas y que todavía no hubiesen sido cumplidas por el delincuente. Del mismo modo, también se equipara al indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente por otras menos graves.
- En cuanto a los **beneficiarios**, el art. 1 dispone que *los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido.*

- No obstante, el art. 2 establece las siguientes excepciones:
 - Primero, los procesados que no hubieran sido condenados por sentencia firme.
 - Segundo, los que no estuvieren a disposición del Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
 - Tercero, los reincidentes en el mismo o cualquier otro delito por el que hubieran sido condenados en sentencia firme salvo que el Juez o Tribunal sentenciador estime razones suficientes de justicia, equidad o convivencia pública.
 - Finalmente, el art. 102 de la Constitución exceptúa los casos de responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del Gobierno.
- Por otra parte, el art. 15 dispone que el indulto no podrá concederse si causare perjuicio a un tercero y tratándose de delitos perseguibles a instancia de parte, será necesaria la audiencia del ofendido.
- En cuanto al **procedimiento para su concesión**, el art. 19 dispone que podrán solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier persona en su nombre sin necesidad de acreditar por escrito su representación.
- De igual modo, también podrán proponer el indulto el Tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el Fiscal de cualquiera de dichos órganos.
 - Por su parte, el art. 4 del Código Penal dispone que si mediara petición de indulto, el Juez o Tribunal suspenderá la ejecución de la pena en tanto no se resuelva sobre la petición siempre que hubiese apreciado en resolución motivada que el cumplimiento de la pena podría vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Del mismo modo, el Juez o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena tanto cuando ésta pudiera convertir en ilusoria la finalidad del indulto.
 - Finalmente, la Ley regula un expediente con informe del Juez o Tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal. Por su parte, la concesión de indulto se realizará mediante Real Decreto y su aplicación corresponderá al Tribunal sentenciador.
- En cuanto a sus **efectos**, se establecen los siguientes:
 - En primer lugar, el indulto de la pena principal lleva consigo el de las accesorias salvo la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y la sujeción a vigilancia de la autoridad salvo que se haga expresa referencia a ellas. Del mismo modo, tampoco se entenderán incluidas la responsabilidad civil ni las costas procesales.
 - En segundo lugar, también podrá concederse el indulto de las penas accesorias pero no de la pena principal y viceversa a menos que aquéllas fuesen inseparables de éstas por su propia naturaleza.
 - En tercer lugar, el indulto de una pena pecuniaria no se extenderá a la devolución de lo pagado salvo que se determine expresamente.
 - Por último, la concesión del indulto será irrevocable.
- En cuanto a la **distinción entre amnistía e indulto**, hay que señalar las siguientes diferencias:
 - Primero, el indulto afecta a uno o varios sujetos en atención a circunstancias específicas mientras que la amnistía afecta a una pluralidad de sujetos en atención a circunstancias generales.
 - Segundo, el objeto del indulto es la pena impuesta por sentencia firme mientras que el objeto de la amnistía es el delito cometido.
 - Tercero, el indulto se concede mediante acto del Poder Ejecutivo mientras que la amnistía se concede mediante acto del Poder Legislativo.
 - Cuarto, el indulto supone el perdón o atenuación de las consecuencias jurídicas del delito mientras que la amnistía supone la extinción de todos sus efectos, incluyendo la responsabilidad civil y la anotación de antecedentes penales.

PERDÓN DEL OFENDIDO

- En cuanto al perdón del ofendido, el art. 130.5 dispone lo siguiente:
 - 1º. *El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.*
 - 2º. *En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.*
- Por otro lado, conviene señalar que el Código Penal admite la eficacia del perdón en relación con delitos como los de descubrimiento y revelación de secretos, calumnias e injurias y daños por imprudencia.

PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

- En cuanto a la prescripción del delito, podemos definirla como *la extinción de la perseguibilidad de un delito por el transcurso de un cierto periodo de tiempo.*
- En cuanto a su **fundamento**, la prescripción puede obedecer a las siguientes motivaciones:
 - Primero, la necesidad de impedir que un sujeto pueda quedar indefinidamente sometido a la amenaza de incoación de un proceso penal por razones de seguridad jurídica.
 - Segundo, la disminución de la necesidad de pena por el transcurso del tiempo desde el punto de vista de la retribución y de la prevención especial.
 - Tercero, la dificultad probatoria existente cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.
- En cuanto a los **plazos de prescripción**, el art. 131 establece los siguientes plazos:
 - Primero, veinte años cuando la pena máxima señalada para el delito sea prisión igual o superior a quince años.
 - Segundo, quince años cuando la pena máxima señalada sea inhabilitación superior a diez años o prisión por más de diez y menos de quince años.
 - Tercero, diez años cuando la pena máxima señalada sea prisión o inhabilitación por más de cinco y hasta diez años.
 - Cuarto, cinco años para los demás delitos salvo los delitos leves y los delitos de injuria y calumnia que prescriben al año.
 - Por último, se establece que los delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado salvo los sancionados en el art. 614 y los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de alguna persona no prescribirán en ningún caso.
- En cuanto a los **supuestos especiales**, el art. 131 dispone que si la pena señalada por la ley fuere compuesta, el plazo aplicable será el correspondiente a la pena que exija un plazo mayor y, si existiere concurso de infracciones o infracciones conexas, el plazo será el correspondiente al delito más grave.
 - Por otro lado, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010 declaró que el plazo de prescripción aplicable será el del delito que se declare cometido por el tribunal sentenciador.
 - De este modo, no se tendrán en cuenta las calificaciones agravadas propuestas por las partes acusadoras que hubieran sido rechazadas por el tribunal como cuando se solicita la condena por un delito menos grave y el tribunal degrada la infracción a delito leve.

- En cuanto al **cómputo del plazo**, el art. 132 dispone que los plazos se computarán desde el día en que se hubiere cometido la infracción con las siguientes especialidades:
 - Primero, tratándose de delito continuado, delito permanente o infracciones que exijan habitualidad, el plazo se computará desde el día en que se realizó la última infracción o se eliminó la situación ilícita o cesó la conducta, respectivamente.
 - Segundo, tratándose de delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos del párrafo siguiente y si la víctima fuere menor de dieciocho años, el plazo se computará desde el día en que alcance la mayoría de edad y, si fallece antes de alcanzarla, desde la fecha del fallecimiento.
 - Tercero, tratándose de delitos de tentativa de homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150, maltrato habitual del art. 173.2, delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos y si la víctima fuere menor de dieciocho años, el plazo se computará desde que cumpla los treinta y cinco años y, si fallece antes de esa edad, desde la fecha del fallecimiento.
- En cuanto a la **interrupción de la prescripción**, el apartado 2 dispone que *la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:*
 - 1º. *Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.*
 - 2º. *No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.*
- En relación con estos últimos supuestos, se establecen dos reglas adicionales:
 - Por un lado, si dentro de este plazo de seis meses se dictare contra el denunciado, el querellado u otra persona implicada en los hechos alguna de las resoluciones citadas en la regla 1ª, la interrupción de la prescripción se entenderá producida retroactivamente en la fecha de presentación de la denuncia o querella.
 - Por otro lado, si dentro de este plazo de seis meses se dictare resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la denuncia o querella o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra el denunciado o querellado o bien el Juez de Instrucción no dictara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo, el cómputo de la prescripción continuará desde la presentación de la denuncia o querella.
- Finalmente, el apartado 3 dispone que la resolución judicial deberá determinar suficientemente a la persona contra la que se dirige el procedimiento por su identificación directa o por datos que permitan concretar posteriormente la identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.
- En cuanto a la **interrupción en los procedimientos asumidos por la Fiscalía Europea**, el apartado 4 dispone que la interrupción se producirá en dos casos.
 - Primero, cuando la investigación se dirija contra persona determinada y suficientemente identificada conforme al apartado 3 y así se refleje en Decreto motivado.
 - Segundo, cuando se interponga denuncia o querella ante la Fiscalía Europea en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito en cuyo caso se aplicará la regla 2ª del apartado 2.

PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

- En cuanto a la prescripción de la pena, el art. 133 contempla plazos distintos en función de la clase y duración de la pena impuesta y oscilan entre uno y treinta años.
 - No obstante, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado salvo los previstos en el art. 614 y los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de alguna persona no prescribirán en ningún caso.
 - Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que los plazos de prescripción de la pena se aplicarán en función de la pena impuesta y no en función del marco penal abstracto previsto por la ley¹.
- En cuanto al **cómputo del plazo**, el art. 134 dispone que éste se computará desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena en el caso de que ésta hubiera comenzado a cumplirse.
 - Por otro lado, este plazo quedará en suspenso durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena y durante el cumplimiento de otras penas cuando resulte aplicable el art. 75.
 - En este sentido, conviene recordar el art. 75 que dispone que cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.

PRESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

- En cuanto a la prescripción de las medidas de seguridad, el art. 135 dispone que las medidas privativas de libertad prescribirán a los diez años si su duración fuese superior a tres y a los cinco años si su duración fuese igual o inferior a tres.
- Por su parte, las medidas no privativas de libertad prescribirán a los cinco años.
- En cuanto al **cómputo del plazo**, éste se computará desde el día de la firmeza de la resolución y, en caso de cumplimiento sucesivo de varias medidas, desde el día en que cada una de ellas debió comenzar a cumplirse.
- Por otro lado, si el cumplimiento de la medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de la pena.

LA CANCELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PENALES

- Pasando a ocuparnos de la cancelación de los antecedentes penales, el art. 136 dispone que *los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos*:
 - Primero, seis meses para las penas leves.
 - Segundo, dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
 - Tercero, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
 - Cuarto, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
 - Por último, diez años para las penas graves.

- En cuanto al **cómputo de los plazos**, éstos se contarán desde el día siguiente a aquél en que hubiera quedado extinguida la pena.
 - Sin embargo, si el condenado hubiere obtenido la remisión condicional, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que habría cumplido la pena de no haber disfrutado dicho beneficio y una vez obtenida la remisión definitiva.
 - Finalmente, el apartado 5 dispone que si a pesar de cumplirse los requisitos previstos para la cancelación, ésta no se hubiera producido, el Juez o Tribunal no tendrá en cuenta los antecedentes.

BREVE REFERENCIA AL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES Y TRATA...

- Pasando a ocuparnos del Registro Central de Delinquentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, se trata de un registro creado por el Real Decreto 1110/2015.
- En cuanto a su **naturaleza**, el art. 3 dispone que se trata de un sistema de información sobre la identidad, perfil **genético**, penas y medidas de seguridad impuestas a las personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual o trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía y con independencia de la edad de las víctimas.
- Por su parte, el art. 6 dispone que las inscripciones harán constar el código identificador del perfil genético del condenado cuando el órgano judicial lo haya acordado.
- En cuanto a su **finalidad**, el art. 3 contempla dos:
 - Por un lado, establecer un mecanismo de prevención para conocer si quienes pretendan ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores cuentan o no con condenas penales por los delitos citados.
 - Por otro lado, facilitar la investigación y persecución de los delitos citados para proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual.
- En cuanto a la **información registral**, el art. 6 dispone que el Ministerio de Justicia autorizará el acceso directo a ella de los Jueces y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.
- Por su parte, el art. 9 contempla la obtención de certificados a petición de los órganos judiciales, de personas inscritas y no inscritas y de los órganos de las Administraciones Públicas ante los que se tramiten procedimientos para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores con consentimiento de los interesados.

¹ SSTs 29 de mayo de 1999 y 23 de mayo de 2001.

DERECHO PENAL

TEMA 26

EL DERECHO PENITENCIARIO. LA RELACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA. EL JUEZ DE VIGILANCIA. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

EL DERECHO PENITENCIARIO

- Al estudiar el Derecho penitenciario, podemos comenzar definiéndolo como *aquel conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad*.
- En cuanto su **evolución**, hay que señalar que el Derecho Penitenciario moderno es resultado de un proceso de evolución histórica que se remonta a la Ilustración y que se manifiesta en las obras de autores como Beccaría y Howard.
 - En este sentido, la Ilustración introduce una humanización en el cumplimiento de las penas y da lugar al nacimiento de sistemas penitenciarios como el sistema progresivo, caracterizado por una disminución paulatina en las condiciones de ejecución de la pena de prisión desde la reclusión celular hasta la libertad condicional.
 - Por otro lado, esta evolución culmina con Ley Orgánica General Penitenciaria cuyo art. 72 dispone que *las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional conforme determina en Código Penal*.
- En cuanto a sus **fuentes**, éstas incluyen la Constitución de 1978, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, el Reglamento Penitenciario de 1996, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las Circulares de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

LA RELACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA

- Pasando a ocuparnos de la relación jurídica penitenciaria, podemos definirla como *el conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce a los reclusos en su relación con la Administración*.
- En cuanto a su **nacimiento**, el art. 15.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que *el ingreso de un detenido, preso o penado en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará mediante mandamiento u orden de la autoridad competente excepto en el supuesto de presentación voluntaria que será inmediatamente comunicado a la Autoridad Judicial quien resolverá lo procedente, y en los supuestos de estado de alarma, excepción o sitio, en los que se estará a lo que dispongan las correspondientes leyes especiales*.
- En cuanto a los **derechos de los internos**, el art. 25.2 de la Constitución de 1978 dispone que *el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad*.
- Por otra parte, el art. 3.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que *la actividad penitenciaria se ejercerá respetando en todo caso la personalidad humana de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza*.
- Por su parte, el apartado 2 dispone lo siguiente:
 - En primer lugar, la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni malos tratos de palabra o de obra ni a un rigor innecesario en la aplicación de las normas.
 - En segundo lugar, los internos tienen derecho a la preservación de su dignidad y de su intimidad y, en particular, a ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros.
 - En tercer lugar, los internos tienen derecho a ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales con la única excepción de los que sean incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

- Finalmente, la Ley y el Reglamento Penitenciario contemplan los siguientes derechos:
 - Primero, el derecho al tratamiento y a los beneficios penitenciarios previstos en la ley.
 - Segundo, el derecho a recibir comunicaciones y visitas.
 - Tercero, el derecho a un trabajo remunerado sujeto de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.
 - Cuarto, el derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento así como a utilizar los medios oportunos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos legalmente previstos.
 - Sexto, el derecho a la libertad religiosa.
 - Por último, el derecho a recibir educación e instrucción.
- En cuanto a los **deberes de los internos**, el art. 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que *los internos deberán*:
 - 1º. *Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.*
 - 2º. *Acatar las normas de régimen interior reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44.*
 - 3º. *Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslados, conducciones o prácticas de diligencias.*
 - 4º. *Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento.*
- En cuanto a la **extinción de la relación jurídica penitenciaria**, el art. 17 dispone lo siguiente:
 - 1º. *La libertad de los detenidos, presos o penados sólo podrá ser acordada por la autoridad competente.*
 - 2º. *Los detenidos serán puestos en libertad por el Director del establecimiento si, transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso, no se hubiere recibido mandamiento u orden de prisión.*
 - 3º. *Para proceder a la excarcelación de los condenados será precisa la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o de la propuesta de libertad condicional por el Juez de Vigilancia.*

EL JUEZ DE VIGILANCIA

- Pasando a ocuparnos del Juez de Vigilancia, hay que señalar que la intervención del Juez en la ejecución de las penas privativas de libertad era mínima hasta la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979.
- En cuanto a su **demarcación**, el art. 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y dentro del orden jurisdiccional penal existirá con carácter general una Sección de Vigilancia Penitenciaria.
 - No obstante, podrán establecerse Secciones de Vigilancia Penitenciaria en Tribunales de Instancia con sede en poblaciones distintas de la capital de provincia.
 - De igual modo, una Sección podrá extender su jurisdicción a uno o más partidos dentro de la misma provincia o a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.

- En cuanto a su **competencia**, el art. 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que *el Juez de Vigilancia tendrá competencia para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que, en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario, puedan producirse.*
- Por otro lado, el apartado 2 atribuye al Juez de Vigilancia las siguientes competencias:
 - Primero, adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
 - Segundo, resolver las propuestas relativas a la libertad condicional y su revocación.
 - Tercero, aprobar las propuestas de los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena.
 - Cuarto, aprobar las sanciones de aislamiento en celda por más de catorce días.
 - Quinto, resolver los recursos relativos a sanciones disciplinarias, a clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.
 - Sexto, adoptar las decisiones procedentes sobre las peticiones y quejas de los internos en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto pueda afectar a sus derechos fundamentales o a sus derechos o beneficios penitenciarios.
 - Séptimo, realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 - Séptimo, autorizar permisos de salida de duración superior a dos días a menos que se trate de clasificados en tercer grado.
 - Por último, conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado.

EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

- Pasando a ocuparnos del tratamiento penitenciario, el art. 59 lo define como el conjunto de actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.
- Por su parte, el art. 71 establece un principio de subordinación del régimen penitenciario al tratamiento penitenciario al disponer que *el fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas.*
- En cuanto a los **principios del tratamiento**, el art. 62 establece los siguientes:
 - En primer lugar, el tratamiento se planificará partiendo de un estudio científico de la personalidad del sujeto, su actividad delictiva y su entorno que se reflejarán en un diagnóstico de personalidad criminal y un pronóstico inicial.
 - En segundo lugar, el tratamiento será individualizado y se basará en la aplicación de métodos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales en relación con la personalidad del sujeto.
 - En tercer lugar, el tratamiento será complejo ya que se basará en la aplicación conjunta de varios de los métodos anteriores en una misma dirección.
 - En cuarto lugar, el tratamiento será programado a través de un plan en el que se fijará la mayor o menor intensidad en la aplicación de cada uno de los métodos de tratamiento y la distribución de tareas entre especialistas y educadores.
 - Por último, el tratamiento será continuado y dinámico en función de los cambios que la personalidad del interno pueda experimentar durante el cumplimiento de su condena.

FASE DE OBSERVACIÓN

- En cuanto a la fase de observación, ésta tiene por finalidad el estudio de la personalidad del interno, su entorno, su historial delictivo y las dificultades para el éxito del tratamiento.
 - En este sentido, el art. 60 dispone que los servicios encargados del tratamiento procurarán conocer aquellas peculiaridades de la personalidad y entorno del penado que puedan suponer un obstáculo para el éxito del tratamiento y utilizarán todos los medios de tratamiento que puedan facilitar dicho éxito con respeto a los derechos constitucionales del penado no afectados por la condena.
 - No obstante, el interno podrá abstenerse de colaborar en estas técnicas de estudio de su personalidad sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, reglamentarias ni de regresión de grado en cuyo caso la clasificación inicial y las sucesivas revisiones de grado se realizarán por la observación directa de su comportamiento y los informes de los equipos técnicos.

FASE DE CLASIFICACIÓN

- En cuanto a la fase de clasificación, ésta tiene por finalidad la determinación del grado de cumplimiento de la pena una vez finalizada la fase de observación.
- En cuanto a los **grados de cumplimiento**, el art. 102 del Reglamento Penitenciario distingue entre primer, segundo y tercer grado conforme a las siguientes reglas:
 - En primer lugar, se clasificará en segundo grado a los penados en quienes concurren circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia pero sin capacidad para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
 - En segundo lugar, se clasificará en tercer grado a los internos en quienes concurren circunstancias personales y penitenciarias por las que estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
 - En tercer lugar se clasificará en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a los regímenes comunes.
- Por su parte, el art. 72 dispone que los penados clasificados en primer grado se destinarán a establecimientos de régimen cerrado; los clasificados en segundo grado a establecimientos de régimen ordinario y los clasificados en tercer grado a establecimientos de régimen abierto.
 - Por otro lado, se establece que siempre que por la observación de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser clasificado inicialmente en un grado superior salvo el de libertad condicional sin pasar previamente por los grados anteriores.
 - Del mismo modo, tampoco podrá mantenerse a un interno en un grado inferior cuando la evolución de su tratamiento aconseje la progresión de grado.
- En cuanto a las **normas sobre progresión y regresión de grado**, el art. 65 dispone que la evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación de los internos a cuyo efecto éstos serán estudiados con una periodicidad mínima de seis meses.
 - En este sentido, la progresión de grado procederá cuando se aprecie una modificación de los aspectos de la personalidad del penado que estén directamente relacionados con su actividad delictiva y se traducirá en el aumento de la confianza depositada en el mismo y en una mayor libertad. Por su parte, la regresión de grado procederá cuando se aprecie una evolución desfavorable de la personalidad del interno.
 - Finalmente, si un mismo equipo reiterase dos veces la calificación del interno en primer grado, éste podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se realice por la Central de Observación. De igual modo, los internos clasificados en segundo grado que hubieran extinguido la mitad de su condena podrán hacer uso de esta facultad cuando concurren las mismas circunstancias señaladas.

- En cuanto a los **requisitos del tercer grado**, el art. 36.2 del Código Penal prevé lo siguiente:
 - 1º. *La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.*
 - 2º. *Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.*
 - 3º. *En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código; b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal; c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código cuando la víctima sea una persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección; d) Delitos del artículo 181; e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código cuando la víctima sea menor de dieciséis años.*
 - 4º. *En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de prisión la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.*
 - 5º. *La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el apartado anterior.*
 - 6º. *En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad.*
- Por otro lado, tratándose de condenados a pena de prisión permanente revisable, el art. 36.1 dispone que *la clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias y no podrá efectuarse:*
 - 1º. *Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.*
 - 2º. *Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva en el resto de los casos.*
- Finalmente, el art. 78 bis establece reglas específicas para el acceso al tercer grado y para la suspensión de la ejecución del resto de la pena en caso de que el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente.
- En cuanto a los **requisitos de la Ley Orgánica General Penitenciaria**, el art. 72 dispone que la clasificación en tercer grado exigirá que los penados hayan satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito para lo cual se tendrá en cuenta la capacidad real para hacer frente a la misma, la conducta efectivamente mostrada por el penado para cumplir dicha responsabilidad, las garantías ofrecidas para asegurar su cumplimiento, el daño o entorpecimiento causado al servicio público y el número y condición económica de los perjudicados.
- Por otro lado, tratándose de condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, será necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y que colabore activamente con las autoridades.

- En cuanto a la **competencia sobre clasificación, progresión y regresión de grado**, el art. 111 del Reglamento Penitenciario dispone que ésta corresponde a la Junta de Tratamiento del establecimiento correspondiente.
 - Por su parte, el art. 70 de la Ley Orgánica General Penitenciaria contempla una Central Penitenciaria de Observación formada por un equipo de especialistas y con funciones de asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento penitenciario.
 - En este sentido, pasarán por este órgano los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o bien los grupos o tipos de internos cuyas peculiaridades convenga investigar.
- Finalmente, ya hemos señalado el art. 76 que dispone que corresponde al Juez de Vigilancia conocer de los recursos relativos a la clasificación inicial y a las progresiones y regresiones de grado.
- Por otro lado, contra estas resoluciones, podrán interponerse los recursos previstos en la disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo estudio es materia de otro tema del programa.

FASE DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICO

- En cuanto a la fase de estudio de resultados y pronóstico, el art. 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que una vez finalizado el tratamiento o si estuviere próxima la libertad del interno, se emitirá un informe final haciendo constar los resultados conseguidos y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad que se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional.

